

2025년 제36회 감정평가사 2차 국가자격 시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목	
3교시	100분	감정평가 및 보상법규	
수험번호		성명	

【문제 1】A시 시장 甲은 1990년에 자연공원법 에 의하여 A 시내 산지 일대 5 k m²를 'X시립공원'으로 지정·고시한 다음, 1992년에 X시립공원 구역을 구분하여 용도지구를 지정하는 내용의 'X시립공원 기본계획'을 결정·공고하였다. 甲은 2017년에 X시립공원 구역 내 10,000 m² 부분에 다목적광장 및 휴양관(이하 '이 사건 시설'이라 한다)을 설치하는 내용의 'X시립공원 공원계획'을 결정·고시한 다음, 2018년에 甲이 사업시행자가 되어 이 사건 시설에 잔디광장, 휴양관, 도로, 주차장을 설치하는 내용의 'X시립공원 공원사업'(이하 '이 사건 시설 조성사업'이라 한다) 시행계획을 결정·고시하였다. 甲은 이 사건 시설 조성사업의 시행을 위하여 그 사업구역 내에 위치한 토지(이하 '이 사건 B토지'라 한다)를 소유한 乙과 손실보상에 관한 협의를 진행하였으나 협의가 성립하지 않자 수용재결을 신청하였다. 乙이 소유하고 있는 토지(이하 '이 사건 B토지'라 한다)는 문화재보호법 상 보호구역으로 지정된 토지로서 이 사건 시설 조성사업의 시행을 위한 사업구역 내에 위치하고 있다. 다음 물음에 답하십시오. (40점)

물음 1) 사업시행자에 대해 설명하고, 국가 이외의 자가 수용권자인 경우 수용권의 주체를 논하십시오. (10점)

물음 2) 甲은 공물인 이 사건 B토지를 이 사건 시설 조성사업의 시행을 위하여 수용할 수 있는가? (15점)

물음 3) 한편, 丙이 소유하고 있는 토지(이 사건 C토지라 한다)는 일부만 사업구역 내에 위치하고 있다. 丙은 잔여토지를 종래 목적대로 사용할 수 없다고 잔여지 수용을 주장한다. 공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률상의 확대보상을 설명하고, 확장수용청구가 거부된 경우 그 불복방법을 논급하십시오. (15점)

【문제 2】토지보상법상 공익사업의 준비를 설명하고, 이로 인한 사업시행자와 토지소유자의 권리구제 방안을 설명하시오. 또한, 공익사업의 준비과정에서 토지소유자가 토지출입을 거부하는 경우 담당 공무원이 실력으로 토지에 들어가 필요한 조사를 할 수 있는지를 논하고, 위법한 측량조사에 따른 사업인정의 효력에 대해 논하시오. (30점)

【문제 3】공용수용의 요건에 대해 설명하고, 공공수용과 공공필요의 관계에 대해 설명하시오. (20점)

【문제 4】사적(私的) 공용수용의 의의 및 요건에 대하여 설명하시오. (10점)

	[문제1] 40점 - 법규 1기 1주차 예시답안, 하지만 평가사
	<물음 1> 10점
	I. 사업시행자의 의의(토지보상법 2조3호)
	사업시행자란 공익사업을 수행하는 자를 말한다(제2조 제3호). 사업시행자는 국가·지방자치단체·법인 또는 사인에 관계없이 특정한 공익사업의 시행자를 말한다. 여기에서 공익사업이란 토지보상법 제4조 각 호 규정에 따른 사업을 말한다. 따라서 사업시행자는 수용적격사업에 관한 법률상 권한을 갖는 자이다.
	II. 사업시행자의 법적 지위
	1. 권리
	사업시행자의 권리에는 ① 사업준비를 위한 타인 토지에의 출입권(제9조), ② 장애물 제거권(제12조), ③ 사업인정 신청권(제20조), ④ 토지 및 물건에 관한 조사권(제27조), ⑤ 재결신청권(제28조), ⑥ 협의성립확인 신청권(제29조), ⑦ 토지나 물건을 원시취득할 권리(제45조), ⑧ 토지나 물건의 인도 또는 이전이 없는 경우 대행신청권(제44조), ⑨ 재결에 불복하는 경우 행정쟁송권(제83조 및 제85조), ⑩ 의무 불이행 등에 대한 대집행신청권(제89조) 등이 있다.
	2. 의무

사업시행자의 의무에는 ① 타인 토지에의 출입 등에 의한 측량·조사, 장애물 제거 등으로 인한 손실보상의무(제9조 제4항, 제12조 제4항), ② 협의 불성립시 피수용자의 재결심 청구구에 응할 의무(제30조 제2항), ③ 피수용자의 고의·과실 없이 수용목적물의 멸실·훼손으로 인한 손실부담의 이전(제46조), ④ 재결로 인한 토지 등 취득시 손실보상의무(제61조) 등이 있다.

Ⅲ. 국가 이외의 자가 수용권자인 경우 수용권의 주체 논의

1. 문제점

국가가 사업시행자인 경우는 논란이 없으나, 국가 이외의 공공단체나 사인(공무수탁사인)이 사업시행자인 경우 수용권의 주체가 누구인지 견해가 대립한다.

2. 학설

① <국가수용권설> 수용권이란 수용의 효과를 야기할 수 있는 능력이므로 수용권자는 국가라고 한다. 사업시행자는 수용권의 발동을 국가에게 청구하는 권리를 갖는데 지나지 않는다고 한다. ② <사업시행자수용권설> 수용의 본질이 특정한 재산권을 취득하는 데 있으므로, 수용권이란 수용의 효과를 누리는 능력이라고 한다. 따라서 수용권자는 사업시행자라고 한다. 이 설이 우리나라 다수설로 되어 있다. ③

<국가위탁권설> 수용권은 국가에 귀속되는 국가적 공권이
고, 국가는 사업인정(수용권 설정)을 통하여 이를 사업시행
자에게 위탁한다고 한다.

3. 판례

대법원은 사업인정을 일정한 절차를 거칠 것을 조건으로 수
용권을 설정해 주는 설권적 형성처분이라 판시하여 사업시
행자수용권설의 입장이다.

4. 검토

국가공권력의 개입이 수용의 효과를 야기한다 하더라도, 현
행 공용수용제도는 공공단체는 물론 기업이나 사인에게도
수용권을 부여하고 있을 뿐 아니라, 수용에 관한 소송도 사
업시행자를 당사자로 할 수 있기 때문에 타당한 논거가 되
지 못한다. 비록 국가가 수용의 효과를 야기한다 하더라도
수용권은 수용의 효과를 누릴 수 있는 능력이라 볼 수 있으
므로, 사업시행자수용권설을 취하는 것이 타당하다.

<물음 2> 15점

I. 논점의 정리

토지보상법 19조 2항의 해석 및 공물의 수용가능성에 대한
학설, 판례를 검토한다.

Ⅱ. 공물의 의의 및 취지	
	공물은 행정주체(국가·지자체)에 의하여 직접 행정목적에 공 용된 개개 유체물로, 공익성 확보 취지가 있다.
Ⅲ. 토지보상법 19조2항	
	토지보상법 19조2항은 “공익사업에 수용되거나 사용되고
	있는 토지등은 특별히 필요한 경우가 아니면 다른 공익사업
	을 위하여 수용하거나 사용할 수 없다”고 규정하고 있어용
	도폐지 없이 공물의 수용이 가능한지와 특별한 필요의 해석
	이 문제된다.
Ⅳ. 공물의 수용가능성	
1. 학설	
	①<긍정설> 법19조2항에 따라 공익 상호간 비교형량을 통
	해 수용이 가능하다고 본다. ②<부정설> 법19조2항의 특별
	한 필요는 명문규정 있는 경우만 해당하며 이미 공적 목적
	에 제공되고 있어 별도로 용도폐지가 필요하다고 본다.
2. 판례	
	①토지보상법 19조 규정에 의한 제한 이외에 수용의 대상
	이 되는 토지에 관하여 아무런 제한을 하지 아니하고 있으
	므로 지방문화재로 지정된 토지등도 수용대상이 될 수 있

	다. ②국유림법에서 정하는 절차와 방법에 따르지 아니한 채, 토지보상법에 따른 재결을 통해 요존국유림의 소유권이 나 사용권을 취득할 수 없다. ③헌법재판소는 공익 또는 수용권의 충돌문제를 해결하기 위한 규정으로 보다 더 중요한 공익사업을 위하여 특별한 필요가 있는 경우에 한하여 예외적으로 수용의 목적물이 될 수 있다고 판시하였다.
	3. 검토
	공물은 현재 공익 목적에 제공되고 있지만 보다 큰 공익 목적을 위해 다른 용도로 전환될 수 있어야 한다고 본다. 긍정설이 타당하다.
	V. 특별한 필요의 판단(비례의 원칙)
	특별한 필요는 행정목적과 행정수단 사이 비례성이 인정되어야 한다는 비례의 원칙에 따라 판단한다. B토지는 문화재 보호법상 보호구역으로 지정된 공물이지만, 이 사건 공원 사업의 공익성이 요구되는 점, 수용을 통하여 공원 사업을 진행할 수 있는 점, 공원사업의 공익이 더 큰 점 등을 보았을 때, 이 사건 공원 조성사업 시행을 위한 적합성, 필요성, 상당성 원칙이 인정되는바, 특별한 필요가 있다.
	VI. 사안의 해결

	甲은 공물인 이 사건 B토지를 이 사건 시설 조성사업의 시행을 위하여 수용할 수 있다.
	<물음 3> 15점
	I. 확장수용의 의의·취지
	특정 공익사업을 위한 필요 범위를 넘어서는 재산권 수용으로 최소침해 원칙의 예외이나 피수용자 권리보호 및 사업의 원활한 시행을 위해 인정된다.
	II. 유형
	1. 완전수용(토지보상법72조)
	완전수용이란 토지사용으로 인해 토지소유자가 받게 되는 현저한 장해에 갈음하여 수용보상을 가능하게 해 주는 제도이다. 완전수용은 '사용에 갈음하는 수용'이라고도 한다. 사업인정고시 후 ① 토지사용기간이 3년 이상인 경우, ② 토지사용으로 인하여 토지형질이 변경되는 경우, ③ 사용하려는 토지에 그 토지소유자의 건축물이 있는 경우 해당 토지소유자는 사업시행자에게 토지매수를 청구하거나 관할 토지수용위원회에 토지수용을 청구할 수 있다.
	2. 잔여지 수용(동법74조)
	①잔여지수용이란 동일한 토지소유자에게 속하는 수용 목적

	물인 일단의 토지 일부가 매수 또는 수용됨으로 인하여 잔여지를 종래 목적에 사용하는 것이 현저히 곤란한 때 토지소유자의 청구에 의해 사업시행자가 해당 토지의 전부를 매수하거나 관할 토지수용위원회가 수용하는 것을 말한다. ② '사용하는 것이 현저히 곤란한 때'라 함은 사회적·경제적으로 사용하는 것이 곤란하게 된 경우도 포함하며 ③시행령 39조1항에 의하면 잔여지가 대지로서 면적이 너무 작거나 부정형(不定形) 등의 사유로 건축물을 건축할 수 없거나 건축물의 건축이 현저히 곤란한 경우, 농지로서 농기계의 진입과 회전이 곤란할 정도로 폭이 좁고 길게 남거나 부정형 등의 사유로 영농이 현저히 곤란한 경우, 공익사업의 시행으로 교통이 두절되어 사용이나 경작이 불가능하게 된 경우, 위 규정과 유사한 정도로 잔여지를 종래의 목적대로 사용하는 것이 현저히 곤란하다고 인정되는 경우로 규정한다.
	3. 이전수용(동법75조)
	이전비 보상이 원칙이나 ① 건축물 등을 이전하기 어렵거나, 그 이전으로 인하여 건축물 등을 종래의 목적으로 사용할 수 없게 된 경우, ② 건축물 등의 이전비가 그 물건의 가격을 넘는 경우에 해당하는 경우에 사업시행자는 관할 토지수용위원회에 그 물건의 수용 재결을 신청할 수 있다.

4. 잔여건축물 수용(동법75조의2)

동일한 소유자에 속하는 일단의 건축물의 일부가 편입됨으로 인해 잔여건축물을 종래의 목적대로 사용하는 것이 현저히 곤란할 때 건축물 소유자의 청구에 의해 사업시행자가 해당 건축물의 전부를 매수하거나 관할 토지수용위원회가 수용하는 것이다. 사업완료일까지 청구해야 한다.

Ⅲ. 확장수용의 성질

1. 학설

사업시행자와 피수용자의 임의적 합의라는 <사법상 매매설>, 필요 최소한도를 넘어서고 피수용자의 청구에 의해 이루어지는 <공법상특별행위설>, 본질이 일반 공용수용과 같다는 <공용수용설>이 대립한다.

2. 판례

대법원은 잔여지수용청구권은 요건 구비 시 피수용자 청구에 의해 수용의 효과 발생하는 형성권성질 갖는다 판시하여 <공용수용설> 입장이다.

3. 검토

권리발생 원인이 공익사업 수행이라는 공권적 침해에 기인하므로 <공용수용설>이 타당하다.

IV. 확장수용재결의 불복	
1. 문제점	
	확장수용은 공용수용의 성질을 갖고, 확장수용청구권의 법적 성질은 공권으로서, 토지수용법 체계상 확장수용은 토지수용위원회의 재결에 의해 이루어진다. 따라서 확장수용 거부 시 이에 대한 불복은 토지보상법 83조 이의신청 및 85조 규정에 따르면 된다. 이때 항고소송을 제기하지 않고 보상금증감청구소송을 제기할 수 있는지 또 민사소송의 제기 가능한지 문제된다.
2. 이의신청(동법83조)	
	법34조 재결에 이의 있는 자 재결서正本 송달일로 30일내 청구가능하다.
3. 행정소송 형태(동법 85조2항 보상금증감청구소송)	
	①<학설> 보상금증감청구소송 심리범위는 보상금액에만 한정된다는 <항고소송설>, 잔여지수용도 궁극적으로는 보상액의 증감에 관한 것이라는 <보상금증감청구소송설>이 대립한다. ②<판례> 잔여지수용청구권은 <손실보상의 일환으로 형성권적 성질>을 가지므로, 잔여지수용청구를 받아들이지 아니한 토지수용위원회의 재결에 대하여 토지소유자가 불복하여 제기하는 소송은 토지보상법 85조 2항에 규정되

어 있는 <보상금증감에 관한 소송>에 해당하여 <사업시행자를 피고>로 하여야 한다고 판시하였다. ③<검토> 잔여지 수용청구권이 형성권인 점, 분쟁의 일회적 해결이라는 보상금증감청구소송 취지, 판례의 입장 종합 고려할 때 <보상금증감청구소송>로 다투는 것이 타당하다.

<끝>

[문제2] 30점

I. 공익사업 준비의 의의·취지 및 근거

공익사업 준비란 공익사업을 위해 조사·측량 및 장애물의 제거 등을 하는 일련의 준비행위로서 타인토지에 출입하여 조사·측량 및 장애물의 제거 등에 관한 일련의 행위를 말한다. 원활한 공익사업 준비에 취지가 있다. 공익사업의 준비는 헌법 23조3항, 37조2항과 토지보상법 9조 내지 13조에서 법적 근거를 구할 수 있다.

II. 타인토지 출입(토지보상법9조)

1. 의의

사업시행자는 공익사업을 준비하기 위하여 타인이 점유하는 토지에 출입하여 측량하거나 조사할 수 있다(제9조 제1항). 행정조사행위이다.

2. 법적성질

①출입의 허가는 공용사용권의 설정으로서 성질을 갖는 행정처분이다. 견해가 대립하나, 타인의 토지에 출입할 수 있는 권리를 부여한다는 점에서 강학상 특허, 재량행위로 보아야 할 것이다. ②출입 측량·조사 행위 자체는 비권력적 사실행위이나, 토지보상법상 토지점유자의 인용의무(제11조)가 부과되므로, 사실행위와 수인하명이 결합된 합성행위로서 권력적 사실행위에 해당하고, 처분성이 인정된다.

3. 요건 및 절차

사업시행자는 타인토지에 출입, 측량·조사하려면 특별자치도지사, 시장·군수 또는 구청장의 허가를 받거나 통지하여야 한다(제9조 제2항). 사업시행자는 출입하려는 날의 5일 전까지 그 일시 및 장소를 특별자치도지사 등에게 통지하여야 하고, 특별자치도지사 등은 그 토지점유자에게 통지하여야 한다.

4. 효과

①사업시행자는 타인토지출입권, 손실보상의무, 반환 및 원상회복의무(48)가 발생한다.

②피수용자는 손실보상청구권(안 날로부터 1년/발생한 날로부터 3년), 인용의무(11), 인용의무 위반 시 200만원 이하

의 벌금(97)의 효과가 발생한다.

Ⅲ. 장해물의 제거 등(토지보상법12조)

1. 의의

장해물 제거란 측량·조사 시 부득이하게 장해물을 제거하고 토지의 시굴·시추를 해야 하는 경우를 말한다(제12조 제1항).

2. 법적성질

①장해물 제거 등을 위한 허가는 공용사용권의 설정으로서 성질을 갖는 행정처분이다. 견해가 대립하나, 장해물 등을 제거할 수 있는 권리를 부여하는 강학상 특허, 재량행위로 봄이 타당하다. ②장해물 제거행위는 명문 규정이 없다 하더라도, 타인토지 출입 시 인용의무를 준용함이 타당하다. 따라서 사실행위와 수인하명이 결합된 권력적 사실행위에 해당하고, 이는 처분성이 인정된다.

3. 요건 및 절차

사업시행자는 소유자 및 점유자의 동의를 얻어야 하고, 동의를 받지 못할 경우에는 사업시행자는 허가를 받아 장해물 제거 등을 할 수 있다(제12조 제1항).

4. 효과

①사업시행자는 장해물제거권, 손실보상의무, 반환·원상회복의무(48)가 발생한다. ②피수용자는 손실보상청구권(안 날로부터 1년/발생한 날로부터 3년), 인용의무가 발생한다.

IV. 권리구제

1. 사업시행자

①허가신청 거부: 허가는 처분으로 공권력 행사이고, 공익사업 진행 관련 권리행사에 중대한 지장을 미치며, 토지보상법 9조 및 12조에 의해 신청권이 있는 것으로 해석되는바, 허가신청 거부는 처분으로서 대상적격이 있다. 기타 소송요건 충족 시 항고소송, 항고 심판 등 가능하다. ②허가신청 부작위: 사업시행자에게 토지보상법 제9조 및 제12조에 의해 신청권이 있는 것으로 해석되고, 특별자치도지사 등에게 일정한 처분을 할 법률상 의무가 있는바, 의무이행심판과 부작위위법확인소송을 제기할 수 있다.

2. 토지소유자

1) 사전적 권리구제

출입 측량·조사 시 통지, 장해물 제거 시 통지, 장해물 제거 허가 시 소유자 및 점유자의 의견청취 등이 토지보상법에 규정되어 있다. 측량·조사와 장해물 제거 행위는 권력

	적 사실행위로서, 처분성이 인정되고, 토지소유자 및 점유자에게는 침익적 행위인 바, 예방적 금지소송과 가처분이 권리구제방법으로 논의될 수 있으나, 현행법상 인정되지 않고 있다.
	2) 사후적 권리구제
	①손실보상(9조4항~7항): 사업시행자는 타인토지출입하여 측량·조사함으로써 발생한 손실을 보상하여야 한다. 손실이 있는 것을 안 날부터 1년 손실이 발생한 날부터 3년 이내 청구해야 한다. ②행정쟁송: 타인토지출입 측량·조사행위, 장해물 제거행위는 권력적 사실행위로 처분성 있어 행정소송 대상적격 인정되나 협의소익 없을 가능성 높다. 재결전치 관련 견해대립이 있으나 판례는 재결절차를 거치지 않고 곧바로 사업시행자에게 손실보상을 청구할 수 없다고 하였다. 손실보상 재결에 대한 불복은 보상재결의 처분성 부정 시 공법상 당사자소송에 의할 것이나 처분성을 인정한다면 항고소송을 통한 구제가 가능하다. 토지보상법은 재결에 대한 불복규정을 두고 있는바 이의신청(83)과 행정소송(85)이 가능하다. ③위법한 조사와 사업인정: 위법한 행정조사에 기한 후속조치로 처분이 행해진 경우 적법절차 관점에서 행정조사의 위법을 이유로 후행처분의 취소를 구할 수 있다. ④손해배상 및 결과제거 청구권: 위법한 행정조사는 국가배상법

에 의해 손해배상청구가 가능하며 위법한 행정조사 결과로 위법한 상태가 계속되는 경우 결과제거청구권 행사가 가능하다.

V. 실력행사의 가부

1. 학설

① <긍정설> 제재규정을 둔 것은 피조사자의 수인의무 위반을 위법으로 보아 비례의 원칙 안에서 실력을 가할 수 있는 규정으로 볼 수 있다고 한다. ② <부정설> 토지보상법상 벌칙 규정만을 둔 취지는 조사의 실효성을 간접적으로 확보하려는 것으로서 실력행사는 허용되지 않는다고 한다.

2. 검토

국민의 신체나 재산에 대한 실력행사는 명문의 근거가 있어야 하므로 부정설이 타당하다.

VI. 위법한 측량조사에 따른 사업인정의 효력

1. 학설

① <적극설> 절차의 적법성 보장 원칙에 비추어 행정조사가 위법한 경우 당해 조사를 기초로 한 행정행위는 위법하다. ② <소극설> 행정조사는 법령에서 특히 행정행위의 전제조건으로 규정되어 있는 경우를 제외하고는 일응 별개의

제도로 볼 수 있어 조사의 위법이 바로 행정행위를 위법하게 하지는 않는다. ③<절충설> 행정조사와 행정처분은 하나의 과정을 구성하므로 적정절차 관점에서 행정조사에 중대한 위법사유가 있으면 그에 기초한 행정행위도 위법한 것으로 볼 수 있다.

2. 판례

판례는 위법한 세무조사에 기초한 부가가치세 부과처분은 위법하다고 하여 적극설을 취하고 있다. 다만, 행정조사 절차하자가 경미한 경우에는 위법사유가 되지 않는 것으로 본다.

3. 검토

사업인정에 필요한 정보를 수집하기 위해 행해진 측량·조사가 위법한 경우 당해 행정행위의 절차하자가 있는 것으로 볼 수 있다. 따라서 이 경우 사업인정의 효력은 절차 하자의 문제가 될 것이다.

<끝>

[문제3] 20점

I. 공용수용의 의의·취지 및 근거

①공용수용(公用收用)이란 특정한 공익사업을 위해 사업주체가 국가권력으로 타인의 재산권을 강제적으로 취득하는 것을 말한다. ②공용수용제도는 공익사업을 위해 권리자의 의사에 관계없이 토지소유권 등을 강제적으로 취득하는 길을 열어두기 위해 마련된 제도이다. ③현대복지국가의 공공복리 증진 등 이론적 근거로 헌법23조3항과 토지보상법 등 개별법에 근거를 둔다.

II. 공용수용의 요건(헌법23조3항)

1. 공용수용의 당사자

공용수용의 당사자는 공용수용 법률관계의 당사자로서, 수용권 주체인 수용권자와 수용목적물에 대한 권리를 가진 피수용자이다.

2. 공용수용의 내용상 요건

헌법 제23조 제3항에 따라 공공필요가 있을 것, 재산권에 대한 공권적 침해일 것, 재산권 침해의 법적 근거가 있을 것, 특별한 희생이 발생할 것, 보상규정이 존재할 것이 그 요건이 된다.

3. 공용수용의 절차상 요건

공용수용에 따른 토지의 취득 및 보상에 관한 일반법적 지

	위에 있는 토지보상법은 사업인정 전 협의(제16조), 사업인정(제20조), 토지조서 및 물건조서의 작성(제27조), 협의(제26조), 수용재결(제34조)로 이어지는 일련의 공용수용의 절차를 규정하고 있다.
	Ⅲ. 공용수용과 공공필요
	1. 헌법23조 3항의 공공필요
	①공공필요는 대표적 불확정 개념으로 현대복지국가이념에 따라 확대화 경향이 있다. ②헌법 제23조 제3항에 따라 재산권에 대한 공권적 침해는 공공필요가 있을 때만 행해질 수 있으므로, 공공필요는 공용침해의 실질적 허용요건이자 본질적 제약요소이다.
	2. 토지보상법 제4조 및 별표, 제4조의2 수용적격사업
	토지보상법은 공공필요가 있는 사업을 수용적격사업으로 규정하고 있다(제4조 및 별표, 제4조의2). 사업의 공공성을 확보하기 위해 사업인정 발령 시 실질적 공공필요가 있는지 판단한다.
	3. 공공필요의 판단기준
	공공필요는 공용침해를 통하여 얻어지는 공익과 재산권자의 재산권 보유이익 간에 이익형량을 통해서 그 여부가 결정되

고, 그 입증책임은 사업시행자에게 있다.

4. 수용에 있어 공공필요의 확대 경향

최근 민간의 이윤, 동기까지 포함하는 시설의 설치 등을 목적으로 하는 사업에 대하여도 점차 공공필요를 인정하기에 이르고 있어 '공공의 이익'이란 관념은 확대현상을 보이고 있다.

IV. 최근 공용수용제도의 동향

①토지보상법 4조 및 동조 8조 규정으로 공익사업의 확대 현상을 반영하고, 동법 4조의3과 21조 등으로 보건데, 공익성 검증을 강화하였다. ②민자유치사업 확대 현상, 토지보상법상 사업주체 구분 없이 공익사업시행자에게 수용권을 부여하는 등 공공적 사용수용의 확대화 경향을 보인다. ③보상금에서 개발이익을 배제하는 제도적 장치가 일반화되고 있고, ④정당보상과 생활보상의 확대 경향을 보인다.

<끝>

[문제4] 10점

I. 사적 공용수용의 의의·취지

공공적 사용수용(사적 공용수용, 사용수용)이란 특정한 공익

	사업을 위하여 사적 주체가 타인의 특정 재산권을 법률의 힘에 의해 보상을 조건으로 강제적으로 취득하는 것이다. 민간활력의 도입, 사업의 확대 등에 취지가 있다.
	Ⅱ. 사적 공용수용의 요건(헌법23조3항)
	① 공공적 사용수용은 공익사업의 목적에만 인정된다. ② 사적 주체로서 국가권력에 의해 수용권을 부여받는다. ③ 대상은 특정한 재산권이다. ④ 법률에 근거하여 타인의 재산권을 강제적으로 취득한다. 강제적 취득이란 권리자의 의사에 상관없이 일방적으로 재산권을 취득하는 것을 말한다. ⑤ 공공적 사용수용은 공용수용과 마찬가지로 재산권자에게 특별한 희생을 발생시키므로, 정당한 보상을 지급하여야 한다.
	Ⅲ. 사적 공용수용 인정여부
	1. 독일의 논의
	독일에서는 일반 사기업도 공익을 위해 수용이 허용된다고 보는 것이 일반적이다. 독일법상의 사기업의 유형으로는 생존배려형 사기업과 경제적 사기업이 있다. 생존배려형 사기업은 공공재화 등의 공익사업을 수행하는 경우의 국민의 생존을 배려하는 급부행정작용을 수행하는 사기업이고, 경제적 사기업은 공공성보다는 이윤추구를 우선적 목적으로 하

는 사기업이다. 생존배려형 사기업의 공익사업은 국가적 과제이므로 사기업에게 수용권한을 부여하는 것은 당연하다. 그러나 경제적 사기업에 대해서는 엄격한 요건 아래에서 허용해야 한다는 주장이 있으나, 오늘날 경제적 사기업은 경제구조 개선·고용 증진·지역 발전 등이라는 공익이 합리적으로 요구될 때 공익사업을 수행하므로, 경제적 사기업의 재산권 침해는 공익적 요청에 의한 것이라면 정당화될 수 있다고 봄이 일반적 입장이다.

2. 판례 및 검토

<대법원>은 어떤 사업이 공익사업인가의 여부는 그 사업자체의 성질에 의하여 정할 것이고, 사업주체의 여하에 의하여 정할 것이 아니라고 판시한 바 있다. <헌법재판소>도 관광진흥법 위헌소원사건에서 재산권의 수용의 주체를 한정하지 않고 있는바 합헌 판결을 하였다. <검토>생각건대, 오늘날 현대복지국가의 실현을 위하여 공익사업이 증가함에 따라 사적주체에게 수용권을 부여할 필요성이 커지는바, 엄격한 요건 하에 사용·수용을 인정할 필요가 있다.

IV. 계속적 공익실현의 보장책

① 공공적 사용수용의 사적 주체는 이윤추구의 목적도 함께 가지고 있으므로 언제든지 사업을 중도에 포기할 가능성이

있어 보장책이 필요하다. ②토지보상법상 환매권 및 사업인정의 실효제도나 ③개별법상 사업시행자에 대한 감독명령과 처분이나 행정쟁송, 위헌법률심판 등 입법·사법적 통제 등 여러 보장수단이 규정되어 있으나 추상적이고 제한적이어서 실효성 있는 수단으로 개괄적 규정이 마련되어야 할 것이다.

<이하여백>

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
3교시	100분	③ 감정평가법규
수험번호		성 명

【문제 1】 국토부장관은 2013. 11. 18. 사업시행자를 'A공사'로, 사업시행지를 'X시 일대 8,958,000m²'로, 사업시행기간을 '2013. 11.부터 2017. 12. 까지'로 하는 '◇◇공구사업'에 대해서「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 사업인정을 고시하였고, 사업시행기간은 이후 '2020. 12.까지'로 연장되었다, 甲은 ㉠토지 78,373m²와 ㉡토지 2,334m²를 소유하고 있는데, ㉠토지의 전부와 ㉡토지의 일부가 사업시행지에 포함되어 있다. 종래 甲은 ㉠토지에서 하우스 딸기농사를 지어 왔고, ㉡토지에서는 농작물직거래판매장을 운영하여 왔다. 甲과 A공사는 사업시행지 내의 토지에 대해「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률(이하 토지보상법)」에 따른 협의 매수를 하기 위한 협의를 시작하였다. 다음 물음에 답하시오.(아래의 물음은 각 별개의 상황임)(40점)

물음 1) 토지보상법상 사업인정 전 협의 취득 절차에 대해 설명하시오. (10점)

물음 2) 토지보상법상 사업인정 전 협의와 사업인정 후 협의를 비교하라. (10점)

물음 3) 토지보상법상의 사업인정과 사업인정고시의 법적 성질에 관하여 설명하시오. (10점)

물음 4) 토지보상법상 사업인정고시의 효과에 대해 설명하시오. (10점)

<공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 (약칭: 토지보상법)>

제16조(협의) 사업시행자는 토지등에 대한 보상에 관하여 토지소유자 및 관계인과 성실하게 협의하여야 하며, 협의의 절차 및 방법 등 협의에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

[전문개정 2011. 8. 4.]

제26조(협의 등 절차의 준용) ① 제20조에 따른 사업인정을 받은 사업시행자는 토지조서 및 물건조서의 작성, 보상계획의 공고·통지 및 열람, 보상액의 산정과 토지소유자 및 관계인과의 협의 절차를 거쳐야 한다. 이 경우 제14조부터 제16조까지 및 제68조를 준용한다.

② 사업인정 이전에 제14조부터 제16조까지 및 제68조에 따른 절차를 거쳤으나 협의가 성립되지 아니하고 제20조에 따른 사업인정을 받은 사업으로서 토지조서 및 물건조서의 내용에 변동이 없을 때에는 제1항에도 불구하고 제14조부터 제16조까지의 절차를 거치지 아니할 수 있다. 다만, 사업시행자나 토지소유자 및 관계인이 제16조에 따른 협의를 요구할 때에는 협의하여야 한다.

[전문개정 2011. 8. 4.]

제20조(사업인정) ① 사업시행자는 제19조에 따라 토지등을 수용하거나 사용하려면 대통령령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관의 사업인정을 받아야 한다. <개정 2013. 3. 23.>

② 제1항에 따른 사업인정을 신청하려는 자는 국토교통부령으로 정하는 수수료를 내야 한다. <개정 2013. 3. 23.>

[전문개정 2011. 8. 4.]

제22조(사업인정의 고시) ① 국토교통부장관은 제20조에 따른 사업인정을 하였을 때에는 지체 없이 그 뜻을 사업시행자, 토지소유자 및 관계인, 관계 시·도지사에게 통지하고 사업시행자의 성명이나 명칭, 사업의 종류, 사업지역 및 수용하거나 사용할 토지의 세목을 관보에 고시하여야 한다. <개정 2013. 3. 23.>

② 제1항에 따라 사업인정의 사실을 통지받은 시·도지사(특별자치도지사는 제외한다)는 관계 시장·군수 및 구청장에게 이를 통지하여야 한다.

③ 사업인정은 제1항에 따라 고시한 날부터 그 효력이 발생한다.

[전문개정 2011. 8. 4.]

【문제 2】 (1) 특수전사령부 및 제3공수특전여단 이전사업의 사업부지에 속하는 이천시 (주소 생략) 전 1,319㎡(이하 '이 사건 토지'라 한다)에 관하여는 2009. 8. 6. 사업시행자인 한국토지주택공사와 그 소유권보존등기 명의인인 피고보조참가인(이하 '참가인'이라 한다) 사이에 토지보상법에 따른 토지 취득에 관한 협의가 성립되었다.

(2) 한국토지주택공사는 토지보상법 제29조 제3항에 따라 이 사건 토지의 등기부상 소유명의인인 참가인의 동의를 받고 한국토지주택공사와 참가인 사이의 매매계약서, 협의성립확인신청 동의서, 토지조서 및 보상금지급서류 등에 공증을 받아 피고(중앙토지수용위원회)에게 이 사건 토지에 관한 협의 성립의 확인을 신청하였고 피고는 2015. 3. 26. 이를 수리하였다(이하 '이 사건 처분'이라 한다).

(3) 한편 이 사건 토지에 관한 농지분배 관련 서류들, 즉 분배대상 농지를 확인하는 농지분배부, 상환에 필요한 사항을 기재하는 상환대장, 농지를 국가에 매수당한 지주가 보상을 받는 과정에서 작성된 보상신청서, 지주신고서, 지가사정조서에는 '서울특별시 ○○동' 또는 '서울특별시 중구 ○○동△△'에 주소를 둔 소외인이 그 소유자로 기재되어 있고, 한자부책식 구 토지대장에는 '서울특별시 □□□□가'에 주소를 둔 소외인이 이 사건 토지를 사정받았다고 기재되어 있다. 원고의 부(父)인 소외인의 본적지는 '서울특별시 중구 □□□□가◇◇'이고, 소외인은 '서울특별시 중구 ○○동△△'에서 사망하였다. (즉, 원고는 진정한 소유자의 상속인이다)

다음 물음에 답하십시오. (30점)

물음 1) 협의성립확인의 절차에 대해 설명하십시오. (10점)

물음 2) 협의 성립 확인 신청에 필요한 동의 요건과 위 사안의 동의 흠결에 대해 설명하십시오. (5점)

물음 3) 동의에 흠결이 있는 협의성립확인 신청에 대해 토지수용위원회가 수리한 경우 그 수리의 위법성과 당해 수리를 항고소송으로 취소를 구할 수 있는지 설명하십시오. (15점)

<공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 (약칭: 토지보상법)>

제29조(협의 성립의 확인) ① 사업시행자와 토지소유자 및 관계인 간에 제26조에 따른 절차를 거쳐 협의가 성립되었을 때에는 사업시행자는 제28조제1항에 따른 재결 신청기간 이내에 해당 토지소유자 및 관계인의 동의를 받아 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할 토지수용위원회에 협의 성립의 확인을 신청할 수 있다.

② 제1항에 따른 협의 성립의 확인에 관하여는 제28조제2항, 제31조, 제32조, 제34조, 제35조, 제52조제7항, 제53조제5항, 제57조 및 제58조를 준용한다. <개정 2023. 4. 18.>

③ 사업시행자가 협의가 성립된 토지의 소재지·지번·지목 및 면적 등 대통령령으로 정하는 사항에 대하여 「공증인법」에 따른 공증을 받아 제1항에 따른 협의 성립의 확인을 신청하였을 때에는 관할 토지수용위원회가 이를 수리함으로써 협의 성립이 확인된 것으로 본다.

④ 제1항 및 제3항에 따른 확인은 이 법에 따른 재결로 보며, 사업시행자, 토지소유자 및 관계인은 그 확인된 협의의 성립이나 내용을 다툴 수 없다.

[전문개정 2011. 8. 4.]

【문제 3】 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률상 사업인정의 법적 성질과 권리구제에 대해 논한 뒤, 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률에 의한 사업인정의 실효제도를 설명하고, 이로 인하여 불이익을 받게 되는 피수용자에게 손실보상청구권이 있는지 설명하시오. (20점)

【문제 4】 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률(이하 토지보상법)상 천재지변 시의 토지의 사용(법 38조)과 시급한 토지 사용에 대한 허가(법 39조)를 비교하시오. (10점)

	[문제1] (40점)
	<물음1> (10점)
	I. 개설
	협약에 의한 취득의 절차는 토지·물건조서의 작성(제14조), 보상계획의 공고·열람 등(제15조), 보상액의 산정(제68조), 협의(제16조), 보상계약의 체결(제17조) 단계로 이루어져 있다.
	II. 토지조서 및 물건조서의 작성(토지보상법 14조)
	①토지조서 및 물건조서란 공익사업을 위해 취득 또는 사용할 토지와 그 토지상의 물건내용을 사업시행자가 일정한 절차를 거쳐 작성하는 문서이다. 조서작성은 당사자 간 분쟁소지를 미리 예방하고, 원활한 공익사업 시행에 취지가 있다. ②사업시행자는 토지조서와 물건조서를 작성하여 서명 또는 날인을 하고 토지소유자와 관계인의 서명 또는 날인을 받아야 하나 일정한 사유로 받을 수 없는 경우 그 사유를 적어야 한다.
	III. 보상계획의 공고 및 열람(토지보상법 15조)
	사업시행자는 토지조서와 물건조서를 작성하였을 때에는 일정한 내용이 포함된 보상계획을 전국을 보급지역으로 하는 일간신문에 공고하고, 토지소유자 및 관계인에게 각각 통지

	하여야 하며, 특별자치도지사, 시장·군수 또는 구청장에게
	도 통지하여야 한다. 이 때 그 내용을 14일 이상 일반인이
	열람할 수 있도록 하여야 한다. 토지물건조서 내용에 이의
	가 있는 토지소유자 등은 열람기간 내에 사업시행자에게 서
	면으로 이의를 제기할 수 있다.
	IV. 보상액의 산정(토지보상법 68조)
	①사업시행자는 보상액을 산정하려는 경우 감정평가법인등
	3인(감정평가법인등을 추천하지 아니하는 경우에는 2인)을
	선정하여 토지 등의 평가를 의뢰하여야 한다. ②사업시행자
	는 보상평가서를 검토한 결과 그 평가가 관계법령에 위반하
	여 평가되었거나 합리적 근거 없이 비교 대상이 되는 표준
	지의 공시지가와 현저하게 차이가 나는 등 부당하게 평가되
	었다고 인정하는 경우에는 당해 감정평가법인등에게 그 사
	유를 명시하여 다시 평가할 것을 요구하여야 한다.
	V. 협의와 계약체결(토지보상법 16조, 17조)
	①협의란 공익사업에 필요한 토지 등의 권리 취득 및 소멸
	등을 위해 행하는 사업시행자와 피수용자 간의 임의적 합의
	를 말한다(제16조). ②법적성질 관해 견해대립이 있으나 판
	례는 손실보상의 협의는 공공기관이 사경제주체로서 행하는
	사법상 계약의 실질을 가지는 것으로 본다. ③토지 등의 구

	체적 대상, 범위, 보상의 시기·방법·절차 및 금액 등이 협의의 내용이 되고(령 제8조 제1항), 계약의 내용에는 계약의 해지 또는 변경에 관한 사항과 이에 따르는 보상액의 환수 및 원상복구 등에 관한 사항이 포함되어야 한다(령 제8조 제4항). ④협의 성립 시 협의의 내용에 따른 사법상 계약의 효과가 발생한다. ⑤협의 불성립 시 사업시행자는 협의경위서를 작성하여 토지소유자 등의 서명 또는 날인을 받아야 하며 받을 수 없는 경우 그 사유를 기재하여야 한다. 사업시행자는 공익사업의 진행을 위해 국토교통부장관에게 사업인정을 신청할 수 있다.
	<물음2> (10점)
	I. 개설
	협의란 공익사업에 필요한 토지 등의 권리 취득 및 소멸 등을 위해 행하는 사업시행자와 피수용자 간의 임의적 합의를 말한다. 토지보상법상 사업인정 전 협의 취득(16조)과 사업인정 후 협의 취득(26조)을 규정한다. 이하 양자를 비교한다.
	II. 공통점
	1. 제도적 취지
	협이는 임의적 합의를 바탕으로 하여 최소 침해의 원칙을

	구현하고, 토지소유자 및 관계인에게 해당 사업의 취지를 이해시켜 신속하게 사업을 수행하고자 함에 그 취지가 있다.
	2. 협의의 내용(토지보상법 50조)
	협의할 내용은 토지·물건조서의 작성범위 내이고, 구체적 내용으로는 토지보상법 50조의 수용 또는 사용할 토지의 구역 및 사용방법, 손실보상, 수용 또는 사용의 개시일과 기간, 그 밖에 이법 및 다른 법률에서 규정한 사항 등이 있다.
	Ⅲ. 차이점
	1. 법적성질 및 권리구제 차이
	사업인정 전후 협의의 법적성질 관련 논의가 있으나 ①사업인정 전 협의는 다수설과 판례는 <사법상 계약>으로 보고, 사업인정 전 협의에 대해 다툼이 있는 경우 <민사소송>에 의한다. 반면, ②사업인정 후 협의에 대해 판례는 <사법상 계약>으로 보나, 다수설은 수용권 실행 방법의 하나로 <공법상 계약>으로 이해하고 있다. 다수설에 의할 경우 사업인정 후 협의에 대해 다툼이 있는 경우 <공법상 당사자소송>에 의하게 된다.
	2. 필수적 전치 여부

	사업인정 전 협의는 임의적 절차이나, 사업인정 후 협의는 필수적 절차이다. 토지보상법은 사업인정 전 협의는 사업시행자의 성실협회의무만을 규정하고 있지만, 사업인정 후 협의는 반드시 거칠 것을 의무로 규정하고 있다. 단지 절차의 중복을 피하기 위하여 사업인정 후 협의를 일정한 경우 하지 않을 수 있는 규정을 두고 있을 따름이다.
	3. 효과상 차이(확인제도 유무)
	①사업인정 전 협의는 협의성립확인 제도가 없으며, 사업인정 후 협의는 협의성립확인을 받으면 재결로 간주되는 규정이 있다. 이에 ②사업인정 전 협의 성립 시 승계취득으로 보며, 사업인정 후 협의 성립 시 협의성립확인 받기 전엔 승계취득, 협의성립확인 후엔 재결로 간주하는바, 원시취득으로 본다. ③사업인정 전 협의 불성립 시 사업인정 신청을 시작으로 강제수용 절차를 진행할 수 있고, 사업인정 후 협의 불성립 시 사업시행자는 재결 신청을, 피수용자는 재결 신청청구를 할 수 있다.
	IV. 양자의 관계
	①<선후관계> 양 협의 간에는 사업인정 이전인지 이후인지에 따른 기본적인 선후관계가 존재한다. 그러나 구속력이 있는 것은 아니다. ②<생략 가능성> 사업인정 후 협의는

	원칙상 필수절차이지만 일정요건을 충족하면 생략할 수 있다.
	<물음3> (10점)
	I. 사업인정(토지보상법 20조)
	1. 의의 및 취지, 근거
	사업인정이란 공익사업을 토지 등을 수용하거나 사용할 사업으로 결정하는 것을 말한다(제2조 제7호). 사업인정은 당해 사업이 토지보상법 제4조에 해당함을 인정하고, 일정한 절차를 거칠 것을 조건으로 수용권을 설정하는 행위이다(제20조). 사업인정은 당해 사업이 공공성이 있는가를 개별·구체적으로 판단하여 피수용자의 권리를 보호하고, 이에 의해 수용 가능여부가 결정되는 수용절차의 제1단계로서, 수용행정의 적정화, 사전적 권리구제장치로서의 역할을 한다.
	2. 법적성질
	1) 행정쟁송법상 처분
	사업인정은 행정청이 구체적 사실에 대한 법 집행으로서 외부에 대하여 직접적 법적 효과를 발생시키는 권력적 행위인 공법행위이다. 사업인정이 있으면 수용할 목적물인 범위가 확정되는 등 토지소유자 등에게 일정한 구체적 법적 효과가 발생하므로, 강학상 행정행위이자, 행정쟁송법상 처분이다.

	2) 설권적 형성행위(특허)
	①사업시행자수용권설에 의거하여 사업시행자에게 토지를 수용할 수 있는 공익사업자의 법적 지위를 설정하여 주는 행위로 보는 <설권적 형성행위설>과 국가수용권설에 의거하여 단순히 특정 사업이 공용수용을 할 수 있는 사업에 해당하는 것을 확인하는 행위라는 <확인행위설>이 대립한다.
	②판례는 일정한 절차를 거칠 것을 조건으로 수용권을 설정하는 형성행위라 판시한 바 있다. ③사업인정은 특정 사업의 공익성 여부를 모든 사정을 참작하여 구체적으로 판단하여 수용권을 설정해주는 것으로 설권적 형성행위로 보는 것이 타당하다.
	3) 재량행위
	①<설권적 형성행위설>은 재량행위로 보고, <확인행위설>은 기속행위로 본다. ②<판례>는 사업의 공익성 여부는 모든 사항을 참작하여 구체적으로 판단해야 하므로 행정청의 재량에 속한다고 판시한 바 있다. ③<검토>토지보상법 20조 규정상 불분명하나 국토교통부장관이 사업인정 시 이해관계인의 의견청취를 거치고 중앙토지수용위원회의 공익성 검토를 거치는 바 재량행위로 봄이 타당하다.
	4) 제3자효 행정행위

	사업시행자에게는 수익적 효과를 제3자인 피수용자에게는 침익적 효과를 발생시키는 바 제3자효 행정행위이다.
	Ⅱ. 사업인정고시(토지보상법 22조)
	1. 의의
	사업인정고시란 사업인정 효과가 미치는 범위를 누구에게나 확인할 수 있도록 나타내는 절차이다.
	2. 법적성질
	1) 사업인정의 효력발생요건
	국토교통부장관은 사업인정을 하였을 때에는 지체 없이 그 뜻을 사업시행자, 토지소유자 및 관계인, 관계 시·도지사 에게 통지하고 사업시행자의 성명이나 명칭, 사업의 종류, 사 업지역 및 수용하거나 사용할 토지의 세목을 관보에 고시하 여야 한다(제22조 제1항). 사업인정의 사실을 통지받은 시· 도지사(특별자치도지사를 제외함)는 관계 시장·군수 및 구 청장에게 이를 통지하여야 한다(제22조 제2항). 사업인정은 고시한 날부터 그 효력이 발생한다(제22조 제3항). 사업인정 은 통지가 있었다 하더라도 고시가 없으면 효력이 발생되지 아니한다.
	2) 설권적 형성행위(특허) 여부

①사업인정고시는 특정한 사실을 알리는 행위로서 사업인정과 분리하여 준법률행위적 행정행위 중 통지로 보는 견해, ②사업인정과 사업인정고시를 통일적으로 파악하여 특허로 보는 견해가 있다. ③해당 논의는 불복과 관련하여 실익이 있는바 사업인정고시는 사업인정의 효력발생요건으로 사업인정과 사업인정고시를 통일적으로 특허로 봄이 타당하다.

<물음 4> (10점)

I. 사업인정고시(토지보상법 22조)

사업인정고시란 사업인정 효과가 미치는 범위를 누구에게나 확인할 수 있도록 나타내는 절차이다. 사업인정은 통지가 있었다 하더라도 고시가 없으면 효력이 발생되지 아니한다.

II. 사업인정고시의 효과

1. 토지수용권의 발생

사업인정이 고시됨으로써 사업시행자는 자기가 시행하는 공익사업을 위하여 일정한 절차를 거칠 것을 조건으로 목적물을 수용할 수 있는 권한이 부여된다.

2. 수용목적물의 확정

사업인정이 고시되면 수용 또는 사용할 토지의 범위가 특정

	된다. 사업시행자는 수용 또는 사용할 토지의 위치와 예정
	면적의 범위가 정해지면 그 범위 내에서 공익사업의 시행에
	따른 권리를 행사할 수 있고 현재 또는 장래의 권리자에게
	대항할 수 있다.
	3. 관계인의 범위 제한
	사업인정 고시가 있는 후 권리를 취득한 자는 기존 권리를
	승계한 자를 제외하고는 관계인에 포함되지 아니한다(제2조
	제5호). 사업인정고시가 있는 후 새로이 권리를 취득한 자
	는 관계인으로 인정되지 않기 때문에 보상금을 받을 수 없
	다. 관계인의 범위를 한정하는 것은 수용절차에 참여하는
	자를 제한함으로써 절차를 간소하게 하는 데 이바지한다.
	4. 토지 등의 보전의무
	사업인정고시가 된 후에는 누구든지 고시된 토지에 대하여
	사업에 지장을 줄 우려가 있는 형질의 변경이나, 제3조에
	규정된 물건을 손괴하거나 수거하는 행위를 하지 못한다(제
	25조 제1항). 사업인정고시가 된 후에 고시된 토지에 건축
	물의 건축·대수선, 공작물의 설치 또는 물건의 부가(附加)
	· 증치(增置)를 하려는 자는 특별자치도지사, 시장·군수 또
	는 구청장의 허가를 받아야 한다. 이 경우 특별자치도지사,
	시장·군수 또는 구청장은 미리 사업시행자의 의견을 들어

	야 한다(제25조 제2항). 이 규정을 위반하여 건축물의 건축 · 대수선, 공작물의 설치 또는 물건의 부가·증치를 한 토 지소유자 또는 관계인은 해당 건축물·공작물 또는 물건을 원상으로 회복하여야 하며 이에 관한 손실의 보상을 청구할 수 없다(제25조 제3항).
	5. 토지·물건조사권의 발생
	사업인정고시 후 사업시행자 또는 감정평가를 의뢰받은 감 정평가법인등은 조서작성이나 감정평가를 위하여 필요한 경 우 허가 없이도 해당 토지나 물건에 출입하여 측량하거나 조사할 수 있다. 이 경우 출입의 통지(제10조), 토지점유자 의 인용의무(제11조) 및 증표 등의 휴대 규정(제13조) 규정 을 준용한다(제27조 제1항).
	<끝>
	[문제2] 30점
	<물음1> 10점
	I. 논점의 정리
	협의성립확인은 재결절차를 준용하는 경우와 공증을 받아 신청하는 경우의 두 절차가 있는바, 이하 설명한다.

II. 의의, 취지	사업인정 후 협의 성립 시 사업시행자가 피수용자 동의를 얻거나 공증을 받아 관할 토지수용위원회에 협의성립확인을 받음으로써 재결로 간주하는 제도이다. 계약 불이행에 따른 분쟁예방 및 공익사업의 원활한 진행에 취지가 있다.
III. 법적성질	① 협의성립 확인을 받으면 재결로 간주되어 처분성이 인정된다는 점에서 형성적 행정행위로 보는 <형성적 행정행위설>와 법규정에 의해 특정한 사실등을 확인하는 준법률행위적 행정행위로서 확인행위라는 <확인행위설>, 법률관계의 존부를 증명하는 것이라는 <공증설>이 있다. ② 공법상 계약이 처분으로 전환되어 당사자에게 권리·의무 발생시키는바 <형성적 행정행위설>이 타당하다.
IV. 협의성립확인의 절차	1. 일반적 확인절차(토지보상법29조 1항; 재결절차 준용) 협의성립확인에 관해 재결절차 사항을 준용하고 있다. 즉, 사업시행자가 관할토지수용위원회에 확인 신청을 하고, 확인신청 내용의 공고·열람·의견제출, 토지수용위원회의 심리, 확인의 절차로 진행된다.

2. 공증에 의한 확인절차(동조 3항; 수리로써 협의 성립확인)

사업시행자가 협의가 성립된 토지의 소재지·지번·지목 및 면적 등 대통령령으로 정하는 사항에 대해 공증인법에 따른 공증을 받아 협의성립확인을 신청하였을 때 관할 토지수용위원회가 이를 수리함으로써 협의 성립이 확인된 것으로 본다(토지보상법 29조 3항). 협의성립확인신청서에는 토지소유자 및 관계인의 동의서를 첨부해야 한다(동법 시행령 13조).

<물음2> 5점

I. 토지보상법 29조 동의 요건과 동조 3항의 취지(판례)

토지보상법 제29조는 이를 위한 전제조건으로 협의 성립의 확인을 신청하기 위해서는 협의취득 내지 보상협의를 성립한 데에서 더 나아가 확인 신청에 대하여도 토지소유자 등이 동의할 것을 추가적 요건으로 정하고 있다. 특히 토지보상법 제29조 제3항은, 공증을 받아 협의 성립의 확인을 신청하는 경우에 공증에 의하여 협의 당사자의 자발적 합의를 전제로 한 협의의 진정 성립이 객관적으로 인정되었다고 보아, 토지보상법상 재결절차 없이 관할 토지수용위원회의 수리만으로 협의 성립이 확인된 것으로 간주함으로써, 사업시행자의 원활한 공익사업 수행, 토지수용위원회의 업무 간소화, 토지소유자 등의 간편하고 신속한 이익실현을 도모하고 있다.

II. 동의요건; 진정한 소유자와 진정한 합의(판례)	
	간이한 절차만을 거치는 협의 성립의 확인에, 원시취득의 강력한 효력을 부여함과 동시에 사법상 매매계약과 달리 협의 당사자들이 사후적으로 그 성립과 내용을 다룰 수 없게 한 법적 정당성의 원천은 사업시행자와 토지소유자 등이 진정한 합의를 하였다는 데에 있다. 여기에 공증에 의한 협의 성립 확인 제도의 체계와 입법 취지, 그 요건 및 효과까지 보태어 보면, 토지보상법 제29조 제3항에 따른 협의 성립의 확인 신청에 필요한 동意的 주체인 토지소유자는 협의 대상이 되는 '토지의 진정한 소유자'를 의미한다.
	<물음3> 15점
I. 논점의 정리	
	동의 요건 흠결이 있는 협의성립확인 신청을 관할 토지수용위원회가 수리했을 경우 그 수리의 위법성 및 위법성 정도를 검토하고, 소송요건 검토를 통해 당해 수리가 항고소송으로 취소할 수 있는지 검토한다.
	II. 동의 흠결 있는 협의성립확인 신청 수리의 위법성
	사업시행자가 진정한 토지소유자의 동의를 받지 못한 채 단순히 등기부상 소유명의자의 동의만을 얻은 후 관련 사항에 대한 공증을 받아 토지보상법 제29조 제3항에 따라 협의

	성립의 확인을 신청하였음에도 토지수용위원회가 신청을 수리하였다면, 수리 행위는 다른 특별한 사정이 없는 한 토지보상법이 정한 소유자의 동의 요건을 갖추지 못한 것으로서 위법하다. 진정한 토지소유자의 동의가 없었던 이상, 진정한 토지소유자를 확정하는 데 사업시행자의 과실이 있었는지 여부와 무관하게 그 동의의 흠결은 위 수리 행위의 위법사유가 된다. 이에 따라 진정한 토지소유자는 수리 행위가 위법함을 주장하여 항고소송으로 취소를 구할 수 있다.
	Ⅲ. 위법성 정도(취소)
	①하자가 중대하면 무효라는 중대설, 중대하고 명백하면 무효라는 중대명백설, 보충적으로 명백성을 요구하는 명백성보충요건설 등이 있으나 ②통설판례는 중대명백설을 취하고 있다. ③행정의 법적 안정성과 국민의 권리구제의 요청을 적절히 조화시키는 중대명백설이 타당하며 동의 흠결이 있는 협의성립확인 신청의 수리는 그 하자가 중대하나 일견 명백하지 않아 취소정도의 하자이다.
	Ⅳ. 소송요건 검토
	1. 대상적격(행위요건적 신고의 '수리'로 처분)
	①토지보상법 29조 3항에 따라 '수리'함으로써 협의성립이 확인된 것으로 본다. ②이는 행정청이 수리를 하여야 비로

	소 법적 효과가 발생하므로, 행정청의 수리 또는 수리의 거부
	부는 준법률행위적 행정행위의 하나로서 행정소송법상의 처
	분의 개념에 해당한다.
	2. 원고적격 및 기타 소송요건
	진정한 소유자의 상속인인 원고는 처분의 당사자로 법률상
	이익이 있는바, 원고적격이 있으며, 협의소익, 제소기간 등
	그 외 소송요건은 특별한 문제가 없는 것으로 본다.
	V. 당해 수리를 항고소송으로 취소할 수 있는지(사안의 해결)
	사안의 '수리'는 처분으로 대상적격을 비롯한 소송요건을 충
	족하며, 취소정도의 하자를 갖는바, 당해 '수리'를 항고소송
	으로 취소를 구할 수 있다.
	<끝>
	[문제3] 20점
	I. 사업인정의 법적성질
	1. 사업인정의 의의, 취지, 근거(토지보상법 20조)
	사업인정이란 공익사업을 토지등을 수용하거나 사용할 사업
	으로 결정하는 것을 말한다. 공익사업을 통한 공공복리의
	증진 및 사전적 권리구제장치로서 그 취지가 있다.

2. 사업인정의 법적성질

① 행정쟁송법상 처분: 사업인정은 행정청이 구체적 사실에 대한 법집행으로서 외부에 대하여 직접적 법적 효과를 발생시키는 권력적 행위인 공법행위이다. ② 형성적 행정행위(설권적 형성행위): 학설은 <설권적 형성행위설>과 <확인행위설>이 대립하나, 판례는 일정한 절차를 거칠 것을 조건으로 수용권을 설정하는 형성행위라 판시한 바 있다. 생각건대, 사업인정은 특정 사업의 공익성 여부를 모든 사정을 참작하여 구체적으로 판단하여 수용권을 설정해주는 것으로 설권적 형성행위로 보는 것이 타당하다. ③ 재량행위: 토지보상법 20조 규정상 불분명하나 국토교통부장관이 사업인정 시 이해관계인의 의견청취를 거치고 중앙토지수용위원회의 공익성 검토를 거치는 바 재량행위로 봄이 타당하다. ④ 제3자효 행정행위: 사업시행자에게는 수익적 효과를 제3자인 피수용자에게는 침익적 효과를 발생시키는 바 제3자효 행정행위이다.

II. 사업인정의 권리구제

1. 피수용자

1) 사전적 권리구제

법21조 이해관계인 의견청취절차 규정이 있다. 예방적금지소송과 가처분을 고려해볼 수 있으나 판례는 부정하며 현행

	법상 인정되기 어려울 것이다.
	2) 사후적 권리구제
	①<위법한 사업인정> 행정쟁송에 관해 토지보상법에 규정이 없는 바 행정심판법과 행정소송법이 적용된다. 국가배상과 집행정지 및 결과제거청구권을 고려해볼 수 있다. ②<적법한 사업인정> 보상규정 있으면 손실보상을, 보상규정 없으면 나머지 손실보상요건 충족 시 헌법23조 효력논의(보상규정 흠결)를 통한 손실보상을 고려해볼 수 있다.
	2. 사업시행자
	1) 사업인정 거부
	<행정심판>에서는 의무이행심판과 거부처분취소심판이 가능할 것으로 보인다. <행정소송>거부가 처분이 되기 위한 요건을 갖추 경우 거부처분취소소송이 가능할 것으로 보인다. 요건 충족 시 국가배상청구도 가능할 것이다. 의무이행소송과 가구제도 고려해볼 수 있으나 판례는 부정하며 현행 법상 인정되기 어려울 것으로 보인다.
	2) 사업인정 부작위
	<행정심판>에서는 의무이행심판을, <행정소송>에서는 부작위위법확인소송이 가능하며 요건 충족 시 국가배상도 가

능할 것이다. 의무이행소송이나 가구제는 어려울 것이다.

Ⅲ. 토지보상법상 사업인정 실효제도(23조, 24조)

1. 개설

실효란 유효하게 성립한 행정행위가 객관적 사실의 발생으로 그 효력이 당연히 상실되는 것이다. 토지보상법상 실효 제도는 크게 사업인정의 실효와 재결의 실효로 볼 수 있다.

2. 사업인정의 실효

1) 재결신청 해태로 인한 실효(법23조)

사업시행자가 22조1항에 따른 사업인정의 고시가 된 날부터 1년 이내에 28조 1항에 따른 재결신청을 하지 아니한 경우에는 사업인정고시가 된 날부터 1년이 되는 날의 다음 날에 사업인정은 그 효력을 상실한다.

2) 사업의 폐지·변경으로 인한 실효(법24조)

사업인정고시가 된 후 사업의 전부 또는 일부를 폐지하거나 변경함으로 인하여 토지 등의 전부 또는 일부를 수용하거나 사용할 필요가 없게 되었을 때 사업시행자의 신고 또는 시도지사의 판단에 따른 고시로, 고시가 된 날부터 그 내용에 따라 사업인정의 전부 또는 일부는 효력을 상실한다.

IV. 사업인정 실효로 인한 손실보상(법9조5항~7항 준용)	
	사업인정의 효력이 상실되며 사업시행자는 사업인정이 실효됨으로 인하여 토지소유자나 관계인이 입은 손실을 보상하여야 한다(법23조2, 3항, 법24조 7, 8항). 손실의 보상은 사업시행자와 피수용자가 협의하여 결정하며 협의 불성립 시 사업시행자나 피수용자는 관할 토지수용위원회에 재결을 신청할 수 있다. 즉, 피수용자에게 손실보상청구권이 있으며 이는 손실이 있음을 안 날부터 1년, 발생한 날부터 3년 이내 청구해야 한다.
	<끝>
	[문제4] 10점
	I. 개설
	공용수용은 특정한 사유재산권의 강제적 취득을 바탕으로 하므로, 엄격한 절차에 의해 진행되어야 하나, 특별한 사유가 있는 경우는 절차 중 일부를 생략할 필요가 있다. 이에 토지보상법 38조 천재지변 시의 토지의 사용과 동법 39조 시급한 토지 사용에 대한 허가를 규정하고 있다.
	II. 공통점
	1. 규정 취지 천재지변이나 그 밖의 사변으로 공공의 안전을 유지하기 위

한 공익사업을 긴급히 시행할 필요가 있을 때나, 공익사업이 진행되는 동안 재결이 지연됨으로써 재해를 방지할 수 없거나 공공의 이익에 현저한 지장을 줄 우려가 있다고 인정되는 경우에는 일반적인 공익사업과는 달리 보통절차를 거칠 여유가 없는바, 원활한 사업진행을 도모하기 위해 약식절차를 규정한다.

2. 요건

양자 모두 관련 행정청으로부터 허가를 받고, 토지소유자 및 점유자에게 통지를 하여야 한다. 또한 공용사용의 경우만 허용한다.

3. 사용기간 및 효과

①양자 모두 보통절차를 거치는 경우보다 재산권 침해의 정도가 커 그 기간을 6개월 이내로 한정하여 재산권 침해를 최소화하고 있다. ②그 효과로 사업시행자의 공용사용권의 취득, 반환 및 원상회복의무, 대행·대집행정청구권 및 토지소유자의 권리행사의 제한, 목적물의 인도·이전의무, 손실보상 청구권 등의 효과가 발생한다.

4. 보상의 특징

토지보상법 62조 사전보상 원칙에 대한 예외로 사후보상의

	성격을 갖는다.
Ⅲ. 차이점	
1. 허가권자	
	천재지변 시 토지 사용(38조)의 경우 허가권자는 특별자치
	도지사 및 시군구청장이나 시급한 토지 사용(39조)의 경우
	사업인정 후 재결신청을 전제로 관할 토지수용위원회의 허
	가를 받아야 한다.
2. 담보물 제공 여부	
	천재지변 시의 토지의 사용(38조)의 경우 담보를 제공하지
	않으나, 시급한 토지 사용(39조)의 경우 대통령령으로 정하
	는 바에 따라 담보를 제공하게 한 후 해당 토지의 사용을
	허가받을 수 있다.
3. 보상금 지급절차	
	전자는 토지보상법 9조 5항 내지 7항을 준용하여, 그 손실
	에 대한 보상은 사업시행자와 손실을 입은 자가 협의하여
	결정하며 협의 불성립 시 관할 토지수용위원회에 재결을 신
	청할 수 있다. 반면 후자는 41조에 별도 보상규정이 있다.
	즉, 토지소유자의 보상청구가 있을 때 사업시행자가 산정한
	보상액을 지급하며 보상시기까지 지급하지 않은 경우 토지

소유자 등은 담보물을 취득할 수 있다.

4. 손실보상액에 대한 불복

전자의 경우 손실보상액에 대한 불복의 별도 규정이 없이 토지보상법 9조 5항 내지 7항 준용규정이 있다. 보상재결의 처분성 논의에 따라 처분성 인정 시 토지보상법 83조 이의 신청 및 85조 행정소송 제기가 가능하나, 처분성 부정 시 민사소송이나 당사자소송으로 불복할 수 있다. 후자의 경우 토지보상법 41조 별도 규정이 있으며 재결 전엔 사업시행자를 상대로 보상금 증액을 구하는 공법상 당사자 소송을 제기할 수 있고, 재결 후엔 재결의 불복절차를 적용할 수 있다.

<이하여백>

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
3교시	100분	③ 감정평가법규
수험번호		성 명

【문제 1】국토부장관은 2013. 11. 18. 사업시행자를 'A공사'로, 사업시행지를 'X시 일대 8,958,000㎡'로, 사업시행기간을 '2013. 11.부터 2017. 12. 까지'로 하는 '◇◇공구사업'에 대해서「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 사업인정을 고시하였고, 사업시행기간은 이후 '2020. 12.까지' 로 연장되었다. 사업시행지 내 피수용자 甲과 A공사는 사업시행지 내의 토지에 대해 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률(이하 토지보상법)」에 따른 협의 매수를 하기 위한 협의를 시작하였다. 다음 물음에 답하시오. (각 물음은 별개의 상황임) (30점)

물음 1) 사업인정 후 당사자 간 협의가 불성립한 경우 사업시행자와 피수용자가 할 수 있는 행위로, 토지보상법상 인정되는 절차를 설명하시오. (15점)

물음 2) 협의 과정에서 일부 지장물에 관하여 협의가 이루어지지 않아 甲이 A공사에게 재결신청을 청구했으나 A공사가 재결신청을 하지 않는 경우, 甲의 불복 방법에 관하여 검토하시오. (15점)

<참조조문>

공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 (약칭: 토지보상법)

제28조(재결의 신청) ① 제26조에 따른 협의가 성립되지 아니하거나 협의를 할 수 없을 때(제26조제2항 단서에 따른 협의 요구가 없을 때를 포함한다)에는 사업시행자는 사업인정고시가 된 날부터 1년 이내에 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할 토지수용위원회에 재결을 신청할 수 있다.

② 제1항에 따라 재결을 신청하는 자는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 수수료를 내야 한다. <개정 2013. 3. 23.>

[전문개정 2011. 8. 4.]

제30조(재결 신청의 청구) ① 사업인정고시가 된 후 협의가 성립되지 아니하였을 때에는 토지소유자와 관계인은 대통령령으로 정하는 바에 따라 서면으로 사업시행자에게 재결을 신청할 것을 청구할 수 있다.

② 사업시행자는 제1항에 따른 청구를 받았을 때에는 그 청구를 받은 날부터 60일 이내에 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할 토지수용위원회에 재결을 신청하여야 한다. 이 경우 수수료에 관하여는 제28조제2항을 준용한다.

③ 사업시행자가 제2항에 따른 기간을 넘겨서 재결을 신청하였을 때에는 그 지연된 기간에 대하여 「소송촉진 등에 관한 특례법」 제3조에 따른 법정 이율을 적용하여 산정한 금액을 관할 토지수용위원회에서 재결한 보상금에 가산(加算)하여 지급하여야 한다.

[전문개정 2011. 8. 4.]

【문제 2】甲은 A시의 관할구역 내 X토지를 소유하고 있다. 국토교통부장관은 A시를 국제관광특구로 발전시킬 목적으로 기업도시개발특별법이 정하는 바에 따라 X토지가 포함된 일단의 토지를 기업도시개발구역으로 지정하고, 개발사업시행자인 乙이 작성한 기업도시개발계획(동법 제14조 제2항에 따른 X토지 그 밖의 수용 대상이 되는 토지의 세부목록 포함. 이하 같다)을 승인·고시하였다. 乙은 협의취득에 관한 제반 절차를 준수하여 X토지에 대한 협의취득을 시도하였으나 甲이 응하지 않았다. 이에 乙은 X토지에 대한 수용재결을 신청하였고 중앙토지수용위원회는 그 신청에 따른 수용재결을 하였다. 甲은 수용재결 취소소송을 제기하면서, 乙이 기업도시개발계획승인 이후에 재정상황이 악화되어 수용재결 당시에 이르러 기업도시개발사업을 수행할 능력을 상실한 상태가 되었음에도 불구하고 수용재결을 한 위법이 있다고 주장한다. 토지보상법 34조 수용재결의 법적성질을 설명하고, 甲의 소송상 청구가 인용될 수 있는 가능성에 관하여 설명하시오. (단, 소송요건은 충족된 것으로 본다.) (30점)

<참조조문>

공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 (약칭: 토지보상법) 제34조(재결) ① 토지수용위원회의 재결은 서면으로 한다.

② 제1항에 따른 재결서에는 주문 및 그 이유와 재결일을 적고, 위원장 및 회의에 참석한 위원이 기명날인한 후 그 정본(正本)을 사업시행자, 토지소유자 및 관계인에게 송달하여야 한다.

[전문개정 2011. 8. 4.]

기업도시개발 특별법 (약칭: 기업도시법)

제14조(토지등의 수용·사용) ① 시행자는 개발구역에서 개발사업을 시행하기 위하여 필요할 때에는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제3조에 따른 토지·물건 또는 권리(이하 "토지등"이라 한다)를 수용 또는 사용(이하 "수용등"이라 한다)할 수 있다.

② 제1항을 적용하는 경우에 수용등의 대상이 되는 토지등의 세부 목록을 제11조제6항에 따라 고시한 때에는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제20조제1항 및 제22조에 따른 사업인정 및 사업인정의 고시가 있는 것으로 본다. <개정 2017. 10. 24.>

③ 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제28조에 따른 재결의 신청은 개발구역 토지면적의 100분의 50 이상에 해당하는 토지를

확보(토지소유권을 취득하거나 토지소유자로부터 사용동의를 받은 것을 말한다)한 후에 할 수 있다. 다만, 제10조제2항에 따라 공동으로 개발사업을 시행하는 경우에는 개발구역 토지면적의 100분의 50 이상에 해당하는 토지를 확보하기 전에도 재결의 신청을 할 수 있다.

④ 재결의 신청은 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제23조제1항 및 제28조제1항에도 불구하고 제11조제6항 본문에 따른 개발계획의 고시일부터 4년 이내에 할 수 있다. 다만, 대통령령으로 정하는 부득이한 사유가 있는 경우에는 국토교통부장관의 승인을 받아 그 기간을 2년 연장할 수 있다. <개정 2012. 1. 20., 2013. 3. 23., 2015. 6. 22., 2017. 10. 24.>

⑤ 제1항에 따른 토지등의 수용등에 관한 재결의 관할 토지수용위원회는 중앙토지수용위원회가 된다.

⑥ 시행자는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에서 정하는 바에 따라 개발사업의 시행에 필요한 토지등을 제공함으로써 인하여 생활의 근거를 상실하게 되는 자에 대하여 주거단지 등을 조성·공급하는 등 이주대책을 수립·시행하여야 한다.

⑦ 제6항에 따라 수립하는 이주대책에는 이주대상 주민과 협의하여 당초 토지등의 소유 상황과 생업 등을 고려하여 생활대책에 필요한 용지를 대체하여 공급하는 등 대통령령으로 정하는 사항이 포함되어야 한다.

⑧ 시행자는 토지등의 보상 및 이주대책에 관한 업무를 시장·군수에게 위탁할 수 있다. 이 경우 시장·군수는 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.

⑨ 제8항에 따라 토지등의 보상 및 이주대책에 관한 업무를 위탁받은 시장·군수는 위탁받은 업무를 직접 이행하기 어려운 경우에는 그 업무 중 일부를 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제81조제1항 제2호에서 정한 기관에 재위탁할 수 있다.

⑩ 제1항에 따른 토지등의 수용등에 관하여 이 법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」을 준용한다.

[전문개정 2011. 5. 30.]

【문제 3】토지보상법상 공탁제도에 대해 설명하고, 토지소유자가 이의신청 및 행정소송 제기 후 이의유보 없이 공탁금을 수령한 경우 묵시적 이의유보로 볼 수 있는지 논하시오. (20점)

【문제 4】A시는 시가지 철도이설사업을 시행하기 위하여 토지보상법 제16조에 따라 주택용지를 협의취득하면서 그에 따른 일체의 보상금을 B에게 지급하였고, B는 해당 주택을 자진철거하겠다고 약정하였다. 토지보상법89조 및 행정대집행법2조의 대집행 요건을 설명하고, B가 자진철거를 하지 않을 경우 B의 주택에 대하여 대집행을 할 수 있는지 판단하시오. (20점)

[문제1] (30점)

<물음 1> (15점)

I. 개설

토지보상법은 사업인정 후 협의 불성립 또는 불능 시 사업시행자에게는 재결신청권을, 토지소유자와 관계인에게는 재결신청청구권을 인정하고 있다.

II. 사업시행자의 재결신청권(토지보상법 28조)

1. 의의 및 근거

재결신청은 협의 불성립 시 사업시행자가 토지수용위원회에 수용 또는 사용의 재결을 구하는 절차 행위이다. 토지보상법 제28조에 근거를 둔다.

2. 요건 및 절차

① <재결신청권자> 재결신청권자는 오직 사업시행자 뿐이다. ② 재결은 협의 불성립 시 관할 토지수용위원회에 하며, 토지보상법상 사업인정고시일로부터 1년 이내에 할 수 있다. 재결신청의무는 반드시 해야 하는 의무는 아니다. 재결신청기간이 경과하면 사업인정의 효력도 상실되므로 재결신청의 근거도 없어진다. 다른 개별법에서 재결신청기간이 특별히 규정되어 있다면 그 기간을 따르면 된다. 사업시행자의 재결신청을 기각하는 재결이 확정되었다 하더라도 재결

신청기간의 제한규정에 저촉되지 않는 한 다시 재결신청을 할 수 있고, 토지수용위원회는 이에 근거하여 다시 수용재결을 할 수 있다.

3. 사업시행자에게만 재결신청권을 인정하는 이유

① 토지보상법 구조상 피수용자에게 재결신청권을 인정할 수 없고, ② 피수용자에게 재결신청권 부여 시 공익사업 계획에 지장이 생길 우려가 있으며, ③ 목적물 취득권과 보상 의무는 사업시행자에게 있는 점, ④ 형평차원에서 피수용자에게 재결신청청구권(토지보상법 제30조)이 인정되는 점 등을 고려할 때, 사업시행자에게만 재결신청권을 인정함이 타당하다.

Ⅲ. 피수용자의 재결신청청구권(토지보상법 30조)

1. 의의, 취지, 법적성질

① 재결신청청구권은 사업인정 후 협의가 성립되지 않을 경우 피수용자가 사업시행자에게 서면으로 재결신청을 조속히 할 것을 청구하는 권리이다. ② 수용의 법률관계의 조속한 확정을 통한 피수용자의 권익보호와 수용당사자간 공평의 원칙에 그 취지가 있다. ③ 재결 보상금에 부수하여 인정되는 공법상 청구권의 성질을 지닌다.

2. 요건, 내용, 형식, 청구기간

사업인정 후 협의 불성립 시, 협의기간 만료일 이후 사업인정고시일부터 1년 이내(재결신청기간 만료일)에 청구하여야 한다. 청구권자는 피수용자로 사업시행자에게 서면으로 청구한다. ①협의 불성립·불능 시, ②사업인정 후 상당 기간이 지나도록 사업시행자의 협의 통지가 없는 경우, ③협의 불성립이 명백한 경우에 협의기간 종료 전이라도 재결신청청구가 가능(판례)하다.

3. 효과

①사업시행자의 재결신청의무(법30조2항): 사업시행자는 재결신청청구 받은 날로 60일 내 관할 토지수용위원회에 재결을 신청하여야 한다. 판례는 협의 불성립이 명백한 경우 협의 기간 만료일부터 60일을 기산한다.

②사업시행자의 지연가산금 지급의무(법30조3항): <지연가산금지급> 청구 받은 날로 60일 초과하여 재결신청 시, 토지수용위원회의 재결보상금에 지연된 기간에 대해 법정이율을 적용한 금액(지연가산금)을 가산하여 지급하여야 한다. <협의불성립이 명백한 경우>는 협의기간 만료일이 60일의 기산점이다. <협의기간 종료 전 협의기간 연장된 경우>는 당초의 협의기간 만료일부터 기산하여야 한다.

<물음 2> (15점)

I. 논점의 정리

A공사의 재결신청을 하지 않은 것이 부작위에 해당하는지 검토 후 불복방법으로 의무이행심판, 부작위위법확인소송, 의무이행소송 등을 검토한다.

II. A공사의 부작위

1. 부작위의 의의 및 성립요건(행정소송법 2조1항2호)

부작위는 행정청이 당사자의 신청에 대해 상당한 기간 내 일정한 처분을 해야 할 법률상 의무가 있음에도 이를 하지 않는 것을 의미한다. 당사자의 신청, 상당한 기간, 일정한 처분을 할 법률상 의무, 무응답의 존재가 필요하다.

2. A공사의 재결신청 할 법률상 의무 존재

재결신청은 사업시행자의 공법행위로서 사실행위이나, 재결신청이 있어야 수용재결이 이루어지고, 수용재결이 토지수용위원회의 공권력행사이므로, 재결신청청구 거부 시 재결의 거부와 같은 결과를 가져올 수 있는 점, 사업인정이 실효되지 않는 한 피수용자에게 다른 구제방법이 없는 점 등을 고려하여 공권력행사로 봄이 타당하다. 따라서 사업시행자는 재결신청 청구를 받은 날로부터 60일 내 재결신청을 할 의무가 있으며, 이러한 의무는 토지보상법 제30조에 따

	른 일정한 처분을 할 법률상 의무에 해당한다. 또한, 판례에 따르면, 협의기간 중이라도 협의성립 가능성이 없음이 명백한 경우 피수용자는 재결신청 청구를 할 수 있으므로 甲의 재결신청 청구는 토지보상법령 및 판례에 부합하는 적법한 청구에 해당하므로, A공사는 재결신청을 해야 할 법률상 의무가 있다.
	3. 甲의 법규상 조리상 신청권
	위 신청권 요부에 대해 견해가 대립하나, 판례는 일반적 추상적 응답신청권으로 보아 필요하다고 본다. 판례의 태도가 타당하며, 甲에게는 토지보상법 30조1항의 신청권이 있다.
	4. 기타 부작위 성립요건
	나머지 당사자 신청, 상당한 기간, 무응답의 존재는 충족되므로, 사안의 A공사의 부작위는 행정소송법 2조1항2호에 해당한다.
	Ⅲ. 부작위위법확인소송(행정소송법 38조2항 등)
	부작위위법확인소송은 행정청의 부작위가 위법하다는 것을 확인하는 소송으로 행정청이 신청에 따른 일정 처분을 하여야 함에도 아무런 응답을 하지 않는 것이 위법하다는 확인을 구하는 소송이다. 대상적격 및 원고적격 등 소송요건을

갖춘 것으로 보이며, 소송의 심리범위에 관하여, 판례는 그 부작위가 위법하다는 것을 확인함으로써 행정청의 응답을 신속하게 하여 부작위 또는 무응답이라는 소극적인 위법상태를 제거하는 것을 목적으로 한다고 하여 절차적 심리설을 취하므로, 甲은 부작위위법확인소송으로 권리구제 가능하다.

IV. 의무이행심판 (행정심판법 5조3호)

의무이행심판이란 당사자의 신청에 대한 행정청의 위법 또는 부당한 거부처분이나 부작위에 대해 일정한 처분을 하도록 하는 행정심판을 의미한다. A공사는 재결신청할 법률상의 의무가 있으므로, 甲은 의무이행심판을 불복방법으로 고려할 수 있다.

V. 의무이행소송 등 가능성

법원의 판결에 의해 행정청으로 하여금 그 거부나 방치된 행정행위를 하여 줄 것을 구하는 내용의 행정소송으로 인정여부에 대해 부정설, 긍정설, 제한적 긍정설이 대립하나, 판례는 검사에게 압수물 환부를 이행하라는 청구는 행정소송법상 허용되지 아니한다고 하여 부정설의 입장이다. 생각건대, 현행 행정소송법 규정 아래에서는 의미이행소송은 인정된다고 보기 어려워 현실적인 불복방법으로 보기 어려우며, 장기적으로 입법으로 해결할 필요가 있다. 판례는 민사상

가처분 제도를 행정소송에 준용하지 않으므로, 위 제도 역시 현실적인 불복방법으로 보기 어렵다.

VI. 관련판례(거부처분취소소송이나 부작위위법확인소송)

판례는 토지소유자나 관계인의 재결신청 청구에도 불구하고 사업시행자가 재결신청을 하지 않을 때 토지소유자나 관계인은 사업시행자를 상대로 거부처분 취소소송 또는 부작위 위법확인소송의 방법으로 다투어야 한다고 판시한 바 있다. 사안의 재결신청을 하지 않은 것을 묵시적 거부처분으로 볼 경우, 취소소송의 방법으로 불복할 수 있다.

<끝>

[문제2] (30점)

I. 논점의 정리

사업시행자의 사업수행능력이 수용재결의 내용상 요건인지 판례 중심으로 검토하여 소송상 청구 인용가능성을 검토한다.

II. 수용재결의 법적성질

1. 의의 및 취지, 근거(토지보상법 34조, 50조)

수용재결은 사업인정고시 후 협의불성립·불능의 경우 사업시행자의 재결신청에 의해 관할 토지수용위원회가 행하는

수용 또는 사용결정의 최종적 판단절차이다(제34조, 제50조). 강제적 권력행사를 통해 공익을 실현하고, 엄격한 절차와 형식을 통해 공익과 사익을 조절하기 위한 제도로써 취지가 있다.

2. 형성적 행정행위

1) 학설

① <국가수용권설> 수용권의 주체는 국가이므로, 수용재결은 국가가 수용권을 행사하여 피수용자의 권리를 박탈하여 사업시행자에게 이전해 주는 행위로 본다. ② <사업시행자수용권설> 수용권의 주체는 사업시행자이므로, 수용재결은 사업시행자에게 부여된 수용권의 구체적 내용을 확정하고, 사업시행자와 피수용자간의 권리 취득 및 상실을 결정하는 형성적 행정행위라고 한다. 이 견해가 다수설이다.

2) 판례 및 검토

대법원은 수용재결은 일정한 법적 효과를 가져오는 처분으로서 행정행위의 성질을 갖는다고 하였다. 생각건대 사업시행자수용권설의 입장이 타당한 바, 수용재결은 수용권의 구체적 내용을 결정하고 권리취득 및 상실을 결정하는 형성적 행정행위로 봄이 타당하다.

3. 기속행위

사업시행자가 재결신청을 하면 관할 토지수용위원회는 형식적 요건이 미비되지 않는 한 재결을 해야 한다. 토지수용절차의 이분화, 사업인정의 성격 등에 비추어 토지수용위원회는 사업인정 자체를 무의미하게 하는, 즉 사업의 시행이 불가능하게 되는 것과 같은 재결을 행할 수 없는 점에서 재결의 발령 자체는 기속행위로 볼 수 있다.

4. 재량행위

토지보상법 제50조 제2항 단서에 따르면 손실보상금에 관하여 증액재결을 할 수 있는바, 위 부분은 재량권이 인정된다.

5. 제3자효 행정행위

수용재결은 사업시행자에게는 재산권 취득의 수익적 효과를 피수용자에게는 재산권 박탈의 침익적 효과를 부여하므로, 제3자효 행정행위이다.

6. 기타의 법적성질

토지수용위원회가 독립적 판단작용을 하므로, 준사법작용과 유사한 당사자심판의 성격, 시심적 쟁송의 성질을 갖고, 수용권자와 피수용권자를 대신하여 수용재결의 사항을 판단하

므로 공법상 대리의 성격도 갖고 있다.

Ⅲ. 수용재결의 요건

1. 주체(법49조) 및 형식(34조1항), 절차

토지등의 수용과 사용에 관한 재결을 하기 위하여 국토교통부에 중앙토지수용위원회를 두고, 특별시·광역시·도·특별자치도(이하 "시·도"라 한다)에 지방토지수용위원회를 둔다. 재결은 서면으로 하며, 사업인정 후 협의(법26조) 후 협의 불성립 혹은 불능 시 사업시행자의 재결신청(법28조), 열람(31조), 심리(32조) 등 일련의 절차를 거친다.

2. 내용

1) 재결서 기재내용(50조)

토지수용위원회의 재결사항은 <수용사용할 토지의 구역 및 사용방법><손실의 보상><수용사용의 개시일과 기간><그 밖에 이 법 및 다른 법률에서 정한 사항>이다.

2) 사업인정 요건이 수용재결 내용상 요건인지(판례)

판례의 견해에 의할 때 사업의 공익성, 사업시행자의 사업수행의 의사나 능력, 관련 이익 등의 형량내용 등을 판단하여 수용권을 행사하여야 한다.

IV. 판례

공용수용은 헌법상의 재산권 보장의 요청상 불가피한 최소한에 그쳐야 한다는 헌법 23조 근본취지에 비추어 볼 때 사업시행자가 사업인정을 받은 후 그 사업이 공용수용을 할 만한 공익성을 상실하거나 사업인정에 관련된 자들의 이익이 현저히 비례의 원칙에 어긋나게 된 경우 또는 사업시행자가 해당 공익사업을 수행할 의사나 능력을 상실하였음에도 여전히 그 사업인정에 기하여 수용권을 행사하는 것은 수용권의 공익 목적에 반하는 수용권의 남용에 해당하여 허용되지 않는다.

V. 사안해결(청구 인용가능성)

사안에서 사업시행자의 사업수행능력 상실에도 불구하고 수용권을 행사한 것은 수용권 남용에 해당하며, 통설판례인 중대명백설에 따를 때 내용상하자는 중대하나, 일견 명백하지 않는바, 취소사유에 해당한다. 수용재결은 위법하여 청구는 인용가능하다.

<끝>

[문제3] (20점)

I. 논점의 정리

공탁제도를 설명하고, 행정소송 제기 후 이의유보 없이 수

	령한 경우 행정소송을 묵시적 이의유보로 볼 수 있는지 판례를 중심으로 검토한다.
	Ⅱ. 토지보상법상 공탁제도(법40조)
	1. 의의 및 취지
	보상금의 공탁이란 일정한 사유가 있을 때 사업시행자가 보상금을 공탁함으로써 보상금 지급에 갈음하는 제도이다. 사전보상원칙의 관철 및 재결실효방지에 취지가 있다.
	2. 법적성질
	견해대립 있으나 근본 목적은 채무 이행으로 변제공탁으로 볼 수 있을 것이다. 다만, 사업시행자가 재결에 불복하여 보상금 차액을 공탁한 경우 일종의 담보공탁이라고 할 수 있다.
	3. 요건(법40조2항)
	①보상금 받을 자가 그 수령을 거부하거나 보상금을 수령할 수 없을 때 ②사업시행자의 과실 없이 보상금을 받을 자를 알 수 없을 때 ③관할 토지수용위원회가 재결한 보상금에 대하여 사업시행자가 불복할 때 ④압류나 가압류에 의하여 보상금의 지급이 금지되었을 때 사업시행자는 수용 또는 사용의 개시일까지 수용하거나 사용하려는 토지등의 소재지의

공탁소에 보상금을 공탁(供託)할 수 있다.

4. 공탁의 효과

①적법한 공탁은 사업시행자의 보상금지급의무가 소멸되고, 목적물 원시취득 등 공용수용의 효과가 발생한다. ②미공탁은 수용의 개시일까지 손실보상의무를 행하지 아니한 것으로 되어 재결은 실효된다(42조). 단, 이의재결에 의해 증액된 보상금은 공탁하지 않아도 이의재결은 실효되지 않는다.

③하자있는 공탁은 공탁요건에 해당하지 아니하는 공탁, 보상금 일부의 공탁, 조건부 공탁 등이 있는데, <법40조 2항 각 호의 어느 하나에 해당하지 않은 경우> 보상금 지급 효력이 발생하지 않는다. <보상금 일부 공탁>은 특별한 사정이 있는 경우를 제외하고 보상금 지급 효력 발생하지 않는다. <조건부 공탁>은 토지소유자 등이 그 조건을 수락하지 않는 한 공탁 전체가 무효로 된다. 수용개시일까지 공탁의 하자 미치유 시 수용재결은 실효된다(42조). ④공탁 하자의 치유는 보상금 일부 공탁이나 조건부 공탁은 무효가 되지만 그 공탁금을 토지소유자 또는 관계인 등 채권자가 수령하면 채권자가 일부 공탁이나 조건을 수락한 것이 되어 그 공탁은 공탁일에 소급하여 유효한 것으로 된다. 따라서 사업시행자가 조건을 붙여 공탁한 보상금이라도 이의 유보 없이 이를 수령하면 그 공탁은 유효하다(81누254).

5. 공탁금 수령의 효과

①적법한 공탁의 경우 판례는 이의유보 없이 공탁금 수령 시 재결에 승복한 것으로 보고 그 재결에 대한 이의는 부적법한 것으로 본다. 한편, 공탁금을 수령하면서 이의를 유보한 경우 수용사용개시일이 도과하더라도 수용법률관계는 종결되지 않는다. 판례는 이 경우에만 이의신청이 유효하다고 본다. ②하자있는 공탁은 이의유보 없이 수령 시 보상금 수령거부 의사 철회로 하자치유 인정되어 공탁의 효력은 유효하게 된다. 이의유보 후 수령 시 하자치유 인정되지 않아 공탁의 효력은 발생하지 못한다.

Ⅲ. 행정쟁송을 묵시적 이의유보로 볼 수 있는지

1. 학설

토지소유자가 쟁송제기를 하는 것은 공탁취지의 승인과 양립할 수 없다는 점에서 묵시적 이의유보로 보자는 견해 <긍정설>과 행정쟁송과 이의유보는 별개의 것이라고 보는 <부정설>이 있다.

2. 판례

<종전 판례>행정소송이 계속 중이라는 사실만으로 묵시적 이의유보로 볼 수 없다[90누6125]고 하였으나 <최근 판례>는 개별적 사실관계를 종합 고려하여 묵시적 이의유보로 본

바 있다.

3. 검토

재결된 보상금의 공탁을 변제공탁으로 보는 한 공탁금의 수령을 재결에 대한 승복으로 보아야 할 것이다. 그러나 공탁에 하자가 있는 경우 토지소유자 등은 이의신청이나 행정소송의 제기 자체를 이의의 유보를 한 것으로 볼 수 있으므로, 피수용자의 권리보호를 위하여 공탁금 수령 시 불복여부에 관한 사항을 확인하는 절차를 마련하여 불이익을 방지할 필요가 있다.

IV. 사안의 해결

토지소유자가 이의신청 및 행정소송 제기 후 이의유보 없이 공탁금을 수령한 경우 묵시적 이의유보로 볼 수 있다.

<끝>

[문제4] (20점)

I. 논점의 정리

B의 자진철거의무 불이행에 대한 대집행 가능성과 관련하여, 토지보상법 89조 및 행정대집행법 2조의 대집행 요건 충족여부가 문제된다.

	Ⅱ. 토지보상법 89조 및 행정대집행법 2조의 대집행 요건
	1. 토지보상법 89조 요건
	이 법 또는 이 법에 따른 처분으로 인한 의무를 이행하여야 할 자가 정해진 기간 내 의무를 이행하지 않거나 완료하기 어려운 경우 또는 그로 하여금 그 의무를 이행하게 하는 것이 현저히 공익을 해친다고 인정되는 사유가 있는 경우 사업시행자는 시장 등에게 행정대집행법이 정하는 바에 따라 대집행을 신청할 수 있다.
	2. 행정대집행법 2조 요건
	공법상의 대체적 작위의무의 불이행, 다른 수단으로써 그 이행확보가 곤란하고, 불이행 방치가 심히 공익을 해칠 것의 요건을 둔다.
	3. 양 법의 관계
	토지보상법 제89조는 행정대집행법이 정하는 바에 따른다고 규정하는바, 행정대집행의 요건을 충족하여야 대집행이 가능하다고 본다. 일부 견해는 토지보상법 제89조가 수용 토지나 건물의 인도 의무를 위한 특별 규정으로 보나, 판례는 대체적 작위의무에 해당하지 않는다고 보아 부정한다.
	Ⅲ. 공법상 의무 불이행 요건 충족 여부

1.	사업인정 전 협의취득의 법적성질
1)	학설
	사경제 주체로서 행하는 사법상 계약과 같다는 견해, 협의 불성립 시 공용수용 절차가 예정되어 있는 점에서 공법상 계약으로 보는 견해가 있다.
2)	판례 및 검토
	판례는 사법상 매매행위에 지나지 않는다고 본다. 생각건대, 공용수용의 보통절차 시작 이전에 이루어진 사법상 계약으로 봄이 타당하다.
2.	사안의 경우
	협의취득 및 자진철거 약정은 사법상 계약이므로, 공법상 의무 불이행 요건을 충족하지 않는다. 판례는 협의취득 시 건물소유자가 매매대상 건물에 대한 철거의무를 부담하겠다는 취지의 약정을 하였다고 하더라도 이러한 철거의무는 공법상의 의무가 될 수 없고, 이 경우에도 행정대집행법을 준용하여 대집행을 허용하는 별도의 규정이 없는 한 위와 같은 철거의무는 행정대집행법에 의한 대집행의 대상이 되지 않는다고 보았다.
IV.	이 법 또는 이 법에 따른 처분으로 인한 의무 불이행인지

토지보상법에는 사업인정 전 협의취득에 자진철거의무규정을 두지 않으므로, 위 요건도 충족하지 못한다. 다만, 철거는 타인이 대신할 수 있어 대체적 작위의무로 볼 수 있다.

V. 사안의 해결

공법상 의무 불이행 요건을 충족하지 못하므로, 대집행을 할 수 없다.

<이하여백>

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
3교시	100분	③ 감정평가법규
수험번호		성 명

【문제 1】 A대도시의 시장은 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따른 도시관리 계획으로 관할구역 내 oo동 일대 90,000㎡ 토지에 공영주차장과 자동차정류장을 설치하는 도시계획시설사업결정을 한 후 지방공기업법에 따른 A대도시 X지방공사(이하 'X공사'라 함)를 도시계획시설사업의 시행자로 지정하고, X공사가 작성한 실시계획에 대해 실시계획인가를 하고 이를 고시하였다. 이에 따라 공익 사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률(이하 '토지보상법'이라 함)에 의해 사업인정 및 고시가 이루어졌다. 한편, X공사는 사업대상구역 내에 위치한 20,000㎡ 토지를 소유한 甲과 토지수용을 위한 협의를 진행하였으나 협의를 성립되지 아니하여 관할 지방토지수용위원회에 토지수용의 재결을 신청하였다. 다음 물음에 답하시오. (40점)

물음 1) 甲은 수용 자체가 위법이라고 주장하면서 관할 지방토지수용위원회의 수용재결과 중앙토지수용위원회의 이의재결을 거친 후 취소소송을 제기하였다. 취소소송의 대상적격과 피고적격에 관하여 설명하시오. (20점)

물음 2) 甲은 자신의 토지에 대한 보상금이 적으며, 일부 지장물이 손실보상 대상에서 제외되었다는 이유로 관할 지방토지수용위원회의 수용재결에 불복하여 중앙토지수용위원회에 이의신청을 거쳤으나 기각재결을 받았다. 甲이 이에 대하여 불복하는 경우 적합한 소송 형태를 쓰고 이 소송의 의의와 그 특수성을 설명하시오. (20점)

【문제 2】甲은 2015. 3. 16. 乙로부터 A광역시 B구 소재 도로로 사용되고 있는 토지 200㎡(이하 '이 사건 토지'라 함)를 매수한 후 자신의 명의로 소유권 이전 등기를 하였다. 한편, 甲은 A광역시지방토지수용위원회에 "사업시행자인 B구청장이 도로개설공사를 시행하면서 사업인정고시가 된 2010. 4. 6. 이후 3년 이상 이 사건 토지를 사용하였다"고 주장하면서 「공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률」(이하 '토지보상법'이라 함) 제72조제1호를 근거로 이 사건 토지의 수용을 청구하였다. 이에 대해 A광역시지방토지수용위원회는 "사업인정고시가 된 날부터 1년 이내에 B구청장이 재결신청을 하지 아니하여 사업인정은 그 효력을 상실하였으므로 甲은 토지수용법 제72조제1호를 근거로 이 사건 토지의 수용을 청구할 수 없다"며 甲의 수용청구를 각하하는 재결을 하였다. 다음 물음에 답하시오. (30점)

- 1) A광역시지방토지수용위원회의 각하재결에 대하여 행정소송을 제기하기 전에 강구할 수 있는 甲의 권리구제수단에 관하여 설명하시오. (10점)
- 2) 甲이 A광역시 지방토지수용위원회의 각하재결에 대하여 행정소송을 제기 할 경우 그 소송의 형태와 피고적격에 관하여 설명하시오. (20점)

【문제 3】 甲은 A토지와 지상 건물 소유자로, 식당을 운영해왔는데, 그 전체 부지 중 일부가 도로건설 사업부지로 편입되었고, 이로 인해 A토지 형상의 변화 및 지상 건물의 가시성이 떨어지는 등, 그 가치하락손실이 발생하였다. 甲은 편입토지, 편입건물, 잔여지 가치하락손실에 대해 사업시행자와 협의하였으나 불성립으로 재결을 신청하였다. 甲은 여러 보상항목 중 잔여지 가치하락손실에 대해 관할 토지수용위원회에서 재결로 결정한 보상액에 불만족하여 행정소송을 청구하려 한다. 소송형태에 대해 설명하고, 사안의 소송에서 토지보상액이 과다하게 산정되어 잔여지 가치하락손실부분과 합산하여 보상금액을 결정한 것인지 등 보상 항목간 유용을 심리할 수 있는지 검토하시오. (20점)

【문제 4】 토지보상법 84조 이의재결에서 증액된 보상금에 대하여 지연이자가 발생하는지 논하시오. (10점)

[문제1] (40점)

<물음 1> (20점)

I. 논점의 정리

이의재결이 특별법상 행정심판의 성질을 가지는지 검토하고, 이를 거친 경우 취소소송의 대상이 무엇인지 관련하여 토지보상법 85조 1항이 원처분주의를 취하는지 검토하여 대상적격과 피고적격을 설명한다.

II. 관련 행정작용의 법적성질

①재결은 사업인정고시 후 협의불성립·불능의 경우 사업시행자의 재결신청에 의해 관할 토지수용위원회가 행하는 수용·사용결정의 최종적 판단절차이다(법34,50조). 재결은 처분으로, 형성적 행정행위에 해당하며, 형식적 요건이 미비되지 않는 한 재결을 해야 하는 점에서 기속행위의 성질을 가진다고 볼 수 있다. 판례도 수용재결의 처분성을 인정한다.

②이의재결은 수용재결의 위법, 부당을 이유로 그 시정을 구하는 절차이며, 판례는 특별법상 행정심판의 성격을 가진다고 보았다.

III. 원처부주의와 재결주의

원처분주의란 원처분과 재결을 모두 소송대상으로 하되, 원칙적으로 원처분에 대해서만 소송을 제기할 수 있고, 재결

	은 재결 자체에 고유한 위법이 있는 경우에 한해 소송을 제기할 수 있는 주의를 말하며, 이에 반해 재결주의란 재결에 대해서만 취소소송을 제기할 수 있도록 한 주의를 말한다. 이를 선택하는 것은 입법의 문제이며 행정소송법 19조는 원처분주의를 취한다.
IV. 토지보상법 85조 1항이 원처부주의를 취하는지	
	토지보상법 85조 1항은 '34조에 따른 재결(수용재결)에 불복할 때'라고 하여 취소소송의 대상을 수용재결로 분명히 하였다. 대법원 또한 원처분주의를 취한다고 본다.
V. 대상적격	
	이의재결을 거쳐 취소소송을 제기한 점에서, 이의재결은 기각재결로 보이고, 판례에 따르면 기각재결은 재결에 고유한 위법이 없으므로, 토지보상법 85조 1항에 의거, 원처분인 수용재결이 취소소송의 대상이 된다. 만약, 이의재결에 고유한 위법이 있다면, 이의재결도 취소소송 대상이 될 수 있다.
VI. 피고적격	
1. 피고적격 의의 및 근거	
	피고적격은 구체적인 소송에서 피고로서 소송을 수행하여 본안판결을 받을 수 있는 자격을 의미한다. 행정소송법 13

	조에 근거를 두고 있다. 이에 따르면, 취소소송은 처분등을 행한 행정청을 피고로 한다.
	2. 판례
	법83, 85가 이의신청을 임의절차로 규정한 점, 행정소송법 19조 단서가 행정심판에 대한 재결은 재결 자체에 고유한 위법이 있음을 이유로 하는 경우에 한하여 취소소송의 대상이라 한 점 종합고려 시 수용재결에 불복하여 취소소송을 제기하는 때에는 이의신청을 거친 경우에도 수용재결을 한 중앙토지수용위원회 또는 지방토지수용위원회를 피고로 하고 이의신청에 대한 재결 자체에 고유한 위법이 있을 때 이의재결을 한 중앙토지수용위원회를 피고로 한다.
	3. 사안의 경우
	취소소송의 대상인 수용재결을 행한 관할 지방토지수용위원회가 피고적격을 가진다. 만약, 이의재결에 고유한 위법이 있어 이의재결을 소의 대상으로 하는 경우라면 중앙토지수용위원회가 피고적격을 가진다.
	<물음 2> (20점)
	I. 논점의 정리
	토지보상법85조2항의 문언, 판례 태도에 비추어, 사안의 적

합한 소송이 보상금증감청구소송임을 설명한 후 이 소송의
의의와 특수성을 검토한다.

II. 적합한 소송형태

1. 토지보상법 85조2항 문언

행정소송이 보상금의 증감에 관한 소송이라면, 취소소송이
아니라 보상금증감청구소송에 의해야 한다고 규정하고 있
다.

2. 관련판례

대법원은 어떤 보상항목이 토지보상법령상 손실보상 대상에
해당함에도 관할 토지수용위원회가 사실을 오인하거나 법리
를 오해함으로써 손실보상대상에 해당하지 않는다고 잘못된
내용의 재결을 한 경우 보상금증감청구소송으로 다투어야
한다고 판시하였다.

3. 사안의 적합한 소송형태

甲은 토지의 보상금이 과소하다고 주장하고, 일부 지장물에
대해 손실보상대상이 된다고 주장하였는데, 이에 대해 토지
수용위원회가 기각결정을 하였다. 따라서 위 규정 및 판례
에 따를 때, 적합한 소송형태는 보상금증감청구소송이 된다.

	Ⅲ. 보상금증감청구소송의 의의, 법적근거, 취지
	보상금증감청구소송은 토지보상법 85조 2항에 근거하여 재결에서 결정된 손실보상금의 증감을 구하는 행정소송을 의미한다. 권리구제의 신속성, 일회적 해결 등에 취지가 있다.
	Ⅳ. 보상금증감청구소송의 특수성
	1. 형식적 당사자소송
	보상금증감청구소송은 행정청의 처분, 재결 등이 원인이 되어 형성된 법률관계에 다툼이 있는 경우 그 원인이 되는 재결의 효력을 직접 다투지 않고 법률관계의 한쪽 당사자를 피고로 하여 제기하는 형식적 당사자 소송에 해당한다.
	2. 확인·급부소송
	보상금과 관련된 권리를 형성한다는 형성소송이라는 견해가 있으나 실질적으로 보상액을 확인하고 부족액의 지급을 명한다는 점에서<확인·급부소송>으로 봄이 타당하다 판단되며 판례의 태도도 동일하다.
	3. 원처분주의 논의가 적용되는지
	이의재결을 거친 경우의 소송의 대상에 대해 견해가 대립하나, 보상금에 관한 법률관계를 보상금증감청구소송의 대상으로 보아야 하므로 원처분주의나 재결주의로 해석하는 것

은 타당하지 않다.

4. 제소기간의 특칙

당사자소송은 공법상 권리의무의 존속기간 내에서 소송을 제기할 수 있는 것이 원칙이다. 다만 토지보상법 85조2항 및 1항에서 34조 및 83조의 재결의 경우 재결서 정본을 송달 받은 날부터 각각 90일, 60일의 제소시간의 특칙을 규정하고 있다. 대법원은 토지수용위원회에서 재결이 있었다는 사실을 알리지 않는 경우 행정소송법 및 행정심판법의 일반규정이 적용된다고 한다.

5. 심리범위

①손실보상금의 지급방법 ②적정손실보상액의 범위 및 보상 관련 보상면적 ③지연손해금 ④잔여지수용 여부 ⑤개인별 보상으로서 과대·과소항목간 유용 등 심리한다.

<끝>

[문제2] (30점)

<물음1> (10점)

I. 논점의 정리

토지보상법 83조의 이의신청제도를 검토한다.

II. 이의신청의 의의 및 취지	이의신청이란 관할 토지수용위원회의 위법·부당한 재결에 이의가 있는자가 중앙토지수용위원회에 그 취소 또는 변경을 구하는 절차이다. 간편한 절차·방법에 의한 피수용자 권익보호에 취지가 있다. 토지보상법 83조에서 “~할 수 있다”고 규정하고 있으므로, 임의적 절차이다.
III. 이의신청의 법적성질(특별행정심판)	①강학상 이의신청은 별도의 행정심판을 거칠 수 있으나, 특별행정심판으로 볼 경우 행정심판법51조에서 재심판청구를 금지하는바 별도 행정심판 제기가 불가능하다는 점에 구별실익이 있다. 토지보상법 제83조의 이의신청은 ②강학상 이의신청이라는 견해가 있으나, 헌법107조3항에서 행정심판의 사법절차 준용을 규정하고 있고, 상급기관인 중앙토지수용위원회에 불복하는 점, 법85조에서 이의재결에 대해 행정소송을 제기할 수 있다는 점에서 <특별행정심판>으로 보는 것이 타당하다. 판례도 특별행정심판으로 본다. 따라서 토지보상법에 없는 규정은 행정심판법을 따른다.
IV. 제기요건 및 효력	재결에 이의가 있는 자는 재결서의 정본을 받은 날로부터 30일 이내에 문서로써 처분청을 경유하여 중앙토지수용위

	원회에 이의신청할 수 있다. 이의신청을 받은 중앙토지수용위원회는 재결의 전부 또는 일부를 취소하거나 보상액을 변경할 수 있다. 재결 확정 시 민사소송법상 확정판결이 있는 것으로 보며, 재결서 정본은 집행력 있는 판결의 정본과 동일한 효력을 갖는다(토지보상법 제86조).
	<물음 2> (20점)
	I. 논점의 정리
	확장수용의 법적성질과 이와 관련한 소송의 형태 및 피고격을 검토한다.
	II. 확장수용의 법적성질
	1. 확장수용과 완전수용
	확장수용은 공익사업을 위한 목적물의 필요최소한의 범위를 넘어 수용하는 것이다. 피수용자 권리구제 등을 위해 법률의 규정이 있을 때 예외적으로 인정되는 제도이다. 완전수용은 토지사용으로 인해 토지소유자가 받게 되는 손실에 갈음하여 수용을 가능하게 해주는 확장수용의 한 예이다.
	2. 확장수용의 법적성질
	확장수용을 사법상 매매로 보는 견해가 있으나, 피수용자의 청구를 요건으로 하는 일방적 권리취득이므로 그 본질은 공

	용수용과 같다고 보는 견해가 타당하며, 판례도 확장수용에 대한 다툼을 행정소송에 의하여야 한다고 본다.
	Ⅲ. 소송의 형태
	1. 학설
	취소소송설은 확장수용은 보상범위에 관련되는 문제라고 보며, 보상금증감청구소송설은 보상금액과 보상범위는 밀접한 관련이 있으며, 피수용자의 일회적 권리구제를 위해 보상금증감청구소송의 심리범위에 확장수용이 포함된다고 본다.
	2. 판례
	판례는 토지보상법 72조의 수용청구권도 토지보상법 74조 1항이 정한 잔여지 수용청구권과 같이 손실보상의 일환으로 토지소유자에게 부여되는 권리로서 그 청구에 의하여 수용효과가 생기는 형성권의 성질을 지니므로, 토지소유자의 수용청구를 받아들이지 아니한 재결에 대하여 불복하여 제기하는 소송은 토지보상법 85조2항에 규정되어 있는 보상금의 증감에 관한 소송에 해당한다고 보았다.
	3. 검토
	분쟁의 일회적 해결이라는 보상금증감청구소송의 취지를 고려할 때, 판례 입장이 타당하다.

IV. 피고적격

보상금증감청구소송은 형식적 당사자소송으로서 법률관계 당사자가 각각 원고와 피고가 된다. 사안의 경우 토지소유자 甲이 소송을 제기하였으므로, 토지보상법 85조 2항에 따라 사업시행자인 B구청장이 피고가 된다.

<끝>

[문제3] (20점)

I. 논점의 정리

보상금에 관한 다툼으로 보상금증감청구소송에 대해 설명하고, 심리범위에 보상항목간 유용 등이 포함되는지 판례 중심으로 검토한다.

II. 소송형태(토지보상법 85조2항 보상금증감청구소송)

1. 의의·취지

보상금증감청구소송은 보상금 증감의 다툼에 대하여 직접적 이해관계를 가진 당사자인 사업시행자와 토지소유자 및 관계인이 소송제기를 통해 직접 다투는 당사자소송이다. 보상금에 대한 분쟁을 일회적으로 해결하고, 권리구제의 신속성·실효성 확보에 취지가 있다.

2. 소송의 성질

1) 형식적 당사자소송

보상금증감청구소송은 법률관계 일방당사자를 피고로 하여 제기하나 실질은 재결이라는 처분에 대해 다투는 소송으로서 형식적 당사자소송이다. 종래에는 형식적 당사자소송인지에 대해 견해가 대립하였으나, 현행 토지보상법에서는 재결청을 공동피고에서 제외하여 형식적 당사자소송임을 명확히 하고 있다.

2) 확인·급부소송

재결을 취소하고 보상액을 결정하는 형성소송이라는 견해가 있으나, 실질적으로 정당 보상액을 확인하고 부족액의 지급을 명하므로 <확인·급부소송>으로 봄이 타당하다. 또한, 판례의 태도도 이와 같다.

3. 보상금증감청구소송 특수성

1) 소송의 대상(보상금을 둘러싼 법률관계)

보상금증감청구소송은 취소소송과 달리 처분 등으로 인해 형성된 법률관계를 소의 대상으로 한다. 즉, 보상금을 둘러싼 법률관계가 소의 대상이 된다.

2) 심리범위

	①손실보상금의 지급방법 ②적정손실보상액의 범위 및 보상 관련 보상면적 ③지연손해금 ④잔여지수용 여부 ⑤개인별 보상으로 과대·과소 항목 간 유용 등 심리한다.
	3)제소기간
	당사자소송은 원칙적으로 제소기간의 제한이 없으나 토지보 상법 85조 2항 문언상 동조 1항 취소소송의 제소기간을 보 상금증감청구소송에 적용함이 타당하다. 따라서 재결서 정 본 받은 날로 90일, 이의재결서 받은 날로 60일 이내 제기 해야 한다.
	4)판결의 효력 및 관련문제
	①법원이 직접 보상금을 결정하는바 소송당사자는 판결의 결과에 따라 이행하여야 하며 중앙토지수용위원회는 별도의 처분을 할 필요가 없다. ②취소소송에서 보상금증감청구소 송을 예비적으로 병합하여 제기할 수 있는가에 대해 분쟁의 일회적 해결을 위해 청구의 병합을 인정함이 타당하며 병합 의 형태는 <주위적·예비적 병합>의 형태가 적합하다.
	Ⅲ. 보상항목간 유용의 문제
	1. 학설
	①보상금증감청구소송에서 소송물은 토지필지별, 물건별,

	손실항목별로 나누어진다고 보아 그 상호간 유용을 허용하지 않는 견해, ②동일인에 대한 일단의 토지를 기준으로 하여 필지별 총액을 기준으로 하는 견해, ③개인별보상원칙에 따라 항목간 유용을 허용하여 보상금액을 결정해야 한다는 개인별 총액주의적 견해가 있다.
2. 판례	
	보상은 수용대상이 되는 물건별로 하는 것이 아니라 피보상자의 개인별로 행하여지는 것이므로, 피보상자는 수용대상 물건 중 일부에 대하여만 불복이 있는 경우 그 부분에 대하여만 불복의 사유를 주장하여 행정소송을 제기할 수 있다고 할 것이나, 행정소송의 대상이 된 물건 중 일부 항목에 관한 보상액이 과소하고 다른 항목의 보상액은 과다한 경우에는 그 항목 상호간의 유용을 허용하여 과다 부분과 과소 부분을 합산하여 보상금의 합계액을 결정하여야 한다.
3. 검토	
	개인별보상원칙에 비추어 볼 때, 보상금에 관한 항목별로 액수가 정해져 있다 하더라도 소송물을 개개 항목별로 구분하는 것이 아니라 전체를 불가분의 1개 소송물로 보기 때문에 개인별 총액으로서 보상액의 당부를 소송물로 보아 항목간 유용을 허용함이 타당하다.

IV.	사안의 해결
	甲이 청구할 소송의 형태는 보상금증감청구소송이고, 당해
	소송에서 보상항목간 유용을 허용함이 합리적이다.
	<끝>
	[문제4] (10점)
	I. 논점의 정리
	이의재결을 거친 후 보상금증감청구소송을 제기한 경우, 사
	업시행자가 이의재결에서 증액된 보상금을 공탁하지 않았다
	면 해당 부분에 대해 이자가 발생하는지가 문제된다.
	II. 이의재결(법84조) 및 이의재결의 효력(법86조)
	①재결이 위법·부당함이 인정될 때 재결의 전부 또는 일부
	를 취소하거나 보상액을 변경할 수 있다(법84조1항). ②보상
	금 증액 시 재결서 정본을 받은 날로 30일 내 사업시행자
	는 증액된 보상금 지급해야한다(법84조2항). ③쟁송기간 도
	과 등으로 이의재결이 확정된 경우에는 민사소송법상의 확
	정판결이 있는 것으로 보고, 재결서 정본은 집행력 있는 판
	결의 정본과 동일한 효력을 갖는 것으로 본다(법 86조 1항).
	따라서 민사소송의 제기 없이 강제집행이 가능하다.

Ⅲ.	이의재결 증액보상금 미지급시 이의재결의 실효 여부
	판례는 이의재결에서 증액된 보상금을 지급·공탁하지 않았다 하여 이의재결이 당연히 실효되는 것은 아니라는 입장을 취하고 있다. 토지보상법 제42조는 재결의 실효만을 규정하고 있으므로 이를 이의재결까지 확대적용하는 것은 타당하지 않으므로 이의재결에서 증액된 보상금을 지급·공탁하지 않았다고 하여 이의재결이 실효된다고 볼 수는 없을 것이다.
Ⅳ.	이의재결에 대한 지연이자 발생 논의
1.	학설
	① 이의재결에서 정한 보상액을 초과하는 부분만의 지급을 명하여야 한다는 견해가 있고, ② 이의재결에서 증액된 보상금이 공탁되지 않은 경우, 그 차액 역시 수용과 대가관계에 있는 손실보상의 일부이므로 동 차액이 수용의 개시일에 지급되지 않는 이상 지연이자 발생한다는 견해가 있다.
2.	판례
	대법원은 재결절차에서 정한 보상액과 행정소송 절차에서 정한 보상금액의 차액 역시 수용과 대가관계에 있는 손실보상의 일부이므로 동 차액이 수용의 시기에 지급되지 않은 이상 이에 대한 지연손해금이 발생하는 것은 당연하다고 판

시한바 있다.

3. 검토

토지보상법의 규정상 이의재결에서 증액된 보상금을 지급 또는 공탁하지 않는다고 하여 이의재결이 실효되는 규정을 따로 두고 있지는 않다. 그러므로 이의재결에서 늘어난 보상금을 공탁하지 않음으로서 피수용자에게 불이익이 발생되는 바, 피수용자의 권리보호를 중시하여 판례와 같이 지연이자가 발생한다고 보는 것이 타당하다.

<이하여백>

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
3교시	100분	③ 감정평가법규
수험번호		성 명

【문제 1】 D시는 도시관리계획결정에서 정해진 바에 따라 근린공원을 조성하기 위하여 그 사업에 필요한 토지들을 공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률의 규정에 의거하여 협의를 거쳐 취득하고자 하였으나 협의가 성립되지 않아 중앙토지수용위원회에 재결을 신청하였다. 중앙토지수용위원회의 수용재결(수용의 개시일 : 2020. 6. 30.)에 따라 D시는 보상금을 지급하고 필요한 토지에 대한 소유권이전등기를 마쳤다. D시장은 토지를 취득한 후, 6개월간의 공사 끝에 공원 조성하였다. 공원조성공사가 완료된 후 2년이 지난 뒤에 위 토지를 포함한 그 일대의 토지들이 택지개발예정지구로 지정되었다(고시일 : 2023. 6. 30.) 국토교통부장관에 의하여 택지개발사업의 시행자로 지정된 대한주택공사는 택지개발사업실시계획의 승인을 얻어 공원시설을 철거하고, 그 지상에 임대주택을 건설하는 공사를 시행하고 있다. 이에 공원조성사업을 위해 수용된 토지의 소유자 甲은 2023. 8. 30. 서울특별시에 환매의 의사표시를 하였으나, 서울특별시는 甲에게 환매권이 없다고 하여 수용된 토지를 되돌려 주지 않았다. 이러한 경우에 甲이 소유권 회복을 위해 제기할 수 있는 소송수단 및 그 인용가능성에 대하여 검토하시오. (40점)

【문제 2】 A지방자치단체는 도로사업 부지를 취득하기 위하여 甲의 토지를 협의 취득하여 공공용지의 협의취득을 원인으로 하는 소유권이전등기를 하였고, 乙의 토지에 대하여는 수용재결에 의하여 소유권을 취득한 후 소유권이전등기를 마쳤다. 그러나 甲과 乙의 토지(이하 '이 사건 토지라 함)가 관내의 택지개발예정 지구에 포함되자 A지방자치단체는 이 사건 토지가 도로사업에 더 이상 제공될 수 없는 상황에서 도로사업의 목적 달성이 불가능 하다고 판단하여, 당초 협의 취득 및 수용의 목적이 된 해당 도로사업을 폐지하였다. 이에 따라 甲과 乙에게 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 의한 환매권이 발생하였다. 甲은 협의취득 당시에 수령한 보상금 상당 금액을 공탁한 후, A지방자치단체에게 환매의 의사표시를 하고 소유권이전등기청구소송을 제기하였다. 한편, 乙이 환매권을 행사할 무렵 환매금액에 관해 A지방자치단체와 乙의 협의를 성립되지 아니하여, A지방자치단체는 환매 대상 토지의 현재 가격이 취득일 당시에 비하여 현저히 상승하였음을 들어 환매대금의 증액을 구하는 소송을 제기하였다. 다음 물음에 답하시오. (30점)

1) 乙에 대한 환매대금증액청구소송의 법적 성질을 설명하고, 甲의 소유권이전 등기청구소송에서, A지방자치단체는 환매 대상 토지 가격의 상승에 따른 환매 대금증액청구권을 내세워 증액된 환매대금과 보상금상당액의 차액을 지급할 것을 선(先)이행 또는 동시이행의 항변으로 주장할 수 있는지에 관하여 설명하시오. (15점)

2) 乙이 수용재결이라는 행정행위의 취소사유에 해당하는 하자를 이유로 민사소송인 소유권이전등기말소청구소송을 제기한 경우 민사법원은 수용재결의 효력을 부인할 수 있는지 검토하시오. (15점)

【문제 3】 토지수용위원회, 보상협의회를 비교 논술향시오. (20점)

【문제 4】 甲은 노점상을 운영하기 위하여 관할청에 도로점용허가를 신청하였다. 이에 관할청은 허가기간 만료 시에 위 시설물을 철거하여 원상복구할 것을 조건으로 이를 허가하였다. 甲은 시설물 철거에 따른 손실보상을 청구할 수 있는지 검토하십시오. (10점)

[문제1] 40

I. 논점의 정리

환매권의 법적성질, 토지보상법 91조가 환매권 행사요건인지, 환매권 행사요건 충족 여부, 공익사업 변환요건을 검토하여 소송수단 및 인용가능성을 검토한다.

II. 환매권의 법적성질

1. 환매권의 의의 및 근거

토지보상법상 환매권이란 공익사업에 필요하여 취득한 토지가 필요없게 되거나 이용되지 않는 경우에 원래의 토지 소유자가 일정한 요건 하에 토지를 재취득할 수 있는 권리이다. 피수용자의 감정 존중과 재산권 존속보장에 그 취지가 있다. ①이론적 근거는 피수용자의 감정 존중, 재산권 존속보장 등을 들 수 있다. 대법원은 환매권을 공평의 원칙상 인정되는 권리로 보면서도 헌법상 재산권의 범주에 속한다고 본다. ②법적 근거는 헌법23조3항 및 토지보상법91조를 들 수 있다.

2. 환매권의 법적성질

1) 공권

수용을 해제하고 원상회복을 구하는 것이므로 공권으로 보는 공권설, 개인의 이익을 위한 권리로서 사권이라고 보는

	사권설이 있다. 대법원은 사권으로 보고, 환매금액증감에 관한 소송을 민사소송에 의하도록 판시한 바 있다. 생각건대 환매권은 개인의 이익을 위한 것으로 사권설이 타당하다.
	2) 형성권
	형성권이란 요건충족 시 일방적 의사표시로 형성적 효력이 발생하는 권리를 말하며 청구권과 달리 상대방이 동시이행 항변권을 주장하지 못하는 권리이다. 대법원은 환매권은 일종의 형성권으로서 재판상이든 재판외이든 그 기간 내에 행사하면 이로써 매매의 효력이 발생한다고 한다고 하여 일관되게 형성권으로 보고 있다.
	3) 채권적 효력
	토지를 환매할 수 있다는 의미에 대해 견해대립 있으나 소유권은 환매권자의 의사표시에 의해 소유권 이전이라는 물권적 효력을 발생한다고 보기 어려운바 소유권이전 등기 청구권이라는 채권적 효력이 발생한다는 <채권적 효력설>이 타당하다. 판례도 같은 입장이며 이때 소송은 소유권이전등기청구소송 형태 취한다.
	Ⅲ. 甲의 환매권 행사요건 충족 여부
	1. 법91조1항 요건

	①공익사업의 폐지·변경·그 밖의 사유로 취득한 토지의 전부
	또는 일부가 필요 없게 된 때, 환매권자는 공익사업의 폐지·
	변경의 경우 사업의 폐지·변경 고시가 있는 날부터, 그 밖의
	사유인 경우 사업완료일부터 10년 이내에 그 토지에 대하
	여 받은 보상금 상당액을 사업시행자에게 지급하고 그 토지
	를 환매할 수 있다. ②<해당사업>이란 토지 취득 목적이
	된 구체적인 특정 공익사업을 의미한다. <사업의 폐지·변
	경>이란 해당 사업을 폐지하는 것뿐 아니라 다른 사업으로
	전환하는 것도 포함한다. <그 밖의 사유>란 관계법에 의하
	여 사업의 폐지·변경 또는 그에 갈음하는 행위로 더 이상
	목적사업에 제공할 필요가 없게 된 객관적 사유를 뜻한다.
	<필요없게 되었는지>는 사업자의 주관적 의사를 표준으로
	할 것이 아니라, 당해 사업의 목적과 내용, 협의취득의 경위
	와 범위, 당해 토지와 사업의 관계, 용도 등 제반사정에 비
	추어 객관적·합리적으로 판단한다.
	2. 법91조2항 요건
	①취득일부터 5년 이내에 취득한 토지의 전부를 해당 사업
	에 이용하지 아니하였을 때 취득일부터 6년 이내 환매권을
	행사하여야 한다. ②특정 환매권자의 해당 필지를 기준으로
	판단해서는 안 되고, 사업시행자가 취득한 토지 전부를 기
	준해야 한다. ③사업에 이용할 필요가 없게 된 것이 아니라,

	단지 사실상 사업에 제공되지 않은 경우면 족하다.
	3. 91조 1항과 2항의 관계
	서로 독립적으로 성립한다. 따라서 어느 한쪽의 요건에 해당된다고 하더라도 다른 쪽의 요건을 주장할 수 있고, 제2항의 규정에 의한 제척기간이 도과하였다하더라도, 제1항의 규정에 의한 환매권 행사가 가능하다.
	4. 사안의 경우
	근린공원사업은 토지보상법 4조3호의 공원사업에 해당하고 취득일은 2020.6.30.이다. 근린공원으로 조성공사 완료하여 이용하다가 사후 택지개발예정지구지정으로 불필요하게 된 경우이고, 필요 없게 된 때에는 택지개발예정지구지정고시 일인 2023.6.30.로서 2023.8.30.일은 폐지·변경 고시가 있는 날로부터 10년 이내이다. 따라서 사안은 환매권 행사기간 충족한다.
	IV. 환매권 행사제한 여부(공익사업 변환)
	1. 공익사업변환의 의의, 근거, 취지
	공익사업 변환은 공익사업이 다른 공익사업으로 변경된 경우 별도의 절차 없이 당해 토지를 변경된 공익사업에 이용하도록 하는 제도이다. 재취득하는 무용한 절차의 반복을

방지하기 위한 제도이다(토지보상법 제91조 6항).

2. 공익사업변환 요건

①<사업시행자 요건> 사업인정을 받은 사업시행자가 국가, 지방자치단체 또는 공공기관이어야 한다. ②<대상사업 요건> 변경 전 공익사업은 사업인정을 받아야 하고, 변경 후 공익사업은 토지보상법 4조 1호부터 5호까지의 공익사업이어야 한다. ③새로운 공익사업은 사업인정을 받거나 받은 것으로 의제되어야 한다는 것이 판례의 입장이다. 또한 ④변경된 사업시행자 아닌 제3자에게 처분되지 않음을 요건으로 한다.

3. 사업시행자 변경 시 변환규정의 적용여부

1) 학설

①공익성이 높은 사업으로 변경되는바, 사업시행자 변경 시에도 적용된다는 견해, ②변경 시 사업시행자가 토지가액 변동의 차액을 얻게 되는 불합리함이 있어 적용될 수 없다는 견해가 있다.

2) 판례

대법원은 관계 법령 규정이나 입법이유 등으로 미루어 볼 때, 공익사업 변환이 사업시행자가 동일한 경우에만 허용되

는 것은 아니라 한다.

3) 검토

공익사업변환제도는 공공필요의 소멸이라는 수용본질의 한계 상 인정되는 것이므로, 이 취지에 반하는 예외규정은 좁게 해석함이 국민의 권리구제에 유리하다. 따라서 사업시행자 변경 시에는 동 규정은 적용되지 않는 것으로 봄이 타당하다.

4. 사안의 경우

변경 전 공익사업은 사업인정이 있었고, 사업시행자가 D시로서 지방자치단체에 해당한다. 변경 후 공익사업은 토지보상법 4조 5호에 해당하는 사업이고, 사업인정의제가 있었다. 다만, 사업시행자가 D시에서 대한주택공사로 변경된바, 공익사업 변환을 인정하기 어려울 것이다.

V. 甲의 소송수단 및 그 인용가능성

1. 소송수단 및 환매방법

甲은 보상금 상당액을 미리 지급하고 환매의사를 표시하면 되고, 사업시행자가 이를 거부 시 민사소송으로 소유권이전등기청구소송을 제기하여야 한다. 다만, 환매권을 공권으로 보는 입장에서는 공법상 당사자소송을 제기하여 소유권을

회복할 수 있다.

2. 대항력(토지보상법91조5항)

환매권은 「부동산등기법」이 정하는 바에 따라 공익사업에 필요한 토지의 협의취득 또는 수용의 등기가 되었을 때에는 제3자에게 대항할 수 있다. 제3자에게 대항할 수 있다는 것은 제3자가 권리 주장을 할 수 있다는 것을 말한다.

3. 소유권이전등기청구소송(민사소송)과 인용가능성(적극)

甲은 환매권 요건을 충족하고 공익사업변환이 적용되지 않으며, 토지보상법은 환매권자가 제3자에게 대항할 수 있다고 규정하므로, 甲은 소유권이전등기청구소송이라는 민사소송을 제기할 수 있고 인용가능성이 있다. 다만, 사업시행자 변경 시 공익사업변환제도가 적용된다는 판례의 입장을 따른다면 공익사업 변환이 인정되어 갑의 청구는 인용가능성이 없다.

<끝>

[문제2] 30점

<물음1>15점

I. 쟁점의 정리

환매대금증액청구소송이 민사소송인지 설명하고, 甲의 해당

	사안을 토지보상법 91조4항 및 시행령 48조, 판례를 중심으로 설명한다.
	Ⅱ. 관련 규정 검토
	1. 「토지보상법」 제91조 제4항(환매금액증감청구)
	토지의 가격이 취득일 당시에 비하여 현저히 변동된 경우 사업시행자와 환매권자는 환매금액에 대하여 서로 협의하
	되, 협의가 성립되지 아니하면 그 금액의 증감을 법원에 청
	구할 수 있다.
	2. 「토지보상법 시행령」 제48조(현저한 변동의 의미)
	토지의 가격이 취득일 당시에 비하여 현저히 변동된 경우는
	환매권 행사 당시의 토지가격이 지급한 보상금에 환매 당시
	까지의 해당 사업과 관계없는 인근 유사토지의 지가변동률
	을 곱한 금액보다 높은 경우로 한다.
	Ⅲ. 환매대금증액청구소송의 법적성질
	1. 환매대금증액청구소송의 의의 (「토지보상법」 제91조)
	토지의 가격이 취득일 당시에 비하여 현저히 변동된 경우
	사업시행자와 환매권자가 환매금액에 대하여 서로 협의가
	성립되지 아니할 때 사업시행자가 그 금액의 증액을 법원에
	청구하는 소송을 의미한다.

	2. 공법상 당사자소송 (「행정소송법」 제3조 제2호)
	행정청의 처분 등을 원인으로 하는 법률관계나 그 밖에 공
	법상의 법률관계에 관한 소송으로서 그 법률관계의 한쪽 당
	사자를 피고로 하는 소송이다. 구법과 종전판례에 의하면
	환매대금증액청구소송은 공법상 당사자소송으로 보았다.
	3. 관련 판례 (민사소송)
	토지보상법 91조의 환매권은 형성권의 일종으로 규정에 따
	른 기간 내에 행사하면 매매의 효력이 생기는바, 환매금액
	의 증감을 구하는 소송 역시 민사소송에 해당한다고 판시한
	바 있다.
	4. 소결
	사업시행자가 사인과 평등한 지위에 있으며 그 목적이 사인
	의 이익을 위한 것이므로 환매권을 <사권>으로 볼 수 있으
	다. 이에 따라 환매대금증액청구소송은 <민사소송>으로 볼
	것이다.
	IV. 선이행 또는 동시이행의 항변 주장 가능성
	1. 관련 판례
	환매권 행사로 인한 소유권이전등기 청구소송에서 환매대금
	증액청구권을 내세워 증액된 환매대금과 보상금 상당액의

	차액을 지급할 것을 선이행 또는 동시이행의 항변으로 주장할 수 없다.
	2. 소결
	환매권은 환매권자가 지급받은 보상액 상당액을 사업시행자에게 선지급하고 일방적 의사표시로 환매가 성립하는바, 환매대금 증액청구권을 내세워 증액된 환매대금과 보상금 상당액의 차액 지급을 선이행 또는 동시이행의 항변으로 주장할 수 없다.
	<물음2>15점
	I. 쟁점의 정리
	민사소송인 소유권이전등기말소청구소송에서 행정행위인 수용재결의 효력 부인이 가능한지 선결문제의 가능성을 검토한 뒤 사안을 해결한다.
	II. 선결문제의 의의 등
	1. 선결문제의 의의 및 근거 (「행정소송법」 제11조)
	선결문제란 민사·형사법원의 본안판단에 앞서 특정 행정행위의 위법 여부 또는 효력 유무가 먼저 해결되어야 할 문제인 된 경우에 그 특정 행정행위의 위법 여부 등의 문제를 선결문제라 한다.

2. 구성요건적 효력과 선결문제

구성요건적 효력이란 취소할 수 있는 행정행위일지라도 그 행정행위가 유효하게 존재하는 한 다른 행정기관이나 법원은 그 행위와 관련이 있는 자들의 결정에 그 행위의 존재와 법적 효과를 인정해야 하고 그 내용에 구속되는 효력을 말한다. 선결문제를 공정력의 문제로 보는 견해도 있으나(공정력과 구성요건적 효력을 구분하지 않는 견해), 공정력과 구성요건적 효력은 내용, 범위 및 이론적·법적근거를 달리하므로 양자를 구별하는 것이 타당하며, 선결문제를 구성요건적 효력의 문제로 보는 것이 다수의 견해이다.

Ⅲ. 민사법원의 행정행위 효력 부인 가능성

1. 학설

위법한 행정행위라도 당연무효가 아닌 한 당해 행정행위의 구성요건적 효력으로 인해 유효하므로 그 효력을 부인할 수 없어 선결문제로 심사할 수 없다는 것이 일반적 견해이다.

2. 판례

1) 당연무효인 경우

행정처분이 당연무효임을 전제로 하여 민사소송을 제기한 때에는 그 행정처분의 당연무효인지의 여부가 선결문제이므로, 법원은 이를 심사하여 그 행정처분의 하자가 중대하고

명백하여 당연무효라고 인정될 경우에는 이를 전제로 하여 판단할 수 있으나 그 하자가 단순한 취소사유에 그칠 때에는 법원은 그 효력을 부인할 수 없다 할 것이다.

2) 취소사유인 경우

불복절차를 취하지 않음으로써 그 재결에 대하여 더 이상 다룰 수 없게 된 경우에는 기업자는 그 재결이 당연무효이거나 취소되지 않는 한 재결에서 정한 손실보상금의 산정에 있어서 위 하자가 반영되지 않았다는 이유로 민사소송절차로 토지소유자에게 부당이득의 반환을 구할 수는 없다.

3. 검토

선결문제는 구성요건적 효력의 문제이므로, 행정행위에 단순 취소사유의 하자가 있다면 그 행위는 여전히 유효하게 존재하며, 다른 국가기관은 그 효력을 인정하여야 하므로 그 효력을 부인할 수 없다고 보는 것이 타당하다.

IV. 사안의 해결

사안의 경우 수용재결에는 단순 취소사유에 해당하는 하자만이 있으므로 소유권이전등기말소청구소송의 수소법원인 민사법원은 해당 행정행위의 효력을 부인할 수 없다.

<끝>

[문제3]20점

I. 개설

토지보상법상 토지수용위원회와 보상협의회의 근거와 법적 지위, 구성, 권한 등에 대하여 비교·검토한다.

II. 토지수용위원회

1. 토지수용위원회(토지보상법 49조~60조)

토지수용위원회는 사업시행자와 토지소유자 또는 관계인과의 사이에서 수용이나 손실보상에 관한 다툼을 당사자가 주장하는 바에 따라 공정·중립의 입장에서 판단하고, 이를 최종적으로 재결하는 준사법적 행정기관이다.

2. 법적성격

토지수용위원회는 공익사업에 필요한 토지 등의 수용 또는 사용에 대한 재결을 목적으로 설치되어 있다는 점에서 ①독립적 행정기관이며, 다수의 구성위원의 합의에 의해 독립적으로 토지수용위원회의 이름으로 재결을 하는 점에서 ②합의적 행정청이다. 또한 ③준사법적 행정기관에 해당하며, 법에서 반드시 설치하도록 하고 있어 ④필수기관으로 본다.

3. 설치 및 구성

토지수용위원회는 중앙토지수용위원회와 지방토지수용위원

회가 있으며, 중앙토지수용위원회는 국토교통부에 두고 위원장 1명을 포함한 20명 이내의 위원으로 구성한다. 위원장은 국토교통부장관이 되며, 위원장은 위원회를 대표하고 위원회의 업무를 총괄한다. 지방토지수용위원회의 위원장은 시도지사가 된다.

4. 재결사항(토지보상법50조1항)

수용하거나 사용할 토지의 구역 및 사용방법, 손실보상, 수용 또는 사용의 개시일과 기간, 그 밖에 이 법 및 다른 법률에서 규정한 사항을 재결한다.

Ⅲ. 보상협의회

1. 보상협의회(토지보상법 82조)

보상업무에 관한 사항을 협의하기 위해서 시·군·구에 설치하는 합의제 행정기관이다. 개정의 취지는 보상업무의 지연 초래를 방지하기 위함이다.

2. 법적성격

보상협의회 설치하는 임의적 사항이나, 공익사업지구 면적이 10만제곱미터 이상이고, 토지 등의 소유자가 50인 이상인 공익사업의 경우에는 필수적으로 설치하여야 하는 필수기관이다.

	3. 설치 및 구성
	위원장 1명을 포함한 위원 8명 이상 16명 이내의 위원으로
	구성하되, 사업시행자를 위원에 포함시키고, 위원 중 1/3이
	상은 토지소유자 또는 관계인으로 구성하여야 한다. 위원장
	은 해당 특별자치도, 시, 군 또는 구의 부지사, 부시장, 부군
	수 또는 부구청장이 된다.
	4. 심의사항
	공익사업이 시행되는 해당 지방자치단체의 장은 보상액 평
	가를 위한 사전 의견수렴에 관한 사항, 잔여지의 범위 및
	이주대책의 수립에 관한 사항, 해당 사업지역 내 공공시설
	의 이전 등에 관한 사항 토지소유자 또는 관계인 등이 요구
	하는 사항 중 지방자치단체의 장이 필요하다고 인정하는 사
	항, 그 밖에 지방자치단체의 장이 부의하는 사항을 심의한
	다.
	IV. 결
	위의 검토와 같이 각각의 위원회는 근거법령, 법적성격, 설
	치 및 구성, 심의 또는 협의사항 등에 차이가 있다. 그러나
	모두 행정기관으로 관련된 송사이익의 조절적 기능을 담당
	하는 측면에 있어 유사하다.
	<끝>

[문제4]10점

I. 논점의 정리

손실보상은 공공필요, 재산권에 대한 적법한 공권적 침해, 특별한 희생, 보상규정의 존재를 요건으로 한다. 도로의 원상회복은 공공필요가 인정되고, 관할청의 적법한 공권력행사이며, 시설물 철거 시 甲은 재산권에 대해 침해를 받는다. 손실보상 요건 중 철거에 따른 甲의 손실이 특별한 희생에 해당하는지 검토한다.

II. 특별한 희생의 판단기준

인적범위의 특정을 기준하는 <형식설>, 침해행위 성질과 정도를 기준으로 하는 <실질설>이 있다. <검토> 양자 타당한바, 상호 보완적으로 적용하는 <절충설>이 타당하다.

III. 관련판례

하천부지 점용허가를 하면서 점용기간 만료 또는 점용을 폐지하였을 때에는 즉시 원상복구할 것이라는 부관을 붙인 사안에서 이 부관의 의미는 하천부지에 대한 점용기간 만료 시 그에 관한 개간비보상청구권을 포기하는 것을 조건으로 본 사례가 있다.

IV. 사안의 경우(甲의 손실보상 청구 불가능)

甲은 자진철거를 하여 원상회복할 것을 조건으로 도로점용 허가를 받은바, 허가기간 만료 시 철거로 인한 손실을 보호 가치 있다거나 수인한도를 넘은 것이라고 보기 어렵다. 따라서 甲의 손실은 특별한 희생이 아니라고 판단한다. 甲손실은 특별한 희생이 아니므로, 甲은 시설물철거에 따른 손실보상을 청구할 수 없다.

<이하여백>

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
3교시	100분	③ 감정평가법규
수험번호		성 명

【문제 1】甲은 P시의 관할구역 내 A토지를 소유하고 있다. P시는 최근 세계적인 불황으로 실업자가 급격하게 증가하고 있다. 국토교통부장관은 P시의 지역경제 활성화시킬 목적으로 기업도시개발특별법이 정하는 바에 따라 A토지가 포함된 일단의 토지를 기업도시개발구역으로 지정하고, 개발사업시행자인 乙이 작성한 기업도시개발계획(동법 제14조 제2항에 따른 A토지 그 밖의 수용 대상이 되는 토지의 세부목록 포함. 이하 같다)을 승인·고시하였다. 乙은 협의취득에 관한 제반 절차를 준수하여 A토지에 대한 협의취득을 시도하였으나 甲이 응하지 않았다. 이에 乙은 A토지에 대한 수용재결을 신청하였고 중앙토지수용위원회는 그 신청에 따른 수용재결을 하였다. 다음 물음에 답하시오. (40점)

1) 甲은 기업도시개발계획승인에 대한 취소소송의 제소기간이 도과한 상태에서 공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률 제21조 제2항에 따른 중앙토지수용위원회 및 이해관계자의 의견청취절차를 전혀 시행하지 않은 채 기업도시개발계획승인이 발급된 것이 위법함을 이유로 수용재결 취소소송을 제기하려고 한다. 甲의 소송상 청구가 인용될 수 있는 가능성에 관하여 설명하시오. (단, 소송요건은 충족된 것으로 본다.) (20점)

2)

어느 수용대상 토지에 관하여 특정 시점에서 용도지역 등의 지정 또는 변경을 하지 않은 것이 특정 공익사업의 시행을 위한 것일 경우 이는 당해 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하는 제한이라고 보아 용도지역 등의 지정 또는 변경이 이루어진 상태를 상정하여 토지가격을 평가하여야 한다. 여기에서 특정 공익사업의 시행을 위하여 용도지역 등의 지정 또는 변경을 하지 않았다고 볼 수 있으려면, 토지가 특정 공익사업에 제공된다는 사정을 배제할 경우 용도지역 등의 지정 또는 변경을 하지 않은 행위가 계획재량권의 일탈·남용에 해당함이 객관적으로 명백하여야만 한다.

중앙토지수용위원회는 보상금을 산정하면서, A토지는 그 용도지역이 제1종 일반주거지역이기는 하지만 기업도시개발사업의 시행을 위해서 제3종 일반주거지역으로 변경되지 않은 사정이 인정되므로 제3종 일반주거지역으로 변경이 이루어진 상태를 상정하여 토지가격을 평가한다고 실시하였다. 이에 대해 乙은 A토지를 제1종 일반주거지역이 아닌 제3종 일반주거지역으로 평가한 것은 공법상 제한을 받는 토지에 대한 보상금 산정에 위법이 있다고 주장하면서 보상금감액 청구소송을 제기하고자 한다. 乙의 소송상 청구가 인용될 수 있는 가능성에 관하여 상기 판례의 계획재량권 일탈남용을 고려하여 설명하시오. (단, 소송요건은 충족된 것으로 본다.) (10점)

3) 한편 P시 시장은 용도지역이 제1종 일반주거지역이던 A토지를 제3종 일반주거지역으로 변경했었다가 기업도시개발사업 시행을 위해 제1종 일반주거지역으로 재지정하였다. 甲은 P시 시장의 제1종 일반주거지역으로 재지정한 것은 신뢰보호의 원칙에 위배된다고 주장한다. 甲의 주장이 법적으로 관철될 수 있는가에 대하여 논하시오. (10점)

<참조조문>

공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 (약칭: 토지보상법) 제21조(협의 및 의견청취 등) ① 국토교통부장관은 사업인정을 하려면 관계 중앙행정기관의 장 및 특별시장·광역시장·도지사·특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다) 및 제49조에 따른 중앙토지수용위원회와 협의하여야 하며, 대통령령으로 정하는 바에 따라 미리 사업인정에 이해관계가 있는 자의 의견을 들어야 한다. <개정 2013. 3. 23., 2015. 12. 29., 2018. 12. 31.>

② 별표에 규정된 법률에 따라 사업인정이 있는 것으로 의제되는 공익사업의 허가·인가·승인권자 등은 사업인정이 의제되는 지구지정·사업계획 승인 등을 하려는 경우 제1항에 따라 제49조에 따른 중앙토지수용위원회와 협의하여야 하며, 대통령령으로 정하는 바에 따라 사업인정에 이해관계가 있는 자의 의견을 들어야 한다. <신설 2015. 12. 29., 2018. 12. 31.>

③ 제49조에 따른 중앙토지수용위원회는 제1항 또는 제2항에 따라 협의를 요청받은 경우 사업인정에 이해관계가 있는 자에 대한 의견 수렴 절차 이행 여부, 허가·인가·승인대상 사업의 공공성, 수용의 필요성, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 검토하여야 한다. <신설 2015. 12. 29., 2018. 12. 31.>

④ 제49조에 따른 중앙토지수용위원회는 제3항의 검토를 위하여 필요한

경우 관계 전문기관이나 전문가에게 현지조사를 의뢰하거나 그 의견을 들을 수 있고, 관계 행정기관의 장에게 관련 자료의 제출을 요청할 수 있다. <신설 2018. 12. 31.>

⑤ 제49조에 따른 중앙토지수용위원회는 제1항 또는 제2항에 따라 협의를 요청받은 날부터 30일 이내에 의견을 제시하여야 한다. 다만, 그 기간 내에 의견을 제시하기 어려운 경우에는 한 차례만 30일의 범위에서 그 기간을 연장할 수 있다. <신설 2018. 12. 31.>

⑥ 제49조에 따른 중앙토지수용위원회는 제3항의 사항을 검토한 결과 자료 등을 보완할 필요가 있는 경우에는 해당 허가·인가·승인권자에게 14일 이내의 기간을 정하여 보완을 요청할 수 있다. 이 경우 그 기간은 제5항의 기간에서 제외한다. <신설 2018. 12. 31., 2020. 6. 9.>

⑦ 제49조에 따른 중앙토지수용위원회가 제5항에서 정한 기간 내에 의견을 제시하지 아니하는 경우에는 협의가 완료된 것으로 본다. <신설 2018. 12. 31.>

⑧ 그 밖에 제1항 또는 제2항의 협의에 관하여 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다. <신설 2018. 12. 31.>

[전문개정 2011. 8. 4.][제목개정 2018. 12. 31.]

기업도시개발 특별법 (약칭: 기업도시법)

제14조(토지등의 수용·사용) ① 시행자는 개발구역에서 개발사업을 시행하기 위하여 필요할 때에는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제3조에 따른 토지·물건 또는 권리(이하 "토지등"이라 한다)를 수용 또는 사용(이하 "수용등"이라 한다)할 수 있다.

② 제1항을 적용하는 경우에 수용등의 대상이 되는 토지등의 세부 목록을 제11조제6항에 따라 고시한 때에는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제20조제1항 및 제22조에 따른 사업인정 및 사업인정의 고시가 있는 것으로 본다. <개정 2017. 10. 24.>

③ 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제28조에 따른 재결의 신청은 개발구역 토지면적의 100분의 50 이상에 해당하는 토지를 확보(토지소유권을 취득하거나 토지소유자로부터 사용동의를 받은 것을 말한다)한 후에 할 수 있다. 다만, 제10조제2항에 따라 공동으로 개발사업을 시행하는 경우에는 개발구역 토지면적의 100분의 50 이상에 해당하는 토지를 확보하기 전에도 재결의 신청을 할 수 있다.

④ 재결의 신청은 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법

률」 제23조제1항 및 제28조제1항에도 불구하고 제11조제6항 본문에 따른 개발계획의 고시일부터 4년 이내에 할 수 있다. 다만, 대통령령으로 정하는 부득이한 사유가 있는 경우에는 국토교통부장관의 승인을 받아 그 기간을 2년 연장할 수 있다. <개정 2012. 1. 20., 2013. 3. 23., 2015. 6. 22., 2017. 10. 24.>

⑤ 제1항에 따른 토지등의 수용등에 관한 재결의 관할 토지수용위원회는 중앙토지수용위원회가 된다.

⑥ 시행자는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에서 정하는 바에 따라 개발사업의 시행에 필요한 토지등을 제공함으로써 인하여 생활의 근거를 상실하게 되는 자에 대하여 주거단지 등을 조성·공급하는 등 이주대책을 수립·시행하여야 한다.

⑦ 제6항에 따라 수립하는 이주대책에는 이주대상 주민과 협의하여 당초 토지등의 소유 상황과 생업 등을 고려하여 생활대책에 필요한 용지를 대체하여 공급하는 등 대통령령으로 정하는 사항이 포함되어야 한다.

⑧ 시행자는 토지등의 보상 및 이주대책에 관한 업무를 시장·군수에게 위탁할 수 있다. 이 경우 시장·군수는 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.

⑨ 제8항에 따라 토지등의 보상 및 이주대책에 관한 업무를 위탁받은 시장·군수는 위탁받은 업무를 직접 이행하기 어려운 경우에는 그 업무 중 일부를 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제81조제1항 제2호에서 정한 기관에 재위탁할 수 있다.

⑩ 제1항에 따른 토지등의 수용등에 관하여 이 법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」을 준용한다.

[전문개정 2011. 5. 30.]

【문제 2】 A군에 사는 甲은 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따라 지정된 개발제한구역 내에 과수원을 경영하고 있다. 甲은 영농의 편의를 위해 동 과수원 토지 내에 작은 소로(小路)를 개설하고, 종종 이웃 주민의 통행에도 제공해 왔다. A군은 甲의 과수원 부지가 속한 일단의 토지에 폐기물처리장을 건설하고자 하는 乙을 폐기물관리법에 따라 폐기물처리장 건설사업자로 지정하면서 동 처리장건설사업실시계획을 승인하였다. 甲과 乙간에 甲 토지에 대한 협의매수가 성립되지 않아 乙은 甲 토지에 대한 수용재결을 신청하고, 관할 지방토지수용위원회의 수용재결을 받았다. 동 수용재결에서는 “사실상 사도(私道)의 부지는 인근 토지에 대한 평가액의 3분의 1 이내로 평가한다.”고 규정하고 있는 공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률 시행규칙(이하 ‘토지보상법 시행규칙’) 제26조 제1항 제2호의 규정에 따라, 甲의 토지를 인근 토지가에 비하여 3분의 1의 가격으로 평가하였다. 이 수용재결에 대하여 이의가 있는 甲은 적절한 권리구제 수단을 강구하고자 한다. 다음의 물음에 답하시오.

1) 甲은 토지보상액에 대해 불복하여 보상금증액청구소송을 제기하였고, 당해 재판에서 피고 측은 甲의 토지에 대한 보상액이 낮게 평가된 것은 토지보상법 시행규칙 제26조 제1항 제2호의 규정에 의한 것으로서 적법하다고 주장한다. 피고의 주장에 대해 법적으로 판단하시오. (15점)

2) 甲은 토지보상법 시행규칙 제26조 제1항 제2호의 규정은 헌법 제23조상의 재산권보장 및 정당보상원칙을 위배하여 위헌적인 것이라고 주장한다. 甲의 주장을 관철할 수 있는 법적 수단을 설명하시오. (15점)

【문제 3】인천시는 인천도시공사를 사업시행자로 하여 국민임대주택단지 조성사업(이하 조성사업)에 대한 사업인정 및 사업인정고시를 하였다. 甲은 조성사업 내 X토지를 소유하고 있다. X토지는 지목이 임야이나 과수원으로 개간된 토지이다. 인천도시공사는 현실적 이용상황이 과수원인 甲의 토지가 불법적으로 형질변경된 것이라고 하여 개간 전 상태인 임야로 보고 평가한 재결감정 결과에 따라 손실보상액을 산정하였다. 손실보상액 산정 당시 인천도시공사는 甲의 토지가 과수원으로 개간되던 당시에 시행되던 법령에 의할 때 그 개간이 허가대상이라는 점을 입증하지 못한 상태였다. 불법형질변경토지의 보상평가기준에 대해 설명하고, 사안의 인천도시공사가 산정한 손실보상액이 정당한 보상인지 검토하시오. (20점)

【문제 4】개간비 보상과 평가에 대해 설명하시오. (10점)

	[문제1](40점)
	<물음1> 20점
	I. 논점의 정리
	의견청취절차를 흠결한 기업도시개발계획승인의 위법성, 하
	자의 정도, 위법하다면 수용재결 취소소송에서 이를 다룰
	수 있는지가 하자의 승계와 관련하여 문제된다.
	II. 관련 행정작용의 법적성질
	1. 개발계획승인
	사안의 사업은 토지보상법 4조의 공익사업으로, 개발계획승
	인은 사업시행자에게 수용권을 설정하는 사업인정의제에 해
	당하며, 강학상 특허이자 설권적 처분이다. 공익성 여부 및
	관련된 제 이익과의 형량을 거치는 점에서 재량행위이며,
	제3자효 행정행위의 성격도 가진다.
	2. 수용재결
	수용재결이란 협의가 불성립되거나 불능인 경우에 사업시행
	자의 재결신청에 의해 토지수용위원회가 수용권의 구체적
	내용을 결정하는 공용수용의 종국적 절차로서 설권적 처분
	이다. 토지보상법 제34조, 제50조에 근거를 둔다.
	III. 의견청취절차 하자의 위법 여부

	1. 관련규정 검토
	기업도시개발 특별법 14조 4항은 토지보상법을 준용하도록 규정하고 있고, 토지보상법 21조에서는 의견청취절차를 규정하고 있다. 따라서 위 의견청취 절차의 흠결은 토지보상법에서 정한 절차를 위배된 것으로 볼 수 있다.
	2. 절차상 하자의 독자적 위법성
	처분의 내용상 하자는 없으나 절차상의 위법만을 이유로 독립된 위법사유가 되는지가 문제된다. 이에 대해, 긍정설, 부정설, 절충설(기속행위와 재량행위로 구별하는 학설) 등의 견해 대립은 있으나, 판례는 기속행위인 과세처분에서 이유제시 하자를 이유로, 재량행위인 식품위생법상 영업정지처분 시 청문절차 결여는 행정절차에 고려해야 할 사항을 누락하였다고 하여 위법성을 인정하였다. 생각건대, 적법절차 관점 등에서 재량행위, 기속행위를 구분하고 절차적 하자의 독자적 위법성을 긍정함이 타당하다.
	3. 위법성 정도
	위법성 정도에 대한 일반적 기준인 중대명백설에 따를 때 절차상 하자의 경우 일반적으로 법 위반으로 그 하자가 중대하나 외견상 명백하다고 보기는 어려워 취소사유로 봄이 타당하다.

	IV. 하자승계의 전제요건 및 인정근거
	1. 의의
	하자승계란 둘 이상의 행정행위가 연속적으로 행해지는 경우 선행 행정행위 위법을 이유로 후행 행정행위를 다룰 수 있는가의 문제이다. 법적 안정성 및 법률적합성에 의한 국민의 권리구제 조화의 문제이다.
	2. 하자승계의 요건 검토
	①선·후행행위 모두 처분일 것, ②선행행위의 하자가 취소사유일 것, ③후행행위가 적법할 것, ④선행행위에 불가쟁력이 발생할 것이 요구된다. 사안의 경우 선행 사업인정의제와 후행 수용재결은 모두 처분에 해당하고, 선행행위에는 절차상 하자인 취소 사유의 위법이 있으며, 후행행위는 적법하고, 선행행위는 제소기간 도과하였으므로 요건을 충족한다.
	3. 하자의 승계의 인정범위
	①단계적 일련의 행정행위가 하나의 법률효과를 예정하는 경우 하자승계가 인정된다는 하자승계론과 ②선행행위의 불가쟁력이 후행행위에 구속력으로 작용하고 구속력이 인정되지 않는 경우 하자의 승계가 인정된다는 구속력론이 대립한다. 대법원은 원칙적으로 하자승계론 입장을 취하면서 예측가능성과 수인가능성을 추가적인 판단지표로 활용한다.

	V. 사업인정의제의 하자가 수용재결에 승계되는지
	1. 학설 및 판례
	이에 대하여 ①사업인정과 수용재결은 서로 별개의 법률효과를 예정하고 있으므로 승계를 부정하는 견해와 ②수용재결은 사업시행자의 재결신청에 의한 것으로 사업인정을 전제로 이루어지는 것이므로 승계를 긍정하는 견해가 대립한다. 대법원은 사업인정의 하자가 무효사유가 아닌 한 수용재결을 다투는 단계에서 사업인정의 위법을 주장할 수 없다고 하여 부정하는 입장이다.
	2. 검토
	사업인정과 수용재결은 서로 별개의 법률효과를 예정하고 있다. 또한, 개발계획승인고시 이후 乙은 甲과 협의절차를 진행한 점에서 甲은 개발계획승인고시가 있는 사실을 알고 이를 법적으로 다투기 기회도 있었으며, 제소기간 내 이를 행하지 않았다. 결국 법률효과도 다르고, 예측가능성 및 수인가능성도 부정되는바, 하자승계는 인정되기 어렵고 甲의 소송상 청구는 인용가능성이 없다. 판례도 같은 입장이다.
	<물음2>10점
	I. 논점의 정리
	토지 손실보상금의 공법상 제한 반영에 관한 판례 등을 기

	초로 사례를 해결한다.
	Ⅱ. 해당사업을 직접 목적으로 용도지역이 변경된 것인지
	1. 관련규정(토지보상법 시행규칙 23조)
	공법상 제한은 용도지구, 용도구역 등 관계 법령에 의해 가
	해지는 토지 이용 규제나 제한을 의미한다. 토지보상법 시
	행규칙 23조는 공법상 제한을 받는 토지에 대하여 제한받
	는 상태대로 평가하되, 그 공법상 제한이 당해 공익사업의
	시행을 직접 목적으로 가하여진 경우 제한이 없는 상태를
	상정하여 평가한다고 규정한다.
	2. 관련판례[2012두7950판례 참조]
	어느 수용대상 토지에 관하여 특정 시점에서 용도지역 등의
	지정 또는 변경을 하지 않은 것이 특정 공익사업의 시행을
	위한 것일 경우 이는 당해 공익사업의 시행을 직접 목적으
	로 하는 제한이라고 보아 용도지역 등의 지정 또는 변경이
	이루어진 상태를 상정하여 토지가격을 평가하여야 한다. 여
	기에서 특정 공익사업의 시행을 위하여 용도지역 등의 지정
	또는 변경을 하지 않았다고 볼 수 있으려면, 토지가 특정
	공익사업에 제공된다는 사정을 배제할 경우 용도지역 등의
	지정 또는 변경을 하지 않은 행위가 계획재량권의 일탈·남
	용에 해당함이 객관적으로 명백하여야만 한다.

	Ⅲ. 계획재량의 일탈·남용이 명백한지 여부
	1. 형량명령
	계획재량의 일탈남용 여부는, 행정계획의 관련된 이익을 정당하게 형량한다는 형량명령에 따라 판단한다. 이 점에서 행정재량과 구분된다. 형량하자에는 향량해태, 형량 흠결, 오형량 등이 있다.
	2. 사안의 경우
	사안의 경우 당해 사업의 시행을 위해 제3종 일반주거지역으로 변경되지 않은 사정이 있으나, 위 사정이 행정청에 주어진 계획재량의 일탈·남용에 해당함이 명백하다고 단정하기는 어렵다고 보인다. 따라서 乙의 보상금감액주장은 타당하며 소송청구는 인용가능하다.
	<물음3> 10점
	I. 논점의 정리
	신뢰보호원칙 위배 주장 관련하여 용도지역 지정이 공적견해표명에 해당하는지 문제된다.
	Ⅱ. 신뢰보호원칙의 의의 및 근거(행정기본법 12조)
	신뢰보호원칙이란 행정기관이 공익 또는 제3자의 이익을 현저히 해칠 우려가 있는 경우를 제외하고는 행정에 대한

국민의 정당하고 합리적인 신뢰를 보호하여야 한다는 원칙을 말한다. 법적 안정성, 신의칙 및 사회국가원리에서 이론적 근거를 찾을 수 있고, 실정법으로는 행정기본법 제12조, 행정절차법 제4조 제2항 등을 근거로 들 수 있다.

Ⅲ. 요건 및 한계

신뢰보호원칙이 적용되기 위해서는 ① 행정청이 개인에 대해 공적인 견해표명을 하여야 하고, ② 그 견해표명이 정당하다고 신뢰한 데에 대하여 개인의 귀책사유가 없어야 하며, ③ 개인이 그 견해표명을 신뢰하고 이에 상응하는 어떠한 행위를 하였어야 하고, ④ 행정청이 위 견해표명에 반하는 처분을 함으로써 ⑤ 그 개인의 이익이 침해되는 결과가 초래되어야 한다. 다만, ⑥ 그 견해표명에 따른 행정처분을 할 경우 그로 인해 공익 또는 제3자의 정당한 이익을 현저히 해할 우려가 있는 경우가 아니어야 한다.

Ⅳ. 판례 및 사안의 경우

대법원은 용도지역의 결정만으로 공적인 견해표명을 한 것이라고 볼 수 없다고 한다. 따라서 P시 시장이 3종 일반주거지역으로 변경했었다는 사실만으로 신뢰보호원칙이 적용될 수는 없다. 甲의 주장은 법적으로 관철될 수 없다.

<끝>

문제2 30점
<물음1> 15점
I. 논점의 정리
토지보상법 시행규칙 26조 1항 2호는 사실상 사도의 보상 평가에 대한 방법을 규정하고 있다. 사안의 경우 사실상 사도에 해당하는지를 검토하여 감가보상의 타당성을 논한다.
II. 사실상 사도의 의의
사실상의 사도란 그 효용은 사도법상 사도와 같으나 관할 시장 등의 허가를 받지 않고 개설하거나 형성된 도로를 말한다. 즉 「사도법」에 의한 사도외의 도로(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 의한 도시·군관리계획에 의하여 도로로 결정된 후부터 도로로 사용되고 있는 것을 제외한다)로서, ① 도로개설당시의 토지소유자가 자기 토지의 편익을 위하여 스스로 설치한 도로, ② 토지소유자가 그 의사에 의하여 타인의 통행을 제한할 수 없는 도로, ③ 「건축법」 제45조에 따라 건축허가권자가 그 위치를 지정·공고한 도로, ④ 도로개설당시의 토지소유자가 대지 또는 공장용지 등을 조성하기 위하여 설치한 도로의 어느 하나에 해당하는 도로를 말한다(칙 제26조 제2항).
III. 사실상 사도의 의미(판례)

	자기토지 편익을 위해 스스로 설치한 토지는 도로개설 경위
	와 목적, 주위환경, 인접토지의 획지 면적, 소유관계 및 이
	용상태 등 제반 사정을 종합적으로 고려하여 판단하며, 토
	지소유자가 그 의사에 의하여 타인의 통행을 제한할 수 없
	는 도로의 의미는 법률상 소유권을 행사하여 통행을 제한할
	수 없는 경우뿐만 아니라 사실상 통행을 제한하는 것이 곤
	란하다고 보이는 경우도 해당한다고 할 것이나, 적어도 도
	로의 이용상황이 고착화되어 당해 토지의 표준적 이용상
	황으로 원상회복하는 것이 용이하지 않은 상태에 이르러야
	할 것이어서 단순히 당해 토지가 불특정 다수인의 통행에
	장기간 제공되어 왔고 이를 소유자가 용인하여 왔다는 사정
	만으로는 사실상의 도로에 해당한다고 할 수 없다라고 판시
	한바 있다.
	IV. 평가방법
	사실상 사도는 인근토지에 대한 평가액의 3분의 1 이내로
	평가한다(칙 제26조 제1항). "인근토지"라 함은 당해 도로부
	지 또는 구거부지가 도로 또는 구거로 이용되지 아니하였을
	경우에 예상되는 표준적인 이용상황과 유사한 토지로서 당
	해 토지와 위치상 가까운 토지를 말한다(칙 제26조 제4항).
	V. 사안의 경우

사안의 경우 甲은 자기 과수원 토지의 영농 편의를 위해 소로를 스스로 설치하였고, 이웃 주민의 통행에 제공되었으므로, 시행규칙 제26조 제2항 제1호 등에 따른 사실상 사도의 요건을 갖춘 것으로 보인다. 또한 토지보상법 시행규칙 제26조는 법규명령으로서 대외적 구속력이 인정되므로 해당 규정에 따라 적법하게 보상평가 되었으므로 피고의 주장은 타당하다.

<물음2> 15점

I. 논점의 정리

법원에서의 주장 수단 및 헌법재판소에서의 주장 수단이 문제된다.

II. 토지보상법 시행규칙 26조 1항 2호의 위헌성

1. 헌법 23조 3항의 정당보상의 의미

헌법 23조 1항은 재산권보장원칙을 규정하고, 재산권에 대한 고용침해 시 헌법 23조 3항에서 정당보상할 것을 규정하고 있다. 여기에서 정당보상은 피수용재산의 객관적 재산가치를 완전하게 보상하고 보상의 시기, 방법에 어떠한 제한도 없는 완전보상의 의미로 해석할 수 있으며, 판례도 같은 입장이다.

2. 위 규정의 위헌성	
감가보상을 규정한 해당 규정은 헌법 23조 1항의 재산권보	
상원칙과 보상방법에 과도한 제한을 뒤 보상방법을 제한하	
여 완전보상에 미치지 못함으로써 정당보상원칙에 위배될	
소지가 있다.	
Ⅲ. 甲주장을 관철할 수 있는 법적 수단	
1. 항고소송 가능성	
법규명령은 법의 집행행위가 아니어서 항고소송의 대상이	
아니라는 것이 주류의 견해 및 판례 입장이다. 처분적 법규	
명령에 대해서는 항고소송이 인정되나, 사안의 규정은 처분	
적 법규명령이 아니어서 항고소송을 제기할 수는 없다.	
2. 구체적 규범통제의 가능성	
1) 구체적 규범통제의 의의(헌법 107조 2항)	
구체적 규범통제는 특정 법규범이 구체적 사건에 적용되는	
상태에서 그 법규성이 상위 법규범에 위반되는지 심사하는	
제도이다.	
2) 주체 및 재판의 전제성	
주체는 각급법원이고, 대법원이 최종 심사 권한을 갖는다.	
재판의 전제성은 처분의 위법성이 법규명령 등에 기한 것	

	일 때, 처분의 근거법령인 법규명령의 위헌·위법성을 먼저 결정하는 것을 말한다.
	3) 사안의 경우
	토지보상법 시행규칙 26조 1항 2호 규정이 헌법 23조의 재산권보장 및 정당보상원칙을 위배한 규정이라면, 甲은 수용재결인 처분의 위법성을 동 규정이 위헌임에서 기인한 것임을 행정소송에서 주장함으로써 자신의 주장을 관철할 수 있다. 따라서, 수용재결의 취소를 구하는 소송에서 시행규칙 26조의 위헌을 주장할 수 있다.
	3. 헌법소원의 가능성(헌법재판소법 68조 1항)
	법규명령에 대한 헌법소원 가능성에 대해 학설은 대립하나, 통설 및 헌법재판소는 가능하다는 입장을 취한다. 헌법소원의 실체적 요건으로서 공권행사 또는 불행사, 헌법상 보장된 기본권의 침해로 기본권 침해의 자기관련성, 현재성, 직접성이 있을 것, 보충성 및 권리보호필요성이 있을 것이 요구된다. 다만, 사안의 경우 시행규칙만으로 甲의 기본권인 재산권에 영향을 미친다고 보기 어려우므로, 甲은 헌법소원을 통해 자신의 주장을 관철시킬 수 없다.
	<끝>

	[문제3] (20점)
	I. 논점의 정리
	토지보상법 시행규칙(이하 칙) 24조 불법형질변경토지의 평가기준에 대해 설명하고, 사안의 손실보상액이 정당한 보상인지 불법형질변경토지 입증책임과 관련하여 검토한다.
	II. 불법형질변경토지의 보상평가기준(칙24조)
	1. 의의·취지
	불법형질변경토지란 관계법령에 의해 허가를 받거나 신고를 받고 토지의 형질변경을 하여야 함에도 허가 등을 받지 아니하고 형질변경을 한 토지를 말한다. 불법형질변경토지의 보상은 현황평가의 예외가 적용되는데 이는 위법행위의 합법화에 따른 불합리한 보상 방지에 그 취지가 있다.
	2. 보상평가기준
	토지가 형질변경 당시의 이용상황을 상정하여 평가한다. 다만, 1995.1.7. 당시 공익사업 시행지구에 편입된 불법형질변경토지는 현실적 이용상황을 기준으로 평가한다(부칙 6조).
	3. 입증책임
	견해대립 있으나 현황평가의 예외인바 사업시행자가 입증하는 견해가 타당(판례)하다.

	4. 관련문제
	①제3자가 불법형질변경한 경우에도 동 규정을 그대로 적용(불법형질변경토지와 동일하게 평가)하며, ②사업인정 후 형질변경허가를 득하지 않은 지목변경토지도 불법형질변경토지와 동일하게 평가한다.
	Ⅲ. 사안의 손실보상액의 부당성
	1. 판례(사업시행자의 불법형질변경토지 입증책임)
	토지에 대한 보상액은 현실적인 이용상황에 따라 산정하는 것이 원칙이다. 따라서, 현황평가의 예외인 시행규칙 24조를 적용하여 평가하는 것은 예외적인 보상액 산정방법의 적용을 주장하는 쪽에서 증명해야 한다. 그리고 수용대상 토지가 불법형질변경토지에 해당한다고 인정하기 위해서는 단순히 수용대상 토지의 형질이 공부상 지목과 다르다는 점만으로는 부족하고, 수용대상 토지의 형질변경 당시 관계 법령에 의한 허가 또는 신고의무가 존재하였고 그럼에도 허가를 받거나 신고를 하지 않은 채 형질변경이 이루어졌다는 점이 증명되어야 한다.
	2. 사안 검토
	사안에서 甲의 토지가 과수원으로 개간되던 당시에 시행되던 법령에 의할 때 그 개간이 허가대상이라는 점을 국민임

	대주택단지 조성사업의 사업시행자인 인천도시공사가 입증해야한다. 그런데 입증하지 못한 상태에서 단순히 공부상 지목과 다르다는 점을 들어 불법형질변경토지의 보상평가기준으로 손실보상액을 산정하였으므로 이는 정당한 보상이라 보기 어렵다.
	<끝>
	[문제4] (10점)
	I. 의의 및 성격
	개간비란 토지의 매립, 간척 등 개간에 소요되는 비용이다. 실비변상적 성격을 갖는다.
	II. 토지보상법 시행규칙 27조 검토
	①국유지 또는 공유지를 관계법령에 의하여 적법하게 개간한 자가 개간당시부터 보상당시까지 계속하여 적법하게 당해 토지를 점유하고 있는 경우 개간에 소요된 비용(이하 "개간비"라 한다)은 이를 평가하여 보상하여야 한다. 이 경우 보상액은 개간후의 토지가격에서 개간전의 토지가격을 뺀 금액을 초과하지 못한다. ②개간비를 평가함에 있어서는 개간전과 개간후의 토지의 지세·지질·비옥도·이용상황 및 개간의 난이도 등을 종합적으로 고려하여야 한다. ③개간비를 보상하는 경우 취득하는 토지의 보상액은 개간후의

토지가격에서 개간비를 뺀 금액으로 한다.

Ⅲ. 요건

①국공유지를 ②적법하게 개간한 자가 ③개간 시부터 보상 시까지 적법하게 계속 점유할 것을 요한다.

Ⅳ. 평가방법 및 개간지 보상

<원칙>가격시점 기준 개간에 통상 필요한 비용 상당액 기준으로 한다. <예외>개간비를 알 수 없을 때 개간 후 토지의 일정비율로 평가하며 개간 전후 가격차이를 한도로 한다. 개간비 평가 시 개간전과 후의 토지의 지세·지질·비옥도·이용상황 및 개간의 난이도 등을 종합적으로 고려하여야 한다. 개간지 보상은 개간 후 토지가격에서 개간비를 뺀 금액으로 하며 이중보상 방지 규정이다.

Ⅴ. 관련판례

점용기간 만료 또는 점용을 폐지하였을 때에는 즉시 원상복구할 것이라는 부관을 붙인 사안 그에 관한 개간비보상청구권을 포기하는 것을 조건으로 한 것이다.

<이하여백>

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
3교시	100분	③ 감정평가법규
수험번호		성 명

【문제 1】 국토부장관은 2013. 11. 18. 사업시행자를 'A공사'로, 사업시행지를 'X시 일대 8,958,000㎡'로, 사업시행기간을 '2013. 11.부터 2017. 12. 까지'로 하는 '공익사업'에 대해서 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 사업인정을 고시하였고, 사업시행기간은 이후 '2020. 12.까지'로 연장되었다. 甲은 (가)토지 78,373㎡와 (나)토지 2,334㎡를 소유하고 있는데, (가)토지의 전부와 (나)토지의 일부가 사업시행지에 포함되어 있다. 종래 甲은 (가)토지에서 하우스 미나리농사를 지어 왔고, (나)토지에서는 농작물직거래판매장을 운영하여 왔다. 甲과 A공사는 사업시행지 내의 토지에 대해 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 협의 매수를 하기 위한 협의를 시작하였다. 다음 물음에 답하시오.(아래의 물음은 각 별개의 상황임) (40점)

물음 1) 협의 과정에서 일부 지장물에 관하여 협의가 이루어지지 않아 甲이 A공사에게 재결신청을 청구했으나 A공사가 재결신청을 하지 않는 경우, 甲의 불복 방법에 관하여 검토하시오. (15점)

물음 2) 협의가 성립되지 않아 사업시행지 내의 (나)토지의 일부가 수용되었다. 그 후 甲은 (나)토지의 잔여지에 대해서 2020. 11. 12. 잔여지수용청구를 하였다. 잔여지수용청구권의 법적 성질과 甲의 잔여지수용청구가 인정될 수 있는지를 검토하시오. (15점)

물음 3) 수용재결이 있는 후 A공사는 甲에게 보상금 지급도 하지 않고 승낙도 받지 않은 채 공사에 착수하여 甲이 영농을 계속할 수 없게 하였다. 甲은 농업손실보상과 별도의 손해배상책임을 주장한다. 甲의 주장은 타당한지 검토하시오. (10점)

【문제 2】인천도시공사는 인천 서구 오류동 일대 인천검단 일반지방산업단지 조성사업(이하 '이 사건 사업'이라 한다)의 사업시행자이다. 甲은 이 사건 사업인정고시일인 2006. 12. 26. 당시 이 사건 사업지구 내에 있는 인천 서구 오류동 (지번 1 생략) 토지에서 일정한 영업시설을 갖추고 제재목과 합판 등의 제조 및 판매업을 영위하고 있었다. 사업인정고시일 이후 위 토지에서 임대차계약기간이 만료되자 甲은 2007년 5월경 같은 사업지구 내에 속하는 같은 동 (지번 2 생략) 토지로 영업장소를 이전하여 기존 상호대로 이미 사용하던 시설 등을 옮겨 동일한 영업을 해왔다. 甲은 영업보상을 요구하면서 수용재결을 청구하였으나 관할 토지수용위원회가 甲의 영업장은 임대기간이 종료되어 이전한 것으로 공익사업의 시행으로 손실이 발생한 것이 아니라는 이유로 甲의 청구를 기각하였다. 다음 물음에 답하시오. (30점)

물음1) 토지보상법상 영업손실보상에 대하여 설명하시오. (20점)

물음2) 영업손실 보상 대상 여부의 판단 기준일을 토대로 甲이 영업보상 대상이 되는지 검토하시오. (10점)

【문제 3】 다음 물음에 답하시오. (20점)

① 사업인정 및 고시

- 사업명 : 화성동탄2지구 택지개발사업 <23차>(이하 '이 사건 사업'이라 한다)
- 고시 : 2008. 7. 11. 국토해양부 고시 제2008-308호
- 사업시행자 : 피고, 경기도시공사

② 중앙토지수용위원회의 2010. 11. 19.자 수용재결

(이하 '이 사건 수용재결'이라 한다)

- 보상대상 : 원고가 화성시 (주소 1 생략) 토지 일대에서 운영하는 '○○○○클럽' 골프장(이하 '이 사건 골프장'이라 한다)의 지장물 중 [별지 1] 목록 순번 1 내지 6, 8 내지 20 기재 각 지장물
- 보상금 : 4,479,740,360원
- 수용개시일 : 2011. 1. 12.
- 감정평가법인 : 주식회사 대화감정평가법인, 한국감정원

③ 중앙토지수용위원회의 2011. 4. 1.자 이의재결

(이하 '이 사건 이의재결'이라 한다)

- 보상대상 : [별지 1] 목록 순번 1 내지 6, 8 내지 20 기재 각 지장물
- 보상금 : 4,505,599,500원 (원고는 위 각 지장물을 새로 설치하는 공사비 상당액을 보상액으로 평가해 달라고 요청하였으나, 중앙토지수용위원회는 위 각 지장물의 가격 범위 내에서 이전비로 평가한 금액을 보상금으로 정하였다)

물음1) 원심은 이 사건 수용재결과 이의재결은 수용되는 이 사건 골프장 부지 위에 설치된 원심판결 [별지 1] 목록 순번 1 내지 6, 8 내지 20 기재 각 지장물 (이하 '이 사건 지장물'이라 한다)을 토지보상법 제75조 제1항에 따라 보상하는 내용이고 원고는 토지보상법 제75조의2 제1항이 규정한 잔여 건축물의 손실에 관하여는 재결절차를 거치지 않았다는 이유를 들어 이 사건 이의재결을 다투는 이 사건 소송에서는 잔여 건축물 손실에 대한 보상금의 지급을 청구할 수 없다고 판단하였다. 토지보상법상 잔여건축물 손실보상에 대해 설명하고, 원심 법원의 판단은 타당한지 검토하시오. (10점)

물음2) 건축허가 후 건축행위에 착수하지 아니하고 있는 사이 토지보상법상 사업인정고시가 된 경우 고시된 토지에 건축물을 건축하려는 자는 토지보상법 25조의 허가를 따로 받아야하는지, 이때 건축허가를 손실보상 대상에서 제외한다면 신뢰보호 원칙에 반하는지 검토하고, 보상계획 공고 이후 설치한 지장물이 손실보상 대상이 되는지 검토하시오. (10점)

【문제 4】 무허가건축물등이 토지보상법상 보상대상인지를 설명하시오. (10점)

	[문제1] 40점
	<물음1> 15점
	I. 논점의 정리
	A공사의 재결신청을 하지 않은 것이 부작위에 해당하는지 검토 후 불복방법으로, 의무이행심판, 부작위위법확인소송, 의무이행소송 등을 검토한다.
	II. A공사의 부작위
	1. 부작위의 의의 및 성립요건(행정소송법 2조 1항 2호)
	부작위는 행정청이 당사자의 신청에 대해 상당한 기간 내 일정한 처분을 해야 할 법률상 의무가 있음에도 이를 하지 않는 것을 의미한다. 당사자의 신청, 상당한 기간, 법률상 의무, 무응답의 존재가 필요하다.
	2. A공사가 재결신청 할 법률상 의무가 있는지
	판례에 따르면 협의기간 중이라도 협의성립 가능성이 없음 이 명백한 경우 피수용자는 재결신청 청구를 할 수 있고, 사업기간 내(재결신청 기간) 사업시행자는 재결신청 청구를 받은 날로부터 60일 내 재결신청을 할 의무가 있다(토지보상법30조1항). 甲의 재결신청 청구는 토지보상법령 및 판례에 부합하는 적법한 청구에 해당하므로, A공사는 재결신청을 해야 할 법률상 의무가 있다.

3. 甲의 법규상 조리상 신청권	
위 신청권 요부에 대해 견해가 대립하나, 판례는 일반적 추상적 응답신청권으로 h아 필요하다고 본다. 판례의 태도가 타당하며, 甲에게는 토지보상법 30조 1항의 신청권이 있다.	
4. 기타부작위 요건 검토	
나머지 당사자 신청, 상당한 기간, 무응답의 존재는 충족되는바, 사안의 A공사의 부작위는 행정소송법 2조1항2호에 해당한다.	
Ⅲ. 부작위위법확인소송(행정소송법 38조2항 등)	
부작위위법 확인소송은 행정청의 부작위가 위법하다는 것을 확인하는 소송으로 행정청이 신청에 따른 일정 처분을 하여야 함에도 아무런 응답을 하지 않는 것이 위법하다는 확인을 구하는 소송이다. 대상적격 및 원고적격 등 소송요건을 갖춘 것으로 보이며, 소송의 심리범위에 관하여, 판례는 그 부작위가 위법하다는 것을 확인함으로써 행정청의 응답을 신속하게 하여 부작위 또는 무응답이라는 소극적인 위법상태를 제거하는 것을 목적으로 한다고 하여 절차적 심리설을 취하므로, 甲은 부작위위법확인소송으로 권리구제 가능하다.	
Ⅳ. 의무이행심판(행정심판법 5조3호)	

	의무이행심판이란 당사자의 신청에 대한 행정청의 위법 또는 부당한 거부처분이나 부작위에 대해 일정한 처분을 하도록 하는 행정심판을 의미한다. A공사는 재결신청할 법률상의 의무가 있으므로, 甲은 의무이행 심판을 불복방법으로 고려할 수 있다.
	V. 의무이행소송 등
	법원의 판결에 의해 행정청으로 하여금 그 거부나 방치된 행정행위를 하여 줄 것을 구하는 내용의 행정소송으로 인정 여부에 대해 부정설, 긍정설, 제한적 긍정설이 대립하나, 판례는 검사에게 압수물 환부를 이행하라는 청구는 행정소송법상 허용되지 아니한다고 하여 부정설의 입장이다. 생각건대, 현행 행정소송법 규정 아래에서는 의무이행소송은 인정되기 어렵고, 입법적 해결이 필요하다.
	VI. 관련 판례(거부처분취소소송)
	판례는 토지소유자나 관계인의 재결신청 청구에도 불구하고 사업시행자가 재결신청을 하지 않을 때 토지 소유자나 관계인은 사업시행자를 상대로 거부처분 취소소송 또는 부작위 위법확인소송의 방법으로 다투어야 한다고 판시한 바 있다. 사안의 재결신청을 하지 않은 것을 묵시적 거부처분으로 볼 경우, 취소소송의 방법으로 불복할 수 있다.

	<물음2>15점
	I. 잔여지수용청구권의 법적성질
	1. 의의 및 근거
	잔여지수용청구권이란, 동일한 토지 소유자에게 속하는 수용 목적물인 일단의 토지 일부가 수용됨으로 인하여 잔여지를 종래 목적에 사용하는 것이 현저히 곤란한 때, 사업인정 이후 토지소유자가 관할 토지수용위원회에 수용을 청구할 수 있는 권리를 말한다. 사업시행자에게 하는 잔여지매수청구권과 구별되며, 토지보상법 74조에 근거를 둔다.
	2. 법적성질
	1) 형성권
	판례는 잔여지 수용청구권이 그 요건을 구비한 때에는 토지수용위원회의 특별한 조치를 기다릴 것 없이 청구에 의하여 수용의 효과가 발생하므로, 이는 형성권적 성질을 가진다고 판시하여 공용수용설 입장이라고 할 수 있다.
	2) 공권
	잔여지수용은 피수용자에 대한 권리구제의 보충적 필요에 의의가 있으므로 본래의 수용개념과는 구별되나, 피수용자의 청구를 요건으로 한 사업시행자의 권리취득행위이므로 공권으로 봄이 타당하다.

	Ⅱ. 甲의 잔여지수용청구가 인정될 수 있는지
	1. 수용청구의 요건(토지보상법 74조1항)
	일단의 토지의 일부가 수용됨으로 인하여 잔여지를 종래의 목적에 사용하는 것이 현저히 곤란할 때이며, 수용청구는 매수에 관한 협의가 성립되지 않은 때 가능하고, 사업완료일까지 하여야 한다(74조 1항). 판례는 '종래의 목적'이라 함은 수용재결 당시에 해당 잔여지가 현실적으로 사용되고 있는 구체적 용도를 사용하는 것이 현저히 곤란한 때라 함은 물리적으로 사용하는 것이 곤란하게 된 경우는 물론 사회적 경제적으로 사용하는 것이 곤란하게 된 경우도 포함한다고 본다.
	2. 토지보상법 시행령 39조
	토지보상법 시행령 39조 1항은 종래의 목적대로 사용하는 것이 현저히 곤란할 때를 구체화하였다. 대지로서 면적이 너무 작거나 부정형 등의 사유로 건축물을 건축할 수 없거나 건축물의 건축이 현저히 곤란한 경우, 농지로서 농기계의 진입과 회전이 곤란할 정도로 폭이 좁고 길게 남거나 부정형 등의 사유로 영농이 현저히 곤란한 경우 등을 규정하고 있으며, 잔여지를 판단할 때에는 잔여지의 위치,형상, 이용상황 및 용도지역, 공익사업 편입토지 면적 및 잔여지 면적을 종합적으로 고려하여야 한다(령 39조2항).

3. 甲의 잔여지수용청구 인정여부 및 불복방법	
사안의 경우, 사업완료 전이며, 나토지의 편입면적, 잔여지 비율 등을 확인할 수 없으나, 농작물직거래판매장이라는 종래 목적대로 사용하지 못하는 경우 잔여지수용청구가 인정될 것이다. 아울러, 판례에 따르면 위 청구가 인정되지 않을 경우 적법한 소송수단은 취소소송이 아니라 보상금 증액청구소송이 되어야 한다.	
<물음3> 10점	
I. 농업손실보상 의의 및 법적성질	
농업손실보상이란 공익사업 시행지구에 편입되는 농지에 대해 영농을 계속하지 못함에 따른 농업의 손실을 보상하는 것이다. 생활재건조치, 일실손실의 지급이라는 측면에 취지가 있다. 부대적 손실보상 중 일실손실보상, 생활보상 성격이 있다. 손실보상청구권 성격 관련 공권력 행사인 공용침해로 인하여 발생한 권리로 공익성이 고려되어야 한다는 <공권설;판례>과 사법상 금전지급청구권과 다르지 않다고 보는 <사권설>이 있다.	
II. 관련규정	
1. 농업손실보상(토지보상법 77조 2항)	
농업의 손실에 대하여는 농지의 단위면적당 소득 등을 고려	

	하여 실제 경작자에게 보상하여야 한다. 다만, 농지소유자가 해당 지역에 거주하는 농민인 경우에는 농지소유자와 실제 경작자가 협의하는 바에 따라 보상할 수 있다.
	2. 사전보상 원칙(토지보상법 62조)
	사업시행자는 해당 공익사업을 위한 공사에 착수하기 이전에 토지소유자와 관계인에게 보상액 전액(全額)을 지급하여야 한다. 다만, 제38조에 따른 천재지변 시의 토지 사용과 제39조에 따른 시급한 토지 사용의 경우 또는 토지소유자 및 관계인의 승낙이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
	Ⅲ. 관련판례
	공익사업을 위한 공사는 손실보상금을 지급하거나 승낙을 받지 않고는 미리 착공해서는 아니 되는 것으로 보상금을 지급하지 아니하고 그 승낙도 받지 아니한 채 미리 공사에 착수하여 영농을 계속할 수 없게 하였다면 사전보상의 원칙을 위반한 것으로서 위법한바 영농손실보상금을 지급하는 것과 별도로 공사의 사전착공으로 인하여 영농을 할 수 없게 된 때부터 수용개시일까지 입은 손해에 대하여 이를 배상할 책임이 있다.
	IV. 사안 검토

수용재결이 있는 후 A공사는 甲에게 보상금 지급도 하지 않고 승낙도 받지 않은 채 공사에 착수하여 甲이 영농을 계속할 수 없게 하였는바, 사전보상 원칙 및 판례 입장에 따라 손실보상과 별도의 손해배상책임이 있다. 甲의 주장은 타당하다.

<끝>

[문제2] 30점

<물음1> 20점

I. 영업손실보상의 의의(토지보상법 77조 1항)

영업손실보상이란 공익사업 시행에 따라 영업을 폐지 또는 휴업하게 되는 경우 발생하는 손실 보상하는 것이다. 합리적 기대이익 상실이라는 점에서 일실손실보상 성격을 갖으며 구체적 내용에 따라 생활보상의 성격과 간접보상의 성격도 가지고 있다.

II. 영업손실보상의 요건(토지보상법 시행규칙 45조)

<1호>사업인정고시일 등 전부터 적법한 장소에서 인적·물적 시설을 갖추고 계속적으로 행하고 있는 영업 (무허가건축물 등 임차인 영업의 경우 사업인정고시일 등 1년 전부터 사업자 등록을 하고 행하는 영업)일 것, <2호>관계법령

	에 의한 허가 등을 필요로 하는 영업의 경우 사업인정고시
	일 등 전에 허가를 받아 그 내용대로 행하고 있는 영업(동
	법 시행규칙 52조 적법한 장소에서의 무허가영업 특례 있
	음)일 것을 요건으로 한다.
	Ⅲ. 영업손실보상의 종류
	1. 폐업보상(토지보상법 시행규칙 46조)
	1)요건(칙46조)
	①영업장소 또는 배후지의 특수성으로 인하여 당해 영업소
	가 소재하고 있는 시·군·구 또는 인접 시·군·구의 지역
	안의 다른 장소에 이전하여서는 당해 영업을 할 수 없는 경
	우 ②당해 영업소가 소재하고 있는 시·군·구 또는 인접
	시·군·구의 지역안의 다른 장소에서는 당해 영업의 허가
	등을 받을 수 없는 경우 ③도축장 등 악취 등이 심하여 인
	근주민에게 혐오감을 주는 영업시설로서 해당 영업소가 소
	재하고 있는 시·군·구 또는 인접 시·군·구의 지역안의
	다른 장소로 이전하는 것이 현저히 곤란하다고 특별자치도
	지사·시장·군수 또는 구청장이 객관적인 사실에 근거하여
	인정하는 경우를 요건으로 한다.
	2)폐업보상 여부
	폐업과 휴업의 구별 기준은 이전가능성에 달려 있고, 이전

	가능성 여부는 법령상 이전장애사유 유무와 사실상 이전장애사유 유무 등을 종합 판단하여야 한다.
	3)보상액
	2년간 영업이익에 영업용 고정자산·원재료·제품·상품 등의 매각손실액을 더한 금액으로 평가한다(칙46조1항).
	2. 휴업보상(토지보상법 시행규칙 47조)
	1)의의
	휴업보상은 공익사업 시행으로 영업이 일정기간 휴업하는 경우에 대한 보상이다. 영업장소 이전(1항-영.감.고.이.부), 시설물의 일부편입(3항), 임시영업소 설치(4항) 시 각각 일정액을 보상한다.
	2)휴업기간(칙47조2항)
	①휴업기간은 4개월이내를 원칙으로 한다. ②해당 사업으로 인하여 4개월 이상의 기간동안 영업불가 ③대규모·이전에 고도의 정밀성 등 고유의 특수성으로 4개월 이내 이전곤란이 객관적으로 인정된 경우 실제 휴업기간으로 하되 그 휴업기간은 2년을 초과할 수 없다.
	3)일부편입(칙47조3항)

①	일부편입에 따른 영업손실 보상은 시설의 일부가 편입됨으로 인해 잔여시설에 그 시설을 새로 설치하거나 잔여시설을 보수하지 않고는 그 영업을 계속할 수 없는 경우의 영업손실 및 영업규모 축소에 따른 영업손실이다.
②	해당 시설의 설치 등에 소요되는 기간의 영업이익, 해당 시설의 설치 등에 통상 소요되는 비용, 영업규모의 축소에 따른 영업용 고정자산·원재료·제품 및 상품 등의 매각손실액(칙47조3항)과 그 보수기간 중의 인건비 등 고정적 비용을 보상한다.
	3. 무허가 건축물 임차인의 영업에 대한 보상
①	<폐업보상> 폐업보상액 중 매각손실 제외한 금액은 1천만원 초과하지 못한다(칙46조5항).
②	<휴업보상> 영업시설의 이전비용 및 감손상당액을 제외한 금액은 1천만원 초과하지 못한다(칙47조6항).
	4. 무허가영업의 손실보상에 관한 특례(칙52조)
①	사업인정고시일등 전부터 허가 등을 받아야 행할 수 있는 영업을 허가등 없이 행하여 온 자가 공익사업의 시행으로 인하여 적법한 장소에서 영업을 계속할 수 없게 된 경우에는 「통계법」에 따른 가계조사통계의 도시근로자가구 월평균 가계지출비를 기준으로 산정한 3인 가구 3개월분 가계지출

	비에 해당하는 금액을 영업손실에 대한 보상금으로 지급하
	되, 영업시설 등의 이전비용은 별도로 보상한다(칙 제52조
	본문) ②본인 또는 생계를 같이 하는 동일 세대안의 직계존
	속·비속 및 배우자가 해당 공익사업으로 다른 영업에 대한
	보상을 받은 경우에는 영업시설 등의 이전비용만을 보상하
	여야 한다(칙 제52조 단서).
	<물음2> 10점
	I. 관련규정
	1. 토지보상법 77조1항
	영업을 폐업하거나 휴업함에 따른 영업손실에 대하여는 영
	업이익과 시설의 이전비용 등을 고려하여 보상하여야 한다.
	2. 토지보상법 시행규칙 45조 1호
	법 제77조제1항에 따라 영업손실을 보상하여야 하는 영업
	은 사업인정고시일등 전부터 적법한 장소(무허가건축물 등,
	불법형질변경토지, 그 밖에 다른 법령에서 물건을 쌓아놓는
	행위가 금지되는 장소가 아닌 곳을 말한다)에서 인적·물적
	시설을 갖추고 계속적으로 행하고 있는 영업을 의미하며 허
	가등이 필요한 경우 사업인정고시일등 전에 허가등을 받아
	그 내용대로 행하고 있는 영업을 의미한다.

Ⅱ. 관련판례

공익사업의 시행으로 인한 영업손실 및 지장물 보상의 대상 여부는 사업인정고시일을 기준으로 판단해야 하고, 사업인정고시일 당시 보상대상에 해당한다면 그 후 사업지구 내 다른 토지로 영업장소가 이전되었다고 하더라도 이전된 사유나 이전된 장소에서 별도의 허가 등을 받았는지를 따지지 않고 여전히 손실보상의 대상이 된다. 사업인정고시일 이후 영업장소 등이 이전되어 수용재결 당시에는 해당 토지 위에 영업시설 등이 존재하지 않게 된 경우 사업인정고시일 이전부터 그 토지 상에서 영업을 해 왔고 그 당시 영업을 위한 시설이나 지장물이 존재하고 있었다는 점은 이를 주장하는 자가 증명하여야 한다.

Ⅲ. 사안의 검토

관련규정 및 판례에 의하면 영업손실보상 대상 여부는 사업인정고시일을 기준으로 판단한다. 甲은 이 사건 사업인정고시일인 2006. 12. 26. 당시 이 사건 사업지구 내에 있는 인천 서구 오류동 (지번 1 생략) 토지에서 일정한 영업시설을 갖추고 제재목과 합판 등의 제조 및 판매업을 영위하고 있었던 자로, 영업보상 대상이 된다.

<끝>

	[문제3] 20점
	<물음1> 10점
	I. 잔여건축물의 손실에 대한 보상(법75조의2, 칙35조)
	1. 잔여건축물의 손실보상
	1) 의의·요건
	동일한 소유자에 속하는 일단의 건축물의 일부가 취득·사용됨으로 인하여 잔여 건축물의 가격이 감소하거나 그 밖의 손실이 있을 때 그 손실을 보상하는 것이다. 잔여 건축물의 손실에 대해서는 해당 사업의 공사완료일부터 1년이 지난 후에는 청구할 수 없다(제75조의2 제4항에서 제73조 제2항을 준용). 잔여 건축물 가격감소분과 보수비의 합이 잔여 건축물 가격보다 큰 경우 사업시행자는 그 잔여 건축물을 매수할 수 있다.
	2) 보수비
	건축물의 나머지 부분을 종래의 목적대로 사용할 수 있도록 그 유용성을 동일하게 유지하는 데에 일반적으로 필요하다고 볼 수 있는 공사에 사용되는 비용을 말한다. 다만, 「건축법」 등 관계 법령에 따라 요구되는 시설 개선에 필요한 비용은 포함하지 아니한다. 정당보상 넘어선 과도한 보상으로 헌법적 측면에서 타당하다.

	2. 잔여건축물 수용
	1) 의의·요건
	동일한 소유자에게 속하는 일단의 건축물의 일부가 협의에 의하여 매수되거나 수용됨으로 인하여 <잔여건축물을 종래의 목적에 사용하는 것이 현저히 곤란할 때> 건축물 소유자가 사업시행자에게 잔여건축물을 매수하여 줄 것을 청구하는 것을 말한다.
	2) 절차
	사업인정 전 그 건축물소유자는 사업시행자에게 잔여 건축물을 매수하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사업인정 이후에는 관할 토지수용위원회에 수용을 청구할 수 있다. 이 경우 수용 청구는 매수에 관한 협의가 성립되지 아니한 경우에만 하되, 사업완료일까지 하여야 한다.
	Ⅱ. 관련판례 및 재결 전치주의
	잔여건축물 가격감소 등으로 인한 손실보상을 받기 위해서는 재결절차를 거친 다음 재결에 대하여 불복이 있는 때에 권리구제를 받을 수 있을 뿐, 재결절차를 거치지 않은 채 사업시행자를 상대로 손실보상을 청구하는 것은 허용되지 않고 이는 건축물에 대하여 재결절차를 거친 경우에도 마찬가지이다. 행정소송을 제기하기 앞서 토지수용위원회의 재

	결을 거쳐야 하는 것을 의미하며, 토지보상법 85조 1항도 불복의 대상을 84조 재결이 아닌 34조 재결이라고 규정하는바, 재결 전치주의를 취한 것으로 볼 수 있다.
	Ⅲ. 사안 검토
	관련 규정 및 판례에 따라 잔여 건축물 손실에 관하여 재결 절차를 거치지 않고 곧바로 행정소송을 제기할 수 없다. 건축물의 손실에 관하여는 재결절차를 거치지 않았다는 이유를 들어 이 사건 이의재결을 다투는 이 사건 소송에서 잔여 건축물 손실에 대한 보상금의 지급을 청구할 수 없다고 판단한 원심 법원 판단은 타당하다.
	<물음2>10점
	I. 토지보상법 25조
	① 사업인정고시가 된 후에는 누구든지 고시된 토지에 대하여 사업에 지장을 줄 우려가 있는 형질의 변경이나 제3조 제2호 또는 제4호에 규정된 물건을 손괴하거나 수거하는 행위를 하지 못한다. ② 사업인정고시가 된 후에 고시된 토지에 건축물의 건축·대수선, 공작물(工作物)의 설치 또는 물건의 부가(附加)·증치(增置)를 하려는 자는 특별자치도지사, 시장·군수 또는 구청장의 허가를 받아야 한다. 이 경우 특별자치도지사, 시장·군수 또는 구청장은 미리 사업시행

	자의 의견을 들어야 한다. ③ 제2항을 위반하여 건축물의
	건축·대수선, 공작물의 설치 또는 물건의 부가·증치를 한
	토지소유자 또는 관계인은 해당 건축물·공작물 또는 물건
	을 원상으로 회복하여야 하며 이에 관한 손실의 보상을 청
	구할 수 없다.
	Ⅱ. 다시 허가를 받아야 하는지
	판례는 건축허가를 받았더라도 허가받은 건축행위에 착수하
	지 아니하고 있는 사이 토지보상법상 사업인정고시가 된 경
	우 고시된 토지에 건축물을 건축하려는 자는 토지보상법
	25조에 의거 허가를 다시 받아야 하고, 그 허가 없이 건축
	된 건축물에 관하여는 토지보상법상 손실보상을 청구할 수
	없다고 판시한바 있다. 관련규정과 판례에 따라 건축허가
	후 건축행위에 착수하지 아니하고 있는 사이 토지보상법상
	사업인정고시가 된 경우 다시 허가를 받을 필요가 있다.
	Ⅲ. 건축허가와 공적견해표명(신뢰보호원칙 검토)
	신뢰보호원칙이란 행정기관의 공적견해표명에 대해 국민이
	귀책사유 없이 신뢰하고 이에 어떠한 행위를 한 경우 그 신
	뢰를 보호하여 주어야 한다는 원칙이다. 행정기본법12조를
	근거로 하며 사안에서 건축허가를 손실보상에 대한 공적인
	견해표명으로 볼 수 있는지가 문제되나, 판례는 공적 견해

	표명이나 신뢰부여로 보기 어려우므로 손실보상 대상에서 이를 제외하더라도 신뢰보호 원칙에 반한다고 볼 수 없다고 판시하였다. 판례 입장이 타당하며, 신뢰보호 원칙에 반하지 않는다.
	IV. 보상계획 공고 후 설치한 지장물의 손실보상 대상여부
	1. 관련판례
	토지보상법 25조에 따르면 사업인정고시 전에 공익사업시행지구 내 토지에 설치한 공작물 등 지장물은 원칙적으로 손실보상의 대상이 된다고 보아야 한다. 그러나 손실보상은 공공필요에 의한 행정작용에 의하여 사인에게 발생한 특별한 희생에 대한 전보라는 점을 고려할 때 구 공익사업법 제 15조 제1항에 따른 사업시행자의 보상계획공고 등으로 공익사업의 시행과 보상 대상 토지의 범위 등이 객관적으로 확정된 후 해당 토지에 지장물을 설치하는 경우에 그 지장물이 해당 토지의 통상의 이용과 관계없거나 이용 범위를 벗어나는 것으로 손실보상만을 목적으로 설치되었음이 명백하다면, 그 지장물은 예외적으로 손실보상의 대상에 해당하지 아니한다고 보아야 한다.
	2. 사안 검토
	특별한 희생으로 보기 어려운바, 보상대상이 되지 않는다.

	[문제4] 10점
	I. 무허가건축물 등의 의의(토지보상법 시행규칙 24조)
	「건축법」 등 관계법령에 의하여 허가를 받거나 신고를 하고 건축 또는 용도변경을 하여야 하는 건축물을 허가를 받지 아니하거나 신고를 하지 아니하고 건축 또는 용도변경한 건축물이다.
	II. 무허가건축물 등의 보상여부
	1. 문제점
	무허가건축물 등은 불법건축물이다. 무허가건축물 등의 보상여부에 대해서는 명문 규정이 없기 때문에, 손실보상요건 중 허가유무에 따른 재산권 충족여부가 문제된다. 다만, 89. 1. 24 이전 건축된 무허가건축물 등은 적법건축물로 보므로, 보상대상이다.
	2. 견해대립 및 판례
	무허가건축물 등은 위반건축물로서 제재를 받을 따름이므로 보상에까지 확대하여 보상대상에서 제외할 이유는 없다는 보상대상이라는 견해와 토지보상법 25조 토지보전의무 해석에 따라 사업인정 전의 무허가건축물 등은 토지보상법상 보전의무의 대상이 되지 않으므로 보상의 대상이 된다는 견해(판례입장), 질서유지차원에서 적법한 건축물에 한하여 보

상대상이 된다는 견해가 있다. 생각건대 허가는 그 성질에 비추어 행위의 적법성 여부에만 관여하고 유효성 여부와는 무관하므로 재산권 요건을 충족하므로, 사업인정을 기준으로 하여 판단하는 견해가 타당하다.

Ⅲ. 무허가건축물 등의 보상평가기준

보상대상이 되는 무허가건축물 등은 당해 무허가건축물 등이 허가를 받지 않은 사정을 고려하지 않은 상태로 평가하여야 할 것이므로, 결국 평가방법에 있어 적법한 건축물의 평가방법과 동일한 평가방법을 적용해야 할 것이다.

<이하여백>

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
3교시	100분	③ 감정평가법규
수험번호		성 명

【문제 1】 「공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률」(이하 '토지보상법'이라 함)의 적용을 받는 공익사업으로 인하여 甲은 사업시행자인 한국철도시설공단 乙에게 협의절차를 통해 자신이 거주하고 있던 주거용 건축물을 제공하여 생활의 근거를 상실하게 되었다고 주장하면서 토지보상법 제78조 제1항에 따른 이주대책의 수립을 신청하였다. 이에 대해 乙은 "위 공익사업은 선형사업으로서 철도건설에 꼭 필요한 최소한의 토지만 보상하므로 사실상 이주택지공급이 불가능하고 이주대책대상자 중 이주정착지에 이주를 희망하는 자의 가구수가 7호(戶)에 그치는 등 위 공익사업은 토지 보상법 시행령 제40조 제2항에서 규정하고 있는 이주대책을 수립하여야 하는 사유에 해당되지 아니한다"는 이유를 들어 甲의 신청을 거부하였다. 다음 물음에 답하십시오. (40점)

1) 乙이 甲에 대한 거부처분을 하기에 앞서 행정절차법상 사전통지와 이유제시를 하지 아니한 경우 그 거부처분은 위법한가? (20점)

2) 만약 甲이 거부처분 취소소송을 제기하였다면, 乙은 그 소송 계속 중에 처분의 적법성을 유지하기 위해 "甲은 주거용 건축물에 계약체결일까지 계속하여 거주하고 있지 아니하였을 뿐만 아니라 이주정착지로의 이주를 포기하고 이주정착금을 받은 자에 해당하므로 토지보상법 시행령 제40조 제2항에 따라 이주대책을 수립할 필요가 없다"는 사유를 추가·변경할 수 있는가? (20점)

<공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률>

제78조(이주대책의 수립 등) ① 사업시행자는 공익사업의 시행으로 인하여 주거용 건축물을 제공함에 따라 생활의 근거를 상실하게 되는 자(이하 "이주대책대상자"라 한다)를 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 이주대책을 수립·실시하거나 이주정착금을 지급하여야 한다.

② <이하 생략>

<공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률 시행령>

제40조(이주대책의 수립·실시) ① <생략>

② 이주대책은 국토교통부령으로 정하는 부득이한 사유가 있는 경우를 제외하고는 이주대책대상자 중 이주정착지에 이주를 희망하는 자의 가구 수가 10호(戶) 이상인 경우

에 수립·실시한다. <이하 생략>

제41조(이주정착금의 지급) 사업시행자는 법 제78조제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이주대책대상자에게 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 이주정착금을 지급하여야 한다.

1. 이주대책을 수립·실시하지 아니하는 경우
2. 이주대책대상자가 이주정착지가 아닌 다른 지역으로 이주하려는 경우

<행정절차법>

제21조(처분의 사전 통지) ① 행정청은 당사자에게 의무를 부과하거나 권익을 제한하는 처분을 하는 경우에는 미리 다음 각 호의 사항을 당사자등에게 통지하여야 한다.

1. 처분의 제목
2. 당사자의 성명 또는 명칭과 주소
3. 처분하려는 원인이 되는 사실과 처분의 내용 및 법적 근거
4. 제3호에 대하여 의견을 제출할 수 있다는 뜻과 의견을 제출하지 아니하는 경우의 처리방법
5. 의견제출기관의 명칭과 주소
6. 의견제출기한
7. 그 밖에 필요한 사항

제23조(처분의 이유 제시) ① 행정청은 처분을 할 때에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 당사자에게 그 근거와 이유를 제시하여야 한다.

1. 신청 내용을 모두 그대로 인정하는 처분인 경우
 2. 단순·반복적인 처분 또는 경미한 처분으로서 당사자가 그 이유를 명백히 알 수 있는 경우
 3. 긴급히 처분을 할 필요가 있는 경우
- ② 행정청은 제1항제2호 및 제3호의 경우에 처분 후 당사자가 요청하는 경우에는 그 근거와 이유를 제시하여야 한다.

【문제 2】 가. 원고는 호남고속철도(오송~광주송정)가 통과하는 □□ ~ ◇◇ 구간(이하 '이 사건 노선'이라 한다) 중 6공구로부터 최소 25m부터 최대 45m 지점에 위치한 원고 소유의 김제시 (주소 생략) 목장용지 4,365㎡(이하 '이 사건 토지'라 한다) 지상에서 '☆☆잠업사'(이하 '이 사건 잠업사'라 한다)라는 상호로 양잠업을 하고 있는 사람이다. 이 사건 잠업사는 전라북도 양잠농가에 보급잠종을 공급하는 유일한 업체이다.

나. 피고 한국철도시설공단(이하 '피고 공단'이라 한다)은 철도산업발전기본법 및 한국철도시설공단법에 의하여 철도시설의 건설 및 관리와 그 밖에 이와 관련되는 사업을 효율적으로 시행함으로써 국민의 교통편의를 증진하고 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 설립된 법인이다.

다. 국토해양부장관은 2009. 4. 16. 국토해양부고시 제2009-185호로 충청북도 청원군, 충청남도 연기군, 공주시, 논산시, 전라북도 익산시, 김제시, 정읍시, 전라남도 장성군, 광주광역시 광산구 일원 7,765,426㎡에 피고 공단을 사업시행자로 하여 고속철도를 건설하는 내용의 '호남고속철도 건설사업(오송~광주송정)'(이하 '이 사건 사업'이라 한다)에 대한 실시계획을 승인하고 이를 고시하였다.

라. 이 사건 토지는 이 사건 사업의 사업구역에 포함되지 아니하였다.

마. 원고는 <① 피고 공단의 호남고속철도 공사와 피고 공사의 호남고속철도 운행은 모두 공익사업에 해당하므로, 피고들은 공동하여 원고에게 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률(이하 '토지보상법'이라 한다) 제79조 제2항에서 정한 손실보상금을 지급할 의무가 있다. ② 피고 공단이 호남고속철도를 완공하고 피고 공사가 호남고속철도를 운행하여 수인한도를 초과하는 소음 및 진동이 발생하였고, 그로 인하여 원고의 손해가 발생하였으므로, 피고들은 공동하여 원고에게 손해배상금을 지급할 의무가 있다.>고 주장한다.

바. 사실확인 결과 이 사건 잠업사에 발생하는 최고소음도는 주간 및 야간의 경우 모두 소음·진동관리법령에서 정한 기준을 초과하고 있고, 실제로 국립농업과학원이 이 사건 잠업사의 유충 등 조사한 결과 발육지연, 기형, 이상증상 등이 발견되었다. 누에씨 보급을 맡고 있는 종자사업소는 이 사건 잠업사의 누에씨를 수용할 수 없다는 의견을 표시하였다. 다음 물음에 답하시오. (30점)

1) 공익사업시행지구 밖 간접손실보상에 대해 설명하고 간접손실보상 대상인지 검토하시오. (20점)

2) ①같은 내용의 손해에 관하여 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률(이하 토지보상법) 제79조 제2항에 따른 손실보상과 환경정책기본법 제

44조 제1항에 따른 손해배상청구권이 동시에 성립하는 경우, 영업자가 두 청구권을 동시에 행사할 수 있는지, 손실보상청구기간 도과 후 손해배상청구가 가능한지 검토하고, ②공익사업으로 인하여 공익사업시행지구 밖에서 영업을 휴업하는 자가 토지보상법 제34조, 제50조 등에 규정된 재결절차를 거치지 않은 채 곧바로 영업손실에 대한 보상을 청구할 수 있는지와 ③어떤 보상항목이 토지보상법상 손실보상대상에 해당함에도 관할 토지수용위원회가 그 대상에 해당하지 않는다고 잘못된 내용의 재결을 한 경우, 피보상자가 제기할 소송과 그 상대방을 검토하시오. (10점)

【문제 3】 X는 도시 및 주거환경정비법 (이하 '도시정비법'이라 함)에 따른 재개발정비사업조합이고, 甲은 X의 조합원으로서, 해당 정비사업구역 내에 있는 A토지의 소유자이다. A토지는 甲이 소유한 건축물의 부지로서 그 건축물의 일부에 임차인 乙이 거주하고 있다. X는 도시정비법 제72조 제1항에 따라 분양신청기간을 공고하였으나 甲은 그 기간 내에 분양신청을 하지 않았다. 이에 따라 X는 甲을 분양대상자에서 제외하고 관리처분계획을 수립하여 인가를 받았고, 그에 불복하는 행정심판이나 행정소송은 없었다. X는 도시정비법 제73조 제1항에 따른 甲과의 보상협의를 이루어지지 않자 A에 관하여 관할 토지수용위원회에 수용재결을 신청하였고, 관할 토지수용위원회는 A토지를 수용한다는 내용의 수용재결을 하였다. 주거이전비에 관하여 甲은 토지보상법 시행규칙 제54조 제1항에 따른 요건을 갖추고 있고, 乙은 같은 조 제2항에 따른 요건을 갖추고 있다. 관할토지수용위원회는 수용재결을 하면서 甲의 주거이전비에 관하여는 재결을 하였으나 乙의 주거이전비에 관하여는 재결을 하지 않았다. 甲은 주거이전비의 증액을 청구하고자 하고, 乙은 주거이전비의 지급을 청구하고자 한다. 甲과 乙의 권리구제에 적합한 소송을 설명하시오. (20점)

【문제 4】 도지사 A는 "X국가산업단지 내 국도 대체우회도로개설사업"(이하 '이 사건 개발사업'이라 함)의 실시계획을 승인·고시하고, 사업시행자로 B시의 시장을 지정하였다. B시의 시장은 이 사건 개발사업을 시행함에 있어 사업시행으로 인하여 건물이 철거되는 이주대상자를 위한 이주대책을 수립하면서 훈령의 형식으로 'B시 이주민지원규정'을 마련하였다. B시의 시장은 이주대책을 실시하면서 이 사건 개발사업 구역 내에 거주하는 甲에 대하여, 甲은 공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법령이 정한 이주대책대상자에 해당됨에도 불구하고 'B시 이주민지원규정'에서 정하는 요건을 이유로 이주대책대상자에서 배제하는 부적격 통보를 하였다. 甲은 'B시 이주민지원규정'에서 정한 추가적 요건을 이유로 자신을 이주대책 대상자에서 배제한 것은 위법하다고 주장한다. 甲의 주장이 타당한지에 관하여 설명하시오. (10점)

	[문제1]40점
	<물음1>20점
	I. 논점의 정리
	거부처분이 사전통지의 대상이 되는 권익을 제한하는 처분
	인지와 해당 거부처분시 이유제시를 하지 아니할 수 있는지
	가 문제된다.
	II. 이주대책수립 거부의 법적성질
	①甲은 공익사업으로 인한 주거용 건축물을 제공하여 생활
	의 근거지를 상실하였다. 따라서 토지보상법 제78조 제1항
	에 따라 사업시행자에게는 이주대책을 수립·실시할 의무가
	있으므로, 甲에게는 이주대책의 수립을 청구할 신청권이 인
	정된다. ②甲의 이주대책 수립에 대한 乙의 거부행위는 고
	권적 위치에서 행하는 구체적인 이주대책 수립에 대한 거부
	이며, ③이로써 甲은 권리의무에 영향을 받았으므로, 乙의
	거부는 처분성이 인정된다.
	III. 거부처분이 사전통지의 대상이 되는지
	1. 문제점
	행정절차법 제21조 제1항은 행정청의 사전통지 의무의 대
	상이 되는 처분을 의무를 부과하거나 권익을 제한하는 처분
	에 한정하고 있는바, 거부처분이 권익을 제한하는 처분에

해당하는지 문제된다.

2. 학설

①수익적 행정행위 거부의 경우에는 기존의 권익이 없고 신청 당시 의견진술의 기회가 부여되었다는 점을 논거로 부정하는 견해, ②신청시 수익적 처분 발령을 기대한다는 점에서 기대이익이 침해되므로 사전통지를 긍정하는 견해, ③거부처분에서는 사전통지를 원칙적으로 부정하나, 허가의 갱신과 같이 기존에 권익이 존재하는 경우에는 거부시 권익이 침해되므로 긍정하는 견해가 대립한다.

3. 판례

판례는 신청의 단계에는 아직 당사자에게 아무런 권익이 부여되어있지 않은 상태이며, 특별한 사정이 없는 한 신청에 대한 거부처분은 직접 당사자의 권익을 제한하는 것이 아니므로 사전통지 대상으로 볼 수 없다고 하여 ①설의 입장을 취한다.

4. 검토 및 사안의 경우

거부처분의 경우에도 특별한 기대이익이 있는 경우에는 긍정하는 것이 타당하므로 ③설의 입장이 타당하다. 사안에서 甲의 경우 기존에 수익적 처분이 발령된 바 없고, 이주대책

	의 수립을 청구하는 단계이므로 아무런 권익이 부여되어 있지 않아, 그 거부는 사전통지 대상이 되지 않는다.
	IV. 이유제시의무 위반 여부
	1. 乙의 이유제시 의무 및 이유제시의 정도
	행정절차법 제23조 제1항에서는 처분을 할 때에 당사자에게 그 근거와 이유를 제시할 것을 규정하고 있는바 乙의 거부행위는 처분에 해당하여 이유제시 의무가 발생하였다. 이유제시의 정도는 처분사유를 이해할 수 있도록 구체적으로 하되, 행정청이 처분결정시 고려한 사실상·법률상 근거를 알려야 한다(행정절차법 시행령 14조의2).
	2. 이유제시 생략사유 및 해당여부
	행정절차법 제23조 제1항에 따라 1. 신청 내용을 모두 그대로 인정하는 처분인 경우, 2. 단순·반복적인 처분 또는 경미한 처분으로서 당사자가 그 이유를 명백히 알 수 있는 경우, 3. 긴급히 처분을 할 필요가 있는 경우 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 이유제시를 생략할 수 있다. 사안의 경우 乙의 이주대책 수립신청에 대한 거부는 ① 甲의 신청내용을 모두 그대로 인정하는 처분에 해당하지 아니하고, ② 단순·반복적 처분 또는 경미한 처분에 해당하지 않으며, ③ 긴급성 또한 인정되지 아니한다. 따라서 이유제시를 생략할

수 있는 사유에 해당하지 않는다.

3. 이유제시 흠결의 하자 (절차상 하자)

행정청은 처분을 할 때에 그 이유를 제시하여야 한다. 이는 행정절차법 제23조에 근거 있으며, 이유제시를 결한 행정행위는 절차상 하자있는 행정행위가 된다. 사안의 경우, 甲의 이주대책 수립신청에 대해 乙이 거부처분을 하는 때에는 행정절차법 제23조에 따라 이유제시를 하여야 한다. 따라서 이유제시를 하지 아니한 乙의 거부처분에는 절차상 하자가 있는 행정행위가 된다.

4. 절차상 하자의 독자적 위법주장 가부

절차상 하자있는 행정행위의 독자적 위법성 여부에 대해 행정능률고 소송경제 측면에서 부정하는 견해, 기속행위의 경우 적법한 절차를 거쳐 다시 동일한 처분이 발령된다는 이유로 부정하는 견해 등이 있으나, 적벌절차의 원칙에 의거하여 긍정하는 견해가 통설이며, 대법원도 행정처분이 재량행위인 경우 뿐만아니라 기속행위인 경우에도 이유제시 흠결의 하자를 행정행위의 독자적 위법사유가 된다고 하여 긍정하는 입장을 취한바 있다.

V. 사안의 경우

1. 甲의 이주대책 수립신청에 대한 乙의 거부는 사전통지의 무 위반은 없으나 이유제시 의무 위반이 있어 절차상 하자 가 존재한다. 2. 대법원에 의하며 절차상 하자의 경우에도 독자적 위법사유 주장이 가능하다. 3. 따라서 乙의 거부처분 은 위법하며 그 정도는 중대·명백설에 따라 판단될 것이다.
<물음2> 20점
I. 논점의 정리
처분사유 추가변경의 허용여부와 그 한계가 문제된다.
II. 처분사유 추가변경의 허용여부
1. 문제점
처분사유 추가변경은 소송계속 중 처분의 기초가 된 사실 및 근거법령을 추가하거나 변경하는 것으로서 그 허용여부 가 분쟁의 일회적 해결 및 원고의 방어권 보장과 관련하여 문제된다.
2. 학설
이에 대하여 원고의 방어권 보장 측면에서 부정하는 견해, 소송경제 및 분쟁의 일회적 해결 측면에서 긍정하는 견해 원칙적으로 불허하나 원고의 방어권 행사에 지장이 없는 한 도 내에서 제한적으로 긍정하는 견해가 대립한다.

	3. 판례
	대법원은 각 처분사유의 기본적 사실관계의 동일성이 인정
	되는 범위 내에서 제한적으로 가능하다고 판시하여 제한적
	으로 긍정하는 견해이다.
	4. 검토 및 사안의 경우
	공익과 사익의 이익형량 측면에서 대법원의 입장이 타당하
	다. 이에 따르면 乙은 기존의 처분사유와 기본적 사실관계
	의 동일성이 인정되는 범위 내에서 처분사유의 추가변경이
	허용된다고 할 것이다.
	Ⅲ. 처분사유 추가변경의 인정범위(한계)
	1. 문제점
	처분사유 추가변경은 시간적, 객관적 한계가 존재하는바 사
	안에서는 처분시 존재하던 사유를 추가하여 시간적 한계는
	문제되지 않고 객관적 한계와 관련하여 乙의 거부사유의 추
	가의 경우 처분사유의 동일성의 판단기준이 문제된다.
	2. 객관적 범위
	① 처분사유의 추가·변경은 취소소송의 소송물 범위 내에서
	만 가능하다. 즉, 처분의 동일성이 유지되어야 하며 처분사
	유 추가·변경으로 소송물이 변경되면 이는 청구가 변경되는

	것으로 행정소송법 제22조에 따라 처분변경으로 인한 소의 변경을 하여야 한다. 또한, ② 추가·변경되는 처분사유는 당초 처분의 근거로 삼은 사유와 기본적 사실관계에 있어서 동일성이 인정되는 범위 내에서만 가능하다.
	3. 판례
	대법원은 처분의 동일성은 기본적 사실관계의 동일성을 기준으로 시간적·장소적 근접성, 행위의 태양, 결과 등을 종합적으로 고려하여 판단한다고 판시하였다.
	4. 검토 및 사안의 경우
	원고의 방어권 보장 측면에서 처분사유의 추가변경을 제한할 필요성이 있는바 대법원의 입장이 타당하다. 따라서 乙은 기본적 사실관계의 동일성이 인정되는 범위 내에서 처분사유의 추가변경이 가능할 것이다.
	IV. 사안의 해결
	1. 乙의 처분사유 추가변경은 처분사유의 동일성이 인정되는 경우 허용되며 2. 처분사유의 동일성은 기본적 사실관계의 동일성을 기준으로 판단하게 된다. 3. 당해 사업이 선형 사업으로서 사실상 이주택지공급 불능이라는 부득이한 사유 및 이주희망 가구수가 10호에 미달한다는 기존의 사유와

추가하려는 사유로서 계속하여 거주하고 있지 아니하였을 뿐만 아니라 이주정착지로의 이주를 포기하고 이주정착금을 받은 자에 해당한다는 사유는 그 근거 규정이 달라 기본적인 사실관계의 동일성이 인정되지 않는다. 따라서 乙은 처분사유 추가·변경을 할 수 없다.

<끝>

[문제2] 30점

<물음1>20점

I. 논점의 정리

간접손실보상에 대해 설명하고 그 요건을 검토해 사안이 간접손실보상 대상인지를 파악한다.

II. 간접손실보상의 의의

공익사업으로 인하여 사업시행지 밖의 재산권자에게 가해지는 손실 중 공익사업으로 인하여 필연적으로 발생하는 손실을 간접손실이라고 한다. 간접손실보상은 이러한 간접손실을 보상하는 것이다.

III. 간접손실보상의 유형

일반적으로 물리적·기술적 손실을 간접침해보상, 사회적·경제적 손실을 간접손실이라 한다. 최근 판례는 사회적·경제적

	손실은 물론 물리적·기술적 손실도 간접손실의 유형으로 보아 피수용자 권익보호를 한층 강화하고 있다.
	IV. 간접손실보상의 성격
	침해의 효과가 간접적인 것이라는 점에서 직접침해에 의한 보상과 구별되며, 손실이 있는 후에 행하는 사후보상의 성격을 갖는다. 간접보상은 재산권 보상 및 생활보상의 성격을 모두 갖는다.
	V. 간접손실보상의 법적 근거
	간접손실이 헌법 제23조 제3항의 손실보상에 포함되는지에 대해 긍정설, 부정설이 대립하나, 통설·판례는 간접손실보상 또한 적법한 공익사업으로 인해 발생하는 필연적인 손실이므로 헌법 제23조 제3항에서 규정한 손실보상 대상이라고 본다. 생각건대, 간접손실은 공익사업시행지구 밖의 손실이라는 것은 하나, 그 또한 적법한 공용침해로 인해 예견되는 통상의 손실이므로 헌법 제23조 제3항의 손실보상에 포함시키는 것이 타당하다.
	VI. 간접손실보상의 요건
	1. 간접손실의 존재
	공공사업 시행으로 사업시행지 밖의 토지소유자 등이 입은

	손실이어야 하고, 그 손실의 발생이 예견가능하고, 그 손실의 범위가 구체적으로 특정될 수 있어야 한다.
	2. 특별한 희생
	사회적 제약을 넘는 특별한 희생을 요한다. 구별기준으로 인적범위의 특정성이라는 형식적 기준설과 침해의 본질과 강도라는 실질적 기준설이 있다. 한 가지 기준으로는 불충분한바, 양자를 모두 고려함이 타당하다.
	3. 보상규정의 존재
	토지보상법 제79조 제2항은 '공익사업시행지 밖 토지등이 본래의 기능을 다할 수 없는 경우'라 하여, 동법 시행규칙 59조 내지 65조에 간접손실보상을 구체적으로 규정하고 있다.
	VII. 사안이 간접손실보상 대상인지
	1. 토지보상법 시행규칙 64조 검토
	토지보상법 시행규칙 제64조 ①항에서는 공익사업시행지구 밖에서 제45조에 따른 영업손실의 보상대상이 되는 영업을 하고 있는 자가 공익사업의 시행으로 인하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 영업자의 청구에 의하여

	당해 영업을 공익사업시행지구에 편입되는 것으로 보아 보상하여야 한다고 규정하며, 그 구체적인 사유로는 1호 배후지의 3분의 2 이상이 상실되어 그 장소에서 영업을 계속할 수 없는 경우, 2호 진출입로의 단절, 그 밖의 부득이한 사유로 인하여 일정한 기간 동안 휴업하는 것이 불가피한 경우 중 어느 하나에 해당하여야 한다.
	2. 관련 판례
	판례는 공익사업시행지구 밖 영업손실보상의 특성과 헌법이 정한 '정당한 보상의 원칙'에 비추어 보면, 공익사업시행지구 밖 영업손실보상의 요건인 '공익사업의 시행으로 인한 그 밖의 부득이한 사유로 일정 기간 동안 휴업이 불가피한 경우'란 공익사업의 시행 또는 시행 당시 발생한 사유로 휴업이 불가피한 경우만을 의미하는 것이 아니라 공익사업의 시행 결과, 즉 그 공익사업의 시행으로 설치되는 시설의 형태·구조·사용 등에 기인하여 휴업이 불가피한 경우도 포함된다고 해석함이 타당하고 판시한바 있다.
	3. 사안의 경우
	사업지구 내가 아닌 인근이라는 점, 농업과학기술원의 조사 결과로 손실 발생이 예견가능하고 매출자료가 존재한다는 점에서 특정가능하여 간접손실이 인정된다. 보급 잠종을 공

	급하는 유일한 업체로 인적범위가 특정가능하고, 소음·진동 관리 법령에서 정한 기준 초과로 특별한 희생이 인정되며, 토지보상법 시행규칙 제64조의 '그 밖의 부득이한 사유'에 해당 되므로 보상규정도 존재하므로 간접손실보상의 대상에 해당한다.
	<물음2> 10점
	I. 논점의 정리
	① 손해배상과 손실보상의 동시행사 여부와 ② 재결전치주의, ③ 피보상자가 제기할 소송과 그 상대방을 판례 중심으로 검토한다.
	II. 손해배상청구 가능여부
	1. 손실보상청구권과 손해배상청구 동시 행사 가능 여부
	판례에 따르면 토지보상법상 손실보상과 환경정책기본법상 손해배상은 근거규정과 요건·효과를 달리하는 것으로서, 각 요건이 충족되면 성립하는 별개의 청구권이다. 다만, 동시에 행사할 수 있다고 본다면 이중배상 문제가 발생하여, 어느 하나만을 선택할 수 있다고 본다.
	2. 손실보상청구기간이 지난 경우 행사 가능성
	'해당 사업의 공사완료일로부터 1년'이라는 손실보상 청구

	기간이 도과하여 손실보상청구권을 더 이상 행사할 수 없는 경우에도 손해배상 요건이 충족되는 이상 여전히 손해배상 청구는 가능하다.
	Ⅲ. 재결절차 거치지 않고 영업손실보상 청구 가능성
	1. 관련판례
	판례에 따르면 '토지보상법의 규정내용과 입법취지 등을 종 합하면, 재결절차를 거친 다음 그 재결에 대하여 불복이 있 는 대에 비로서 토지보상법 83조 내지 85조에 따라 권리구 제를 받아야 한다'고 하여 민사소송 및 당사자소송 가능성 을 부정한다.
	2. 사안의 해결
	재결전치주의란 행정소송을 제기하기 앞서 토지수용위원회 의 재결을 거쳐야 하는 것을 의미한다. 영업손실보상도 토 지보상법 규정에 의거 제34조 및 제50조 등 일련의 재결절 차를 반드시 거쳐야 하므로 그러한 재결절차를 거치지 않고 영업손실에 대한 보상은 청구할 수 없다
	IV. 피보상자가 제기할 소송과 그 상대방
	판례는 토지보상법에 관한 법령상 손실보상 대상에 해당함 에도 관할 토지수용위원회가 사실을 오인하거나 법리를 오

	해함으로서 손실보상대상에 해당하지 않는다고 잘못된 내용의 재결을 한 경우 토지보상법 85조 2항에 따른 '보상금 증감청구소송'을 제기하여야 한다고 해 그 상대방은 사업시행자가 된다.
	<끝>
	[문제3]20점
	I. 논점의 정리
	주거이전비에 대해 검토하고, 주거이전비의 법적성질과 관련 판례 및 법리에 기초하여 사안을 해결한다.
	II. 주거이전비의 의의, 취지, 근거
	주거이전비 보상은 재산권에 대한 대물보상과는 달리 생활권보상의 일종에 해당하는 것으로서 공익사업의 시행으로 생활 근거를 상실하게 되는 자를 위하여 종전의 생활상태를 원상으로 회복시키면서 동시에 인간다운 생활을 보장하여 주기 위한 이른바 생활보상의 일환으로 국가의 정책적 배려에 의해 마련된 제도이다. 소유자는 토지보상법 시행규칙 54조 1항에, 세입자는 같은 조 2항에 근거를 둔다.
	III. 주거이전비 지급청구권의 법적성질
	주거이전비 지급청구권이 공권인지, 사권인지 문제되며 그

에 따라 관할 법원과 적용법률 등이 결정된다. 판례는 주거이전비 보상청구권이 공법상 권리라고 하여 그 보상을 둘러싼 쟁송은 민사소송이 아니라 행정소송에 의하여야 한다고 본다.

IV. 주거이전비 보상평가 (시행규칙 제54조)

① 공익사업시행지구내 편입되는 주거용 건축물의 소유자에 대하여는 당해 건축물에 대한 보상을 하는 때에 가구원수에 따라 2개월분의 주거이전비를 보상하여야 한다. ② 공익사업의 시행으로 인하여 이주하게 되는 주거용 건축물의 세입자로서 사업인정고시일등 당시 또는 공익사업을 위한 관계법령에 의한 고시 등이 있는 당시 당해 공익사업시행지구 안에서 3개월 이상 거주한 자에 대하여는 가구원수에 따라 4개월분의 주거이전비를 보상하여야 한다. 다만, 무허가건축물등에 입주한 세입자로서 사업인정고시일등 당시 또는 공익사업을 위한 관계법령에 의한 고시 등이 있는 당시 그 공익사업지구 안에서 1년 이상 거주한 세입자에 대하여는 본문에 따라 주거이전비를 보상하여야 한다.

V. 권리구제에 관한 대법원 판례

주거이전비 보상청구권은 그 요건을 충족하는 경우 당연히 발생하는 것이므로, 주거이전비 보상청구 소송은 행정소송

	법 3조 2호에 규정된 당사자소송에 의하여야 한다. 다만 세입자의 주거이전비 보상에 관하여 재결이 이루어진 다음 세입자가 보상금의 증감 부분을 다투는 경우에는 토지보상법 85조 2항에 규정된 행정소송에 따라, 보상금의 증감 이외의 부분을 다투는 경우에는 같은 조 1항에 규정된 행정소송에 따라 권리구제를 받을 수 있다. 그리고 이러한 법리는 주거용 건축물의 소유자가 사업시행자를 상대로 이주정착금, 주거이전비 및 이사비의 보상을 구하는 경우에도 그대로 적용된다.
	VI. 甲이 제기 할 수 있는 소송방법
	1. 보상금증감청구소송 의의 및 근거 (보상법 제85조 제2항)
	보상금증감청구소송은 보상금 증감의 다툼에 대하여 직접적 이해관계를 가진 당사자인 사업시행자와 토지소유자 및 관계인이 소송제기를 통해 직접 다투는 당사자소송이다. 보상금증감청구소송은 토지보상법 제85조 제2항에 근거가 있으며, 실질적으로는 처분 또는 재결을 다투는 것이나, 그 소송 구조에 있어서는 처분청을 피고로 하는 것이 아니라 법률관계의 한쪽 당사자를 피고로 하며 형식적으로는 당사자소송 형식을 취하는 소송으로서 <형식적 당사자소송>이다.
	2. 소유자 甲의 경우

	甲의 주거이전비에 대한 수용재결이 있었으므로, 토지보상법 85조 2항의 보상금증감청구소송을 제기할 수 있다. 같은 법 83조 이의신청도 권리구제 수단으로 고려할 수 있다.
	VII. 乙이 제기 할 수 있는 소송방법
	1. 공법상 당사자소송의 의의 및 근거
	당사자소송은 행정청의 처분등을 원인으로 하는 법률관계에 관한 소송 그 밖에 공법상의 법률관계에 관한 소송으로서 그 법률관계의 한쪽 당사자를 피고로 하는 소송을 말한다. 행정소송법 제3조 제2호에 그 근거가 있다. 즉, 공법상 법률관계 당사자가 각각 원고와 피고가 되어 공법상 법률관계에 대해 다투는 소송을 말한다.
	2. 세입자 乙의 경우
	乙의 주거이전비에 대한 수용재결이 없었으므로, 乙은 공법상 당사자소송을 제기하여 사업시행자에게 주거이전비의 지급을 구할 수 있다.
	<끝>
	[문제4] 10점
	I. 논점의 정리
	이주민지원규정이 대외적 구속력이 있는지를 검토하고, 이

	를 근거로 乙을 이주대책 대상자에서 배제한 것의 위법성 여부를 논한다.
	Ⅱ. 이주민지원규정의 대외적 구속력
	1. 훈령(행정규칙)의 법규성
	행정규칙이란 행정조직 내부에서 효력을 갖는 일반적·추상적 규율로서 행정의 조직과 활동을 규율하는 것을 목적으로 하는 행정기관 내부의 사무처리 기준을 말한다. 행정규칙은 내부적으로만 효력을 갖고 대외적 구속력 즉, 법규성은 없다.
	2. 관련 판례
	대법원은 한국토지주택공사가 수립한 이주대책기준에 대하여 사업시행자 내부의 사무처리준칙에 불과하고, 대외적으로 국민이나 법원을 기속하는 효력이 없을 뿐 아니라, 법원으로서 토지보상법 규정 취지를 감안하여 기준에 나타난 사업시행자의 의사를 합리적으로 해석할 수 있다고 판시한 바 있다.
	3. 사안의 경우
	사안의 이주민지원규정은 훈령 형식으로 행정규칙이므로 대외적 구속력은 인정되지 않는다.

	Ⅲ. 이주대책 내용의 사업시행자 재량
	사업시행자는 이주대책을 수립할 의무는 있지만(제78조 제1
	항), 이주대책의 내용 결정에 대해서는 재량권을 갖는다. 대
	법원은 일관되게 사업시행자가 이주대책의 내용 결정에 재
	량을 갖는다는 입장을 취하고 있다. 또한, 판례는 사업시행
	자가 설정한 이주대책기준은 그것이 객관적으로 합리적이
	아니라거나 타당하지 않다고 볼 만한 특별한 사정이 없는
	한 존중되어야 한다고 판시한바 있다.
	IV. 사안의 경우
	1. 이주민지원규정의 객관성, 합리성 검토
	사업시행자는 이주대책 내용을 결정하는 데에 재량을 갖으
	며 그 내용이 객관적으로 합리적이 아니라거나 타당하지 않
	다고 볼 만한 특별한 사정이 없는한 존중되어야 한다. 그러
	나 사안의 이주민지원규정은 법령상 요건보다 엄격한 요건
	을 규정하여 법상 이주대책대상자임에도 추가적인 요건을
	두어 이주대책대상자를 축소시키는바 객관성, 합리성이 결
	여된다.
	2. 소결
	甲이 법상 요건을 충족하여 이주대책대상자에 해당된다면,
	해당 이주민지원규정의 추가적 요건으로 이주대책대상자에

서 배제시킬 수 없으므로 甲을 배제한 것은 위법하며, 甲주
장은 타당하다.

<이하여백>

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
3교시	100분	③ 감정평가법규
수험번호		성 명

【문제 1】 국토교통부장관은 표준지로 선정된 X토지의 2023. 1. 1. 기준 공시지가를 1㎡당 1,000만원으로 결정·공시하였다. 국토교통부장관은 X토지의 표준지공시지가를 산정함에 있어 부동산 가격공시에 관한 법률 및 같은 법 시행령이 정하는 '토지의 일반적인 조사사항' 이외에 국토교통부 훈령인 표준지공시지가 조사·평가 기준 상 상업·업무용지 평가의 고려사항인 '배후지의 상태 및 고객의 질과 양, '영업의 종류 및 경쟁의 상태'등을 추가적으로 고려하여 평가하였다. 甲은 A시에 상업용지인 Y토지를 소유하고 있다. A시장은 X토지를 비교표준지로 선정하여 Y토지에 대한 개별공시지가를 1㎡당 1,541만원으로 결정·공시 후 이를 甲에게 통지하였다. 甲은 국토교통부장관이 X토지의 표준지공시지가를 단순히 행정청 내부에서만 효력을 가지는 국토교통부 훈령 형식의 표준지공시지가 조사·평가 기준이 정하는 바에 따라 평가함으로써 결과적으로 부동산가격공시에 관한 법령이 직접 규정하지 않는 사항을 표준지공시지가 평가의 고려사항으로 삼은 것은 위법하다고 주장하고 있다. 다음 물음에 답하시오. (40점)

물음 1) 표준지공시지가 조사·평가 기준의 법적 성질에 비추어 甲 주장의 타당성 여부를 설명하시오. (15점)

물음 2) 甲은 부동산 가격공시에 관한 법률 제11조에 따라 A시장에게 Y토지의 개별공시지가에 대한 이의를 신청하였으나 기각되었다. 이 경우 甲이 기각결정에 대해 여전히 불복하는 경우 행정심판법상의 행정심판을 청구할 수 있는지 설명하시오. (10점)

물음 3) 한편, 甲은 2023. 6월 경 개별공시지가결정에 대하여 부동산 가격공시에 관한 법령에 따른 이의신청의 기각결정 통지를 받은 후 행정심판법에 따른 행정심판과 행정소송법에 따른 행정소송을 제기하지 않았다. 그 후, A시장은 2023. 9. 15. 이 사건 토지에 대한 개별공시지가를 시가표준액으로 하여 재산세를 부과·처분하였다. 이에 甲은 2023. 12. 5. 이 사건 토지에 대한 개별공시지가

결정시 검증을 거치지 않았다는 이유로 재산세부과처분에 대하여 취소소송을 제기하였다. 甲의 청구가 인용될 수 있는지 여부에 관하여 설명하시오. (15점)
(단, 재산세 부과처분은 적법하다)

<부동산 가격공시에 관한 법률>

제11조(개별공시지가에 대한 이의신청) ① 개별공시지가에 이의가 있는 자는 그 결정·공시일부터 30일 이내에 서면으로 시장·군수 또는 구청장에게 이의를 신청할 수 있다.

<부동산 가격공시에 관한 법률 시행령>

제6조(표준지공시지가 조사·평가의 기준) ① 법 제3조제4항에 따라 국토교통부장관이 표준지공시지가를 조사·평가하는 경우 참작하여야 하는 사항의 기준은 다음 각 호와 같다. <각 호 생략>

② 표준지에 건물 또는 그 밖의 정착물이 있거나 지상권 또는 그 밖의 토지의 사용·수익을 제한하는 권리가 설정되어 있을 때에는 그 정착물 또는 권리가 존재하지 아니하는 것으로 보고 표준지공시지가를 평가하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 표준지공시지가의 조사·평가에 필요한 세부기준은 국토교통부장관이 정한다.

<표준지공시지가 조사·평가 기준>

제23조(상업·업무용지) 상업·업무용지(공공용지를 제외한다)는 토지의 일반적인 조사사항 이외에 다음 각 호의 사항 등을 고려하여 평가하되, 인근지역 또는 동일수급권 안의 유사지역에 있는 토지의 거래사례 등 가격자료를 활용하여 거래사례비교법으로 평가한다. <단서 생략>

1. 배후지의 상태 및 고객의 질과 양
2. 영업의 종류 및 경쟁의 상태
- 3.~6. <생략>

【문제 2】 관할 A시장은「부동산 가격공시에 관한 법률」에 따라 甲소유의 토지에 대해 공시기준일을 2018. 1. 1.로 한 개별공시지가를 2018. 5. 28. 결정·공시하고(당초 공시지가) 甲에게 개별통지 하지는 않았다. 해당 개별공시지가는 토지가격비준표의 적용에 오류가 있는 것이었다. 이후 甲소유의 토지를 포함한 지역 일대에 개발사업이 시행되면서 관련법에 의한 부담금 부과 대상이 된 甲의 토지에 대해 A시장은 2018. 8. 3. 당초 개별공시지가에 근거하여 甲에게 부담금을 부과하였다. 한편 A시장은 甲소유 토지에 대한 당초 공시지가를 결정할 때 토지가격비준표의 적용에 오류가 있었음을 이유로 「부동산 가격공시에 관한 법률」 제12조 및 같은 법 시행령 제23조제1항에 따라 개별공시지가를 감액하는 정정을 하였고, 정정된 공시지가는 2018. 9. 7. 甲에게 통지 되었다. 다음 물음에 답하시오. (아래 설문은 각각 별개의 독립된 상황임) (30점)

물음 1) 甲은 정정된 공시지가에 대해 2018. 10. 22. 취소소송을 제기하였다. 甲의 소송은 적법한가? (15점)

물음 2) 만약, A시장이 당초 공시지가에 근거하여 甲에게 부담금을 부과한 것이 위법한 것이더라도, 이후 A시장이 토지가격비준표를 제대로 적용하여 정정한 개별공시지가가 당초 공시지가와 동일하게 산정되었다면, 甲에 대한 부담금 부과 하자는 치유되는가? (15점)

(설문은 감액 정정이었으나, 물음2)는 정정 후 개별공시지가가 동일한 것을 전제함.)

【문제 3】 서울의 A구청장은 이 사건 B토지의 비교표준지로 A구의 C토지(2017. 1. 1. 기준 공시지가가 1㎡당 810만원임)를 선정하고 이 사건 B토지와 비교표준지 C의 토지가격비준표상 토지특성을 조사한 결과 총 가격배율이 1.00으로 조사됨에 따라 이 사건 각 토지의 가격을 1㎡당 810만원으로 산정하였다. 감정평가사 D는 A구청장으로부터 이와 같이 산정된 가격의 검증을 의뢰받고 이 사건 각 토지가 비교표준지와 비교하여 환경조건, 획지조건 및 기타조건에서 열세에 있어 비교표준지의 공시지가를 약 83.9%의 비율로 감액한 1㎡당 680만원을 개별공시지가로 정함이 적정하다는 검증의견을 제시하였다. 이에 A구청장은 A구 부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 이 검증의견을 받아들여 B토지에 대하여 1㎡당 680만원으로 개별공시지가결정을 하였다. 이에 대하여 B토지소유자는 토지가격비준표와 달리 결정된 개별공시지가결정은 위법하다고 주장한다. 이 주장은 타당한가? (20점)

【문제 4】토지수용위원회, 부동산가격공시위원회, 보상협의회를 비교 하시오. (10점)

[문제1] 40

<물음1> 15

I. 논점의 정리

표준지공시지가 조사·평가기준(이하 조사평가기준)은 훈령형식이나 국민의 권리의무에 영향을 미치는바, 행정규칙 형식의 법규명령으로 볼 수 있다. 해당 조사평가기준의 법적성질 검토 후, 甲주장의 타당성을 검토한다.

II. 표준지공시지가 조사평가기준의 법적성질

1. 의의

국토교통부가 표준지가격의 공시를 위하여 선정된 표준지의 적정가격의 조사평가에 관하여 세부적인 기준과 절차 등을 정하기 위한 훈령이다.

2. 학설

① 규범의 실질을 강조하면서 헌법이 인정하고 있는 위임명령의 형식을 예시적으로 보아 법규 명령으로 보는 견해(법규명령설), ② 규범의 형식을 강조하면서 헌법이 인정하고 있는 위임명령의 형식을 열거적인 것으로 보아 행정규칙으로 보는 견해(행정규칙설), ③ 헌법은 법규명령의 형식으로 대통령령, 총리령, 부령만을 한정적으로 열거하고 있으므로, 행정규칙형식의 법규명령은 허용되지 않아 위헌무효라는 견

	해(위헌무효설), ④ 상위법령의 수권을 받아 제정된 행정입법의 경우 법규명령으로 보아야 한다는 견해(수권여부기준설), ⑤ 이를 규범구체화 행정규칙으로 보면서 독일과 같이 대외적 구속력을 인정하려는 견해(규범구체화 행정규칙설) 등이 대립하고 있다.
	3. 판례
	대법원은 위임의 한계를 벗어나지 아니하는 한 상위 수권법령과 결합하여 대외적인 구속력이 인정된다고 보았다. 또한 법규적 효력을 갖는 고시의 위임을 받아 정한 지방자치단체의 내부규정에 대해서도 법규성을 인정한 바 있으며, 헌법재판소도 헌법이 인정하고 있는 위임입법의 형식은 예시적이라는 입장에서 대법원과 같은 태도를 취한다.
	4. 검토
	국민의 권리나 의무는 법률이나 법률의 수권을 받는 행정입법에 의하여 규율하는 것이 헌법 37조 2항의 법률유보원칙에 부합하는 것이므로 수권여부기준설이 타당하다고 본다. 또한 헌법 75조 및 95조의 취지가 일정한 범위 내에서 행정입법을 허용하여 사회적 변화에 대응한 입법수요의 급증에 대비하기 위한 기능적 권력분립론에 있다는 것을 감안한다면 헌법이 인정하고 있는 위임입법의 형식은 예시적인 것

으로 보아 법령보충적 행정규칙의 법규성을 인정하는 것이 타당하다.

Ⅲ. 甲 주장의 타당성

1. 부동산공시법 시행령 6조 내용

위 규정에서 참작하여야 하는 사항의 기준은 예시적인 것으로 볼 수 있고, 조사평가기준의 상위 근거 규정으로 볼 수 있다.

2. 소결

표준지공시지가 조사·평가기준의 현실적인 필요성이 인정되고, 조사평가기준은 상위법령인 부동산공시법 시행령 제6조에 위임에 따른 것으로 수권의 범위 내에서 상위법령과 결합하여 대외적 구속력이 인정된다. 따라서 甲의 주장은 타당하지 않다.

<물음2> 10

I. 논점의 정리

행정심판법 제51조는 행정심판 재청구의 금지를 규정한다. 이에 부동산공시법 11조 이의신청이 강학상 이의신청인지 여부와 관련해 그 법적성질을 검토하여 사안을 해결한다.

	Ⅱ. 이의신청의 법적성질
	1. 학설
	① 이의신청의 실질적 내용에 비추어 특별행정심판 성격을 갖는다고 보는 견해, ② 이의신청은 개별공시지가가 처분임을 전제한 권리구제는 아니고, 국민의 권리구제 확립을 위해 강학상 이의신청으로 보는 견해가 있다.
	2. 판례
	판례는 부동산공시법이 이의신청에 관하여 규정하고 있다고 하여 이를 행정심판법 3조 1항에서 행정심판의 제기를 배제하는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우에 해당한다고 볼 수 없다고 하여 강학상 이의신청으로 본다.
	3. 검토
	이의신청 절차는 준사법적 절차에 따르도록 하는 어떠한 규정도 없으며, 이의신청을 거친 후에도 행정심판을 청구 할 수 있다고 판시하는 바, 당사자의 권리구제 측면에서 강학상 이의신청으로 보는 것이 타당하다.
	Ⅲ. 사안 관련 판례
	판례는 이의신청과 행정심판의 절차가 상이하고 행정심판을 금지하는 규정이 없는바, 이의신청 후 행정심판 청구가 가

능하다고 판시한바 있다.

IV. 결론

甲은 부동산공시법 제11조의 이의신청은 강학상 이의신청으로 행정심판법 제51조가 적용되지 않는다. 따라서 이의신청 기각결정에 불복하는 경우 이의신청과 별도로 행정심판을 청구 할 수 있다.

<물음3> 15

I. 논점의 정리

개별공시지가의 위법을 후행행위인 재산세부과처분 취소소송에서 주장할 수 있는지에 대한 물음으로 하자의 승계 가능성이 중심으로 검토한다.

II. 하자의 승계의 의의 및 취지

하자승계는 불가쟁력이 발생하여 직접 다룰 수 없는 선행행위 위법을 후행행위를 다투는 쟁송단계에서 주장하려는 논의이며, 법적안정성과 국민의 권리구제의 조화에 그 취지가 인정된다.

III. 하자승계 논의의 전제요건

1. 전제요건

	① 선·후행행위 모두 처분이며, ② 선행행위에 불가쟁력이
	발생여야 하고, ③ 선행행위에 단순 취소사유에 해당하는
	하자가 존재하여야 한다. ④ 또한 후행행위는 적법할 것이
	요구된다.
	2. 사안의 경우
	① 개별공시지가와 재산세부과처분은 모두 처분이고, ②
	2023년 12월 5일은 이의신청의 결과 통지받은 날로부터 90
	일이 지났으므로 행정기본법 제36조 4항에 의거 개별공시
	지가에 대해 행정소송을 제기할 수 있는 제소기간이 도과한
	것으로 판단된다. ③ 선행행위에는 검증을 거치지 않았고
	이는 절차상 하자로서 중대명백성설에 따라 취소사유의 위
	법이 있다. ④ 재산세부과처분에는 적법하므로, 전제요건은
	모두 충족된다.
	V. 하자승계의 인정범위
	1. 학설
	① 하자승계론 (전통적 견해)
	하자승계론은 행정행위의 하자는 독립적으로 판단되어야 한
	다는 전제 하에 선행행위와 후행행위가 결합하여 하나의 법
	률효과의 발생을 목적으로 하는 경우 하자의 승계를 인정하
	고, 서로 독립하여 별개의 법률효과의 발생을 목적으로 하

는 경우에는 하자의 승계를 부정한다.

② 구속력론 (규준력 이론)

선행행위에 형식적 존속력이 발생되면 상대방, 이해관계인 및 행정청에 대한 포괄적인 구속력이 후행행위에 발생하여 행정청은 선행행위의 규율내용과 모순되는 결정을 내려서는 안 되며, 상대방은 후행행위의 불법을 다룰 때에도 선행행위의 내용을 다투어서는 안 된다. 다만, 구속력은 대인적(주관적)·사물적(목적)·시간적(사실 및 법상태) 한계 내에서 인정되고, 이 한계 내에서도 예측 가능하고 수인 가능한 경우에만 구속력이 미친다. 따라서 예측 불가능하거나 수인 불가능한 경우는 구속력이 배제되어 하자의 승계가 인정될 수 있다.

2. 판례

원칙적으로 통설과 같이 선후의 행위가 결합하여 하나의 법률효과를 목적으로 하는지, 독립하여 별개의 법률효과를 목적으로 하는지에 따라 판단한다. 그러나 개별공시지가 결정과 과세처분, 표준공시지가 결정과 보상금산정에 관한 수용재결의 경우에는 비록 별개의 법률효과를 목적으로 하는 경우이지만 예외적으로 예측가능성과 수인한도의 법리를 고려하여 하자의 승계를 긍정한 바 있다.

3. 검토

구속력이론은 행정행위와 판결이 구조적인 차이가 있음에도 불구하고 행정행위에 기판력과 유사한 효력을 인정한다는 점에서 문제가 있다. 따라서 원칙적으로 하자승계론을 기준으로 하여 하자승계여부를 결정하되, 선행행위와 후행행위가 서로 독립하여 별개의 효과를 목적으로 하는 경우에도 선행처분의 구속력이 그로 인하여 불이익을 입게 되는 자에게 수인한도를 넘는 가혹함을 가져오며, 그 결과가 당사자에게 예측 가능한 것이 아닌 경우에는 국민의 권리구제차원에서 예외적으로 후행행위를 다투면서 선행행위의 위법을 주장할 수 있다고 보아야 할 것이다.

VI. 사안의 해결

사안의 경우 개별공시지가와 재산세부과처분은 별개의 법률 효과를 목적으로 하며, 개별공시지가 결정에 대해 甲에게 개별적으로 통지하였고, 甲은 이에 대해 이의신청을 하고 그 결과에 대해 더 이상 다투지 않았다. 따라서 수인불가능하거나, 예측불가능하다고 볼 수 없어 개별공시지가와 재산세부과처분의 하자승계는 인정될 수 없다고 판단된다. 관련 판례 또한 개별공시지가 결정에 대하여 한 재조사청구에 따른 조정결정을 통지받고서도 더 이상 다투지 아니한 경우까지 선행처분인 개별공시지가 결정의 불가쟁력이나 구속력이

	수인한도를 넘는 가혹한 것이거나 예측불가능하다고 볼 수
	없어, 위 개별공시지가 결정의 위법을 이 사건 과세처분의
	위법사유로 주장할 수 없다고 판시한바 있다. 따라서 甲의
	청구는 인용될 수 없을 것이다.
	<끝>
	[문제2] 30
	<물음1> 15
	I. 논점의 정리
	소송 요건과 관련하여, 대상적격과 제소기간이 문제된다. 甲
	은 토지소유자로서 취소를 다툼 법률상 이익이 있고, 이를
	다툼 현실적인 필요성인 협의의 소익, 피고적격, 관할 법원
	등 나머지 요건을 갖춘 것으로 보인다.
	II. 대상적격 충족 여부
	1. 개별공시지가의 의의 및 법적성질
	개별공시지가는 시장 등이 매년 결정, 공시하는 개별 토지
	의 단위면적당 가격이다. 법적성질에 대해 행정행위설, 행정
	규칙설, 법규명령설, 사실행위설 등 견해 대립이 있는데, 통
	설·판례는 개별토지가격 결정은 과세의 기준이 되는 등 해
	당 토지소유자 및 이해관계인의 권리의무에 직접 영향을 미
	치므로, 항고소송의 대상인 처분이라 본다.

	2. 개별공시지가의 정정(부동산공시법 제12조)
	개별공시지가에 위산, 오기 등이 있는 경우 이를 직권으로
	정정할 수 있으며, 이 경우 당초 개별공시지가는 효력을 상
	실하고, 정정된 공시지가의 효력은 공시기준일에 소급한다.
	정정된 공시지기도 처분에 해당한다.
	3. 대상적격
	1) 문제점
	취소소송은 처분등을 대상으로 하여야 한다(행정소송법 제
	19조). 따라서 처분이 있는 후 처분청이 처분을 변경한 경
	우에 원처분과 변경처분 중 어느 것을 소의 대상으로 하여
	야 하는지가 문제 된다.
	2) 학설
	① 변경처분과 원처분은 각각 독립된 처분이므로 양자 모두
	소의 대상이라고 보는 <병존설>, ② 변경처분으로 원처분
	은 취소되어 변경처분으로 대체 되므로 변경처분이 소의 대
	상으로 보는 <흡수설> 및 ③ 변경처분은 원처분의 일부취
	소로 원처분은 변경된 원처분으로 존재하게 되어 이를 소의
	대상으로 삼아야 한다고 보는 <역흡수설> 등이 있다.
	3) 판례 (감액처분)

행정청이 과세처분을 한 뒤에 이를 감액하는 경정처분을 한 경우에 그 경정처분은 감소된 부분에만 법적효과를 미치는 것이므로 이러한 경정처분은 독립한 과세처분이 아니고, 당초 부과처분(원처분)의 일부취소로서 납세자에게 유리한 효과를 가져오므로, 항고소송의 대상은 당초 부과처분 중 경정처분에 의해 취소되지 않고 남은 부분이며, 제소기간의 준수 여부도 감액처분이 아닌 당초 처분을 기준으로 판단해야 한다는 것이 판례의 태도이다.

4) 소결 및 사안의 경우

당초 처분을 당사자에게 유리하게 변경하는 경우에는 변경되고 남은 원처분을 소의 대상으로 하는 것이 원처분의 연속성 측면에서 타당하다. 사안의 경우 개별공시지가를 감액하는 정정을 하였고, 甲의 입장에서는 재산세부과 등의 기준이 되는 개별공시지가가 감액이 된 것은 유리한 변경이므로 변경되고 남은 원처분이 소의 대상이 된다고 보는 것이 타당하다.

Ⅲ. 제소기간

1. 행정소송법 제20조 검토

취소소송은 처분등이 있음을 안 날부터 90일 이내, 처분등이 있는 날부터 1년을 경과하면 이를 제기하지 못한다고

	행정소송법 제20조에서 규정하고 있다. 또한, 처분이 있음을 안 날과 처분이 있는 날 중 어느 하나의 기간이라도 경과 하면 제소할 수 없다.
	2. 관련판례
	개별토지가격결정은 행정편의상 일단의 각 개별토지에 대한 가격결정을 공고하는 것일 뿐 그 처분의 효력은 각각의 토지 또는 각각의 소유자에 대하여 각별로 효력을 발생하는 것이므로 개별토지가격결정의 공고는 공고일로부터 그 효력을 발생하지만 처분 상대방인 토지소유자 및 이해관계인이 공고일에 개별토지가격결정처분이 있음을 알았다고까지 의제할 수는 없으므로, 상대방에 대하여 별도의 고지절차를 취하지 않는 이상 특별히 위 처분을 알았다고 볼만한 사정이 없는 한 개별토지가격결정에 대한 재조사청구 또는 행정심판청구는 처분이 있는 날로부터 180일 이내에 이를 제기하면 된다고 판시한바 있다.
	3. 사안의 경우
	사안의 경우 소의 대상은 변경되고 남은 원처분이므로, 제소기간의 준수여부는 당초 개별공시지가를 기준으로 판단하여야 한다. 다만, 당초 개별공시지가의 경우 甲에게 개별통지를 하지 않았으므로 공고일인 2018년 5월 28일에 처분이

	있음을 알았다고 의제할 수 없으나, 정정된 공시지가가
	2018.09.07.에 甲에게 통지 되었으므로 이날 당초 처분도
	있었음을 알았다고 판단된다. 따라서 2018.09.07.을 안날로
	보고 이날부터 90일 이내에 소송을 제기할 수 있으며 사안
	의 2018.10.22.일은 해당기간 이내이므로 제소기간을 준수
	하고 있다.
	IV. 甲의 소송이 적법한지
	사안에서 대상적격, 제소기간을 갖추었고 나머지 소송요건
	또한 갖추었으므로, 甲 소송은 적법하다.
	<물음2> 15
	I. 논점의 정리
	토지가격비준표의 법규성 여부 및 하자치유의 가능성을 검
	토한다.
	II. 토지가격비준표의 법적성질 등
	1. 법적성질
	토지가격비준표는 형식(행정규칙)과 내용(법규명령)이 다른
	법률보충적 행정규칙으로 볼 수 있다. 이에 대해 행정규칙
	설, 법규명령설, 위헌무효설, 수권여부기준설이 대립하나, 판
	례는 토지가격비준표는 집행명령인 개별토지가격 합동조사

	지침과 더불어 법령보충적인 구실을 하는 법규적 성질을 가지고 있는 것으로 보아야 한다고 판시하였다.
	2. 토지가격비준표 적용 오류의 하자의 정도
	토지가격비준표 적용 오류는 내용상 하자로서 통설·판례인 중대명백성설에 따를 때, 내용상 중대하나 외견상 명백하지 않기에 취소사유에 해당한다.
	Ⅲ. 하자치유 가능성
	1. 의의
	하자의 치유란 성립 당시 위법한 것이라고 하더라도 사후에 흠결을 보완 시 적법한 행위로 취급하는 것을 말한다.
	2. 인정여부
	하자치유에 대해, 행정의 능률성 확보를 위해 허용하는 긍정설, 행정결정의 자의성을 배제하기 위해 부정되어야 하는 부정설, 원칙적으로 허용될 수 없으나 국민의 방어권보장을 침해하지 않는 범위 내에서 허용될 수 있다는 절충설이 대립한다. 판례는 원칙적으로 허용될 수 없는 것이나 예외적으로 국민의 권익을 침해하지 않는 범위에서 구체적 사정에 따라 합목적적으로 인정해야 한다고 하였다. 법치주의의 관점에서는 하자치유는 원칙적으로 부정함이 타당하지만 행정

	의 능률성을 고려할 때 국민의 권리구제를 침해하지 않는 범위 내에서 제한적으로 긍정함이 타당하다.
	3. 하자치유의 적용범위
	하자의 치유는 법치주의의 관점에서 보아 원칙적으로는 허용될 수 없지만, 국민의 권리와 이익을 침해하지 않는 범위에서 예외적으로 인정되어야 한다. 다수설과 판례는 하자치유는 취소사유에만 가능하며, 절차와 형식상의 하자에만 인정된다고 본다. 시간적 한계와 관련하여 판례는 행정쟁송제기 이전까지 하자치유가 가능하다는 입장을 취한다.
	4. 관련판례
	대법원도 선행처분인 개별공시지가결정이 위법하여 그에 기초한 개발부담금 부과처분도 위법하게 된 경우 그 하자의 치유를 인정하면 개발부담금 납부의무자로서는 위법한 처분에 대한 가산금 납부의무를 부담하게 되는 등 불이익이 있을 수 있으므로, 그 후 적법한 절차를 거쳐 공시된 개별공시지가결정이 종전의 위법한 공시지가결정과 그 내용이 동일하다는 사정만으로는 위법한 개별공시지가결정에 기초한 개발부담금 부과처분이 적법하게 된다고 볼 수 없다고 보았다.

IV. 사안의 해결

토지가격비준표를 적정하게 반영하지 못한 것은 내용상 하자이며, 정정행위를 통해 정정한 개별공시지가가 종전의 공시지가와 동일하게 산정되었다 하더라도, 하자치유를 인정하게 되면 甲은 개발부담금 납부 지연에 따른 가산금을 부담하는 등 불이익을 받게 되므로 하자는 치유되지 않는다고 봄이 타당하다.

<끝>

[문제3] 20

I. 논점의 정리

개별공시지가와 관련하여 토지가격비준표의 법적성질을 검토한 후, 판례 태도에 비추어 검증의견에 따라 결정한 개별공시지가가 적법한지 살펴본다.

II. 개별공시지가와 검증

1. 개별공시지가의 의의 및 근거 (부동산공시법 제10조)

개별공시지가는 시장 등이 과세 및 부담금 산정의 목적을 위하여 산정한 공시기준일 현재 개별토지의 단위 면적당 가격을 의미한다.

2. 법적성질

1) 학설	
후속 행정행위에 대해 직접적인 구속력이 발생하므로, 당사자의 권리 의무에 영향을 미친다는 행정행위설, 후속 행정행위의 산정기준이 되는 것으로 일반적이고 추상적인 규율을 의미한다는 행정규칙설, 국민을 구속하지만 구체적인 효과로 권리, 의무관계의 변동이 발생되지 않는다는 법규명령설, 지가정보를 제공하는 의사작용이라는 사실행위설이 있다.	
2) 판례	
판례는 각종 조세부담금의 산정기준이 되어 국민의 권리의무 내지 법률상 이익에 직접적으로 관계된다고 할 것이고 따라서 이는 행정소송의 대상이 되는 행정처분으로 보아야 한다고 판시하였다.	
3) 검토	
개별공시지가는 토지 조세산정에 지속적으로 적용되는 점에서 법적 규율성을 인정할 수 있는바, 일반처분 중 물적 행정행위로 보아 처분성을 인정할 수 있다.	
3. 검증의 의의 및 취지 (부동산공시법 제10조 제5항)	
검증은 개별공시지가의 타당성을 전문가인 감정평가사가 검	

	토하는 행위로 개별공시지가의 신뢰성, 객관성 확보에 그 취지가 있으며, 사실행위로 볼 수 있다.
	Ⅲ. 토지가격비준표의 법적성질
	1. 의의 (부동산공시법 제3조 제8항, 제10조 제4항)
	토지가격비준표는 표준지와 개별토지 사이의 지가형성요인에 관한 비교표로 개별공시지가 산정 시 자의성을 배제하여 객관성과 전문성을 도모하는데 취지가 있다.
	2. 법적성질
	견해 대립이 있으나, 통설·판례는 토지가격비준표는 상위법인 부동산공시법 제3조 제8항 및 제10조 제4항의 구체적 내용을 보충하여 법령을 보충하는 법규적 성질을 가진다고 본다. 생각건대 상위법령에 위임이 있고, 상위법령과 결합하여 대외적 구속력을 지니는 법령보충적 행정규칙으로 봄이 타당하다.
	IV. 甲주장의 타당성
	1. 관련판례
	판례는 시장등은 표준지공시지가에 토지가격비준표를 사용하여 산정된 지가와 감정평가법인등의 검증의견 및 토지소유자 등의 의견을 종합하여 당해 토지에 대하여 표준지공시

	지가와 균형을 유지한 개별공시지가를 결정할 수 있고, 그와 같이 결정된 개별공시지가가 표준지공시지와 균형을 유지하지 못할 정도로 현저히 불합리하다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 결과적으로 토지가격비준표를 사용하여 산정한 지가와 달리 결정되었거나 감정평가사의 검증의견에 따라 결정되었다는 이유만으로 그 개별공시지가 결정이 위법하다고 볼 수는 없다고 판시하였다.
	2. 甲주장의 타당성 사안의 경우 법규성 있는 토지가격비준표를 사용하여 개별공시지를 산정하였고 이후에, 부동산공시법에 따른 검증절차 및 검증의견에 대해 부동산가격공시위원회의 심의를 적법하게 거쳐 개별공시가격을 결정하였으므로, 단순히 토지가격비준표를 사용한 지가와 다르다는 이유만으로 위법하다는 甲 주장은 타당하지 않다. <끝>
	[문제4] 10 I. 토지수용위원회 1. 의의 및 법적성격 토지수용위원회는 공익사업에 필요한 토지 등의 수용 또는 사용에 대한 재결을 목적으로 설치된 독립된 행정기관이다.

	다수의 구성위원의 합의에 의해 독립적으로 토지수용위원회
	의 이름으로 재결을 하는 점에서 합의적 행정청이며, 준사
	법적 행정기관에 해당하고, 법에서 반드시 설치하도록 하고
	있어 필수기관으로 본다.
	2. 설치 및 구성
	토지수용위원회는 중앙토지수용위원회와 지방토지수용위원
	회가 있으며, 중앙토지수용위원회는 국토교통부에 두고 위
	원장 1명을 포함한 20명 이내의 위원으로 구성한다. 위원장
	은 국토교통부장관이 되며, 위원장은 위원회를 대표하고 위
	원회의 업무를 총괄한다. 지방토지수용위원회의 위원장은
	시도지사가 된다.
	Ⅱ. 보상협의회
	1. 의의 및 법적성격
	보상협의회는 보상업무에 관한 사항을 협의하기 위해서 시·
	군·구에 설치하는 합의제 행정기관이다. 보상협의회 설치
	임의적 사항이나, 공익사업지구 면적이 10만제곱미터 이상
	이고, 토지 등의 소유자가 50인 이상인 공익사업의 경우에
	는 필수적으로 설치하여야 하는 필수기관이다.
	2. 설치 및 구성

	위원장 1명을 포함한 위원 8명 이상 16명 이내의 위원으로
	구성하되, 사업시행자를 위원에 포함시키고, 위원 중 1/3이
	상은 토지소유자 또는 관계인인으로 구성하여야 한다. 위원
	장은 해당 특별자치도 시군 또는 관계인으로 구성하여야 한
	다. 위원장은 해당 특별자치도 시군 또는 구의 부지사 부시
	장 부군수 또는 부구청장이 된다.
	Ⅲ. 부동산 가격공시위원회
	1. 의의 및 법적성격
	부동산가격공시위원회는 부동산가격공시에 관한 사항을 심
	의의결하기 위한 위원회로 부동산가격공시법 제24, 25조
	등에 근거를 둔다. 심의기관에 해당하며, 법에서 반드시 설
	치하도록 규정하고 있는 필수기관이다.
	2. 설치 및 구성
	중앙부동산가격공시위원회와 시군구 부동산가격공시위원회
	가 있으며 중앙부동산가격공시위원회의 위원장은 국토교통
	부 제1차관이 된다. 위원회는 위원장을 포함한 20명 이내의
	위원으로 구성한다. 시군구 부동산가격공시위원회는 시장군
	수 또는 구청장 소속하에 둔다. 위원장 1명을 포함한 10명
	이상 15명 이하의 위원으로 구성한다. 위원장은 부시장, 부
	군수 또는 부구청장이 된다.

IV. 소결

각각의 위원회는 근거법령, 법적성격, 설치 및 구성, 심의 또는 협의사항 등에 차이가 있다. 그러나 모두 행정기관으로 관련된 공·사이익의 조절적 기능을 담당하는 측면에 있어 유사하다.

<이하여백>

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
3교시	100분	③ 감정평가법규
수험번호		성 명

【문제 1】 甲은 2014. 3.경 감정평가사 자격을 취득한 후, 2015. 9. 2.부터 2017. 8. 3.까지 '乙감정평가법인'의 소속 감정평가사였다. 또한 甲은 2015. 7. 7.부터 2017. 4. 30.까지 '수산업협동조합 중앙회(이하 '수협'이라 함)'에서 상근계약직으로 근무하였다. 관할 행정청인 국토교통부장관 A는 甲이 위와 같이 수협에 근무하면서 일정기간 동안 동시에 乙감정평가법인에 등록하여 소속을 유지하는 방법으로 감정평가사 자격증을 대여하거나 부당하게 행사했다고 봄이 상당하여, 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」(이하 '감정평가법'이라 함) 제27조가 규정하는 명의대여 등의 금지 또는 자격증 부당행사 금지에 위반하였다는 것을 이유로 징계처분을 내리고자 한다. 다음 물음에 답하시오. (40점)

1) 국토교통부장관 A가 甲에 대하여 위와 같은 사유로 감정평가법령상의 징계를 하고자 하는 경우, 징계 가능성 및 징계절차에 관하여 설명하시오. (15점)

2) 위 징계절차를 거쳐 국토교통부장관 A는 甲에 대하여 3개월간의 업무정지 징계처분을 하였고, 甲은 당해 처분이 위법하다고 보고 관할법원에 취소소송을 제기하였다. 이 취소소송의 계속 중 국토교통부장관 A는 당해 징계처분의 사유로 감정평가법 제27조의 위반사유 이외에, 징계처분 당시 甲이 국토교통부 장관에게 등록을 하지 아니하고 감정평가업무를 수행하였다는 동법 제17조의 위반사유를 추가하는 것이 허용되는가? (10점)

3) 한편 국토교통부장관은 감정평가관리·징계위원회의 의결에 따라 사전통지를 거쳐 감정평가사 자격취소처분을 하였다. 甲은 사전통지서에 기재된 의견제출기한 내에 청문을 신청하였으나 국토교통부장관은 '감정평가법 제13조 제1항

제1호에 따라 감정평가사 자격취소를 하려면 청문을 실시하여야 한다는 규정이 있지만, 명의대여를 이유로 하는 감정평가사 자격취소의 경우에는 청문을 실시하여야 한다는 규정이 없을 뿐 아니라 청문을 실시할 필요도 없다'는 이유로 청문을 실시하지 않았다. 甲에 대한 감정평가사 자격취소처분이 적법한지 설명하시오. (15점)

<감정평가 및 감정평가사에 관한 법률>

제13조(자격의 취소) ① 국토교통부장관은 감정평가사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 자격을 취소하여야 한다.

1. 부정한 방법으로 감정평가사의 자격을 받은 경우
2. 제39조제2항제1호에 해당하는 징계를 받은 경우

제17조(등록 및 갱신등록) ① 제11조에 따른 감정평가사 자격이 있는 사람이 10조에 따른 업무를 하려는 경우에는 대통령령으로 정하는 기간 이상의 실무수습을 마치고 국토교통부장관에게 등록하여야 한다.

②~④ 생략

제27조(명의대여 등의 금지) 감정평가사 또는 감정평가업자는 다른 사람에게 자기의 명 또는 상호를 사용하여 제10조에 따른 업무를 수행하게 하거나 자격증·등록증 또는 인가증을 양도·대여하거나 이를 부당하게 행사하여서는 아니 된다.

제45조(청문) 국토교통부장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 처분을 하려는 경우에는 청문을 실시하여야 한다.

1. 제13조제1항제1호에 따른 감정평가사 자격의 취소
2. 제32조제1항에 따른 감정평가법인의 설립인가 취소

【문제 2】 다음 물음에 답하시오(각 별개의 물음임). (30점)

1) 국토교통부장관 乙은 감정평가사 甲이 감정평가업무를 행하면서 고의로 잘못된 평가를 하였다는 것을 이유로, 감정평가 및 감정평가사에 관한 법률(이하 감정평가법) 제32조 제1항 및 동법 시행령 제29조 별표3에 따라 6개월의 업무정지처분을 하였고, 甲은 이에 불복하여 취소소송을 제기하였다. 소송의 계속 중에 6개월의 업무정지기간이 만료하였다. 甲은 위 취소소송을 계속할 이익이 인정되는가. (20점)

2) 한편, 감정평가사 乙은 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 따른 감정평가준칙을 위반하여 감정평가를 하였음을 이유로 업무정지처분을 받게 되었으나, 국토교통부장관은 그 업무정지처분이 「부동산 가격공시에 관한 법률」에 따른 표준공시지가 공시 등의 업무를 정상적으로 수행하는 데에 지장을 초래할 우려가 있음을 들어, 2021. 4. 1. 乙에게 업무정지처분을 갈음하여 3천만원의 과징금을 부과하였다. 乙은 부과된 과징금이 지나치게 과중하다는 이유로 국토교통부장관에게 이의신청을 하였고, 이에 대해서 국토교통부장관은 2021. 4. 30. 乙에 대하여 과징금을 2천만원으로 감액하는 결정을 하였다. 乙은 감액된 2천만원의 과징금도 과중하다고 생각하여 과징금부과처분의 취소를 구하는 소를 제기하고자 한다. 이 경우 乙이 취소를 구하여야 하는 대상은 무엇인지 검토하시오.(10점)

【문제 3】 국토교통부장관은 감정평가사 甲에 대하여 법령상 의무 위반을 이유로 6월의 업무정지처분을 하였다. 甲은 업무정지처분취소소송을 제기하였으나 기각되었고 동 기각판결은 확정되었다. 이에 甲은 위 처분의 위법을 계속 주장하면서 이로 인한 재산상 손해에 대해 국가배상청구소송을 제기하였다. 이 경우 업무정지처분 취소소송의 기판력이 국가배상청구소송에 미치는 지를 논하시오.(20점)

【문제 4】 국토교통부장관은 타당성조사 결과에 근거하여 고의로 잘못된 평가를 한 A법인 소속 감정평가사 甲에 대하여 업무정지 6개월의 징계처분을 하였다. 이에 불복한 甲이 징계처분취소소송을 제기하였는바, 법원은 해당 징계처분을 업무정지 3개월의 징계처분으로 감경하는 판결을 할 수 있는지에 관하여 설명하시오. (10점)

[문제1] 40

<물음1>15

I. 징계 가능성 (징계사유 검토)

1. 관련규정 검토 (감정평가법 제27조 명의대여금지)

감정평가법인등은 다른 사람에게 자기의 성명 또는 상호를 사용하여 업무를 수행하게 하거나 자격증, 등록증 또는 인가증을 양도·대여하거나 이를 부당하게 행사하여서는 아니 된다. 여기에서 대여는 감정평가사가 아닌 자가 업무를 행하려는 것을 알면서도 빌려주는 행위를 말하고, 부당행사는 본래 용도가 아닌 용도로 자격증을 행사하는 것을 의미한다.

2. 감정평가법 제39조 징계

국토교통부장관은 일정 사유에 해당할 경우 감정평가관리·징계위원회 의결에 따라 자격취소, 등록취소, 2년 이하 업무정지, 견책 등의 징계를 할 수 있다.

3. 관련 판례

판례는 법인에 적을 두었으나 실질적인 업무수행 없이 경력을 부당하게 인정받는 한편, 법인의 설립, 존속에 관한 인원수만을 형식적으로 갖추거나 감정평가 업무를 추가적으로 배정받을 목적으로 자격증을 행사한 경우 자격증 부당행사

	에 해당한다고 보았다. 사안은 자격증 부당행사에 해당한다.
	4. 사안의 해결 (징계 가능성)
	甲은 감정평가법 제27조의 명의대여금지의무를 위반하였으므로, 국토교통부장관은 동법 제39조에 따라 징계를 할 수 있다.
	Ⅱ. 징계의 절차
	1. 감정평가법상 징계 절차
	감정평가사 협회는 감정평가사에게 징계 사유가 있다고 인정하는 경우, 그 증거서류를 첨부하여 국토교통부장관에게 징계를 요청할 수 있다(법 제39조 제3항). 국토교통부장관은 감정평가사에게 징계사유가 있다고 인정되면, 증명서류를 갖추어 감정평가관리·징계위원회에 징계의결을 요구하고, 징계위원회는 징계의결의 요구를 받으면 지체 없이 그 징계요구 내용과 징계심의기일을 당사자에게 통지하여야 한다. 징계위원회는 징계의결의 요구를 받은 날부터 60일 이내 징계에 관한 의결을 하여야 하며, 당사자는 징계위원회에 출석하여 구술 또는 서면으로 자기에게 유리한 사실을 진술하거나 필요한 증거를 제출할 수 있다. 국토교통부장관은 위원회의 의결에 따라 징계를 한 때에는 지체 없이 징계사실을 당사자와 감정평가사협회에 각각 서면으로 통보하여야

	하고, 이 경우 통보 서면은 징계사유를 명시하여야 한다.
	2. 징계위원회의 성격 및 의결의 구속력
	징계위원회는 합의제 행정기관이다. 감정평가법 제39조 제1
	항에서 국토교통부장관은 징계위원회의 의결을 따라 징계를
	할 수 있다고 규정하고 있으므로 징계위원회는 구속력을 가
	지는 의결기관에 해당한다.
	3. 행정절차법에 따른 절차
	징계는 침익적 처분이므로, 행정절차법에 따라 사전통지(21
	조), 의견청취(22조), 처분의 이유제시(23조)와 같은 행정절
	차법상 절차가 적용된다.
	<물음2> 10
	I. 논점의 정리
	취소소송 계속 중 처분사유 추가변경의 허용여부, 기본적
	사실관계의 동일성이 인정되는지 문제된다.
	II. 처분사유 추가, 변경의 의의 등
	처분사유 추가, 변경은 처분 당시에 존재하였으나 처분의
	이유로 제시되지 않은 사실 및 법적근거를 소송 계속 중 추
	가하거나 변경하는 것을 말한다.

	Ⅲ. 처분사유 추가, 변경 허용여부
	1. 학설
	원고의 방어권을 침해하는 점에서 이를 부정하는 견해와 일회적인 분쟁해결을 위해 긍정하는 견해, 원고의 방어권을 고려하여 제한적으로 인정된다는 견해가 있다.
	2. 판례 및 검토
	판례는 당초 처분의 근거로 삼은 사유와 기본적 사실관계의 동일성이 있다고 인정되는 범위에서 처분사유 추가변경을 긍정하여 제한적으로 긍정하는 입장이다. 생각건대, 실질적 법치주의와 분쟁의 일회적 해결이라는 요청 및 원고의 방어권 보장과 신뢰보호 조화 관점에서 제한적 긍정설이 타당하다.
	IV. 인정 요건
	1. 시간적 범위
	① 처분사유의 추가·변경은 사실심 변론 종결시까지만 허용되며, ② 취소소송에서 처분의 위법성 판단의 기준시점을 처분시로 보는 <처분시설>에 따르면 처분시에 객관적으로 존재하였던 사유만이 처분사유의 추가·변경의 대상이 된다. 사안의 경우 사실심 변론 종결전이며, 추가하려는 처분사유는 처분시에 존재했던 사유로 보이므로, 시간적 범위는 문

제 되지 않는다.

2. 객관적 범위

① 처분사유의 추가·변경은 취소소송의 소송물 범위 내에서만 가능하다. 즉, 처분의 동일성이 유지되어야 하며, ② 추가·변경되는 처분사유는 당초 처분의 근거로 삼은 사유와 기본적인 사실관계 있어서 동일성이 인정되어야 한다. 사안의 경우 처분사유를 추가하여도 소송물은 동일하므로 기본적인 사실관계의 동일성이 있는지를 검토하여야 한다.

3. 기본적인 사실관계의 동일성 여부

1) 기본적인 사실관계의 동일성의 의미

판례는 기본적인 사실관계가 동일하다는 것은 처분사유를 법률적으로 평가하기 이전의 구체적인 사실에 착안하여 그 기초인 사회적 사실관계가 기본적인 점에서 동일한 것을 말한다고 판시한바 있다.

2) 관련 판례

처분청이 처분 당시 적시한 구체적 사실을 변경하지 아니하는 범위 내에서 단지 처분의 근거 법령만을 추가·변경하는 것은 새로운 처분사유의 추가라고 볼 수 없으므로 이와 같은 경우에는 처분청이 처분 당시 적시한 구체적 사실에 대

	하여 처분 후 추가·변경한 법령을 적용하여 처분의 적법 여부를 판단하여도 무방하고 판시한바 있다.
	V. 사안의 경우
	사안의 경우 당초 처분사유는 자격증을 부당행사 하였다는 것인데 반해, 추가하려는 처분사유는 등록을 하지 않고 감정평가를 하였다는 것이므로 양자는 기본적 사실관계 동일성을 인정할 수 없으므로 해당 처분사유를 추가하는 것은 허용될 수 없다.
	<물음3> 15
	I. 논점의 정리
	자격취소처분의 성질, 행정절차법의 규정 및 대법원 판례 법리를 검토하여 청문을 하지 않은 자격취소처분이 적법한지 검토한다.
	II. 자격취소처분의 의의, 법적성질
	국토교통부장관이 감정평가관리·징계위원회의 의결에 따라 감정평가사의 자격을 취소하는 처분을 의미한다. 감정평가를 수행할 수 있는 권리와 의무를 박탈하는 점에서 침익적 성격의 행정행위로서 행정쟁송법상 처분에 해당한다. “할 수 있다”는 문언상 징계처분은 재량행위로 볼 수 있다.

	Ⅲ. 내용상 하자 검토
	1. 관련규정 검토 (감정평가법 제39조 제1항)
	감정평가법 제39조 제1항에 감정평가법 제27조를 위반한 경우 자격취소처분은 다른 사람에게 자격증·등록증 또는 인가증을 양도 또는 대여한 경우에만 할 수 있다고 명문화하고 있다.
	2. 관련판례
	감정평가사가 자신의 감정평가경력을 부당하게 인정받는 한편, 소속 법인으로 하여금 설립과 존속에 필요한 감정평가사의 인원수만 형식적으로 갖추게 하거나 법원으로부터 감정평가 물량을 추가로 배정받을 수 있는 자격을 얻게 할 목적으로 자신의 등록증을 사용한 경우, 자격증 등의 부당행사에 해당한다고 보았다.
	3. 사안의 경우
	乙법인에서 감정평가사 본연의 업무를 전혀 수행하지 않았고, 그 법인의 운영에도 관여하지 않은 것이 자격증의 부당행사에 해당하므로, 자격취소 처분의 사유가 될 수 없다. 다만, 甲의 행위가 명의대여일 가능성을 배제하기 어려운바, 명의대여에 해당되는 경우라면 감정평가법 제39조에 의거해당 자격취소처분은 적법하다.

	IV. 절차상 하자 검토
	1. 청문
	1) 의의 및 근거
	청문이란 행정청이 어떠한 처분을 하기에 앞서 당사자들의
	의견을 직접 듣고 증거를 조사하는 절차를 말한다(행정절차
	법 2조 5호).
	2) 청문사유 (행정절차법 제22조 제2항)
	다른 법령 등에서 청문을 하도록 규정하고 있는 경우, 행정
	청이 필요하다고 인정하는 경우, 인허가 등의 취소, 신분,
	자격의 박탈, 법인이나 조합 등의 설립허가의 취소 처분 시
	의견제출기한 내에 당사자들의 신청이 있는 경우에는 청문
	을 실시해야 한다. 행정청은 청문을 실시하려면 청문이 시
	작되는 날부터 10일 전까지 처분하고자 하는 원인이 되는
	사실과 처분의 내용 및 법적 근거 등에 대해 당사자 등에게
	통지해야 한다.
	2. 청문의 생략사유 (행정절차법 제22조 제4항)
	① 공공의 안전 또는 복리를 위하여 긴급히 처분을 할 필요
	가 있는 경우, ② 법령 등에서 요구된 자격이 없거나 없어
	지게 되면 반드시 일정한 처분을 하여야 하는 경우에 그 자
	격이 없거나 없어지게 된 사실이 법원의 재판 등에 의하여

	객관적으로 증명된 경우, ③ 해당 처분의 성질상 의견청취가 현저히 곤란하거나 명백히 불필요하다고 인정될 만한 상당한 이유가 있는 경우, ④ 당사자가 의견진술의 기회를 포기한다는 뜻을 명백히 표시한 경우에 의견청취를 생략할 수 있다.
	3. 사안의 경우
	1) 감정평가법 제45조 규정 검토
	감정평가법 제45조에서는 동법 제13조 제1항 제1호에 따른 감정평가사 자격의 취소 시에만 청문을 하도록 규정하고 있다. 그러나 같은 자격의 취소라는 침익적인 결과가 초래되는 점에서 반드시 법 제13조 제1항 제1호의 취소에만 청문이 적용된다고 제한적으로 해석하는 것은 타당하지 않다.
	2) 청문을 실시하지 않은 사유가 있는지
	사안에서 당해 처분의 성질상 의견청취가 현저히 곤란하거나 명백히 불필요하다고 인정될 만한 상당한 이유가 있는 사정은 보이지 않는다. 게다가 甲이 권리구제를 위하여 소명의 기회를 가지고자 청문을 신청하였다는 점을 고려할 때 청문을 실시하지 않을 정당한 사유는 없다.
	3) 소결 (절차상 하자)

	해당 자격취소처분에는 청문을 결한 절차적 하자가 있으며,
	중대명백성설에 따를 때 절차상 하자는 내용상 중대하나 외
	견상 명백하지 않으므로, 사안의 자격취소처분은 취소사유
	의 위법이 있다.
	<끝>
	[문제2] 30
	<물음1> 20
	I. 논점의 정리
	甲의 소의 이익 인정여부와 관련하여 감정평가법 시행령 제
	29조 [별표3]의 법적성질을 검토한다.
	Ⅱ. 감정평가법 시행령 제29조 [별표3]의 법적성질
	동 법령에 따른 가중처분의 기준은 그 실질은 행정규칙이지
	만 형식은 대통령령인 법규명령형식의 행정규칙이다. 대법
	원은 대통령령 형식의 구 청소년보호법 시행령이 법규명령
	의 효력을 가진다고 판시하여 시행령으로 규정된 경우 대외
	적 구속력을 긍정한다. 따라서 상기 제재적 처분의 기준은
	대외적 구속력이 인정된다.
	Ⅲ. 소의 이익
	1. 소의 이익의 의의 및 원고적격과 구별여부

	협의의 소의 이익이란 원고가 소송상 청구에 대하여 본안판결을 구하는 것을 정당화시킬 수 있는 현실적 이익 내지 필요성으로서 권리보호의 필요를 의미한다. 소의 이익을 원고적격과 구별하지 않는 견해가 있으나, 원고적격은 권리보호 이익의 주관적 측면을 소의 이익은 객관적 측면을 나타낸다는 점에서 이를 구별하는 것이 타당하다.
	2. 회복되는 법률상 이익의 범위(행정소송법 제12조 후문) 견해대립이 있으나, 행정소송법 제12조 전문은 원고적격을 후문을 협의의 소익을 규정하고 있다고 봄이 타당하다. 회복되는 법률상 이익의 범위에 대하여 법적으로 보호할 만한 가치가 있는 이익에 한정하는 견해, 경제적 인격적, 사회적 이익까지 포함하는 견해, 문화적 이익까지 포함하는 견해가 있으나 대법원은 법률상 이익이란 직접적이고 구체적인 이익을 말하며, 간접적이거나 사실적, 경제적인 이해관계를 가진 경우는 포함되지 않는다고 판시하였다.
	3. 처분효력 소멸 시 협의의 소익 처분의 효력기간이 경과한 경우 협의의 소익이 인정되지 않는다. 다만, 감정평가법 시행령 제29조 [별표3]에 위반횟수에 따른 가중처분을 규정하고 있는바, 이러한 경우 예외적으로 소의 이익을 인정할 수 있는지 문제된다.

IV. 제재적 처분이 가중처분인 경우 소익에 대한 판례	
1. 종래 판례	
대법원은 종래 제재적 처분기준의 규정형식 및 효력을 기준으로 법규명령의 효력을 가지는 경우 소익을 인정하였고, 행정규칙의 효력을 가지는 경우 부정하였다.	
2. 최근 판례	
대법원은 현실적으로 권리보호의 필요성을 기준으로 판단하여 소익을 긍정한다. 그 논거로 행정청은 처분기준을 준수할 의무를 지고, 상대방은 장래에 확실히 받을 것으로 예상되는 가중처분에 대한 현실적 우려가 있으며 선, 후행 처분을 따로 다투게 되는 경우 이중의 노력과 비용이 발생하고 시간의 경과가 있는 경우 증거자료의 일실위험이 있는 점을 들고 있다.	
V. 사안의 해결	
선행처분으로 인해 가중체재처분을 받을 위험은 현실적, 구체적인바, 비록 처분기간이 도과하여 처분의 효력이 소멸되었다고 하더라도, 이를 다룰 현실적인 필요성이 있다고 본다. 따라서 甲에게 협의의 소익이 인정된다.	
<물음2> 10	

	I. 논점의 정리
	사안은 이의신청에 따른 감액처분이 있는 경우 원처분과 감액처분 중 어느 것이 취소소송의 대상이 되는지 문제된다.
	II. 과징금의 의의 및 법적성질 (감정평가법 제41조)
	과징금은 행정법상 의무위반 행위로 얻은 경제적 이익을 박탈하기 위한 금전상 제재금을 말하는데, 감정평가법상 과징금은 업무정지에 갈음하여 부과하는 변형된 과징금이다(감정평가법 제41조). 과징금은 급부하명으로 행정소송법 제2조의 처분에 해당한다.
	III. 감액처분 시 취소소송의 대상
	1. 학설
	① 당초 처분과 변경처분은 독립된 처분으로서 각각 소송의 대상이 된다는 병존설, ② 당초 처분은 변경처분에 흡수되어 소멸되므로 경정처분만이 소송의 대상이 된다는 흡수설, ③ 변경처분으로 변경되고 남은 당초 처분만이 소의 대상이 된다는 역흡수설 등이 대립한다.
	2. 판례
	과세관청이 과세처분을 한 뒤에 당초 부과처분의 일부를 취소, 감액하는 내용의 경정결정을 한 경우 위 경정처분은 그

에 의하여 감소된 세액부분에 관하여서만 법적 효과를 미치는 것으로서 당초 부과처분과 독립의 과세처분이 아니라 그 실질은 당초 부과처분의 변경이고 그에 의하여 세액의 일부 취소라는 납세자에게 유리한 효과를 가져오는 처분이라 할 것이므로 그 경정결정으로도 아직 취소되지 않고 남아 있는 부분이 위법하다고 하여 다투는 경우에는 항고소송의 대상이 되는 것은 당초의 부과처분중 경정결정에 의하여 취소되지 않고 남은 부분이 된다 할 것이고 경정결정이 항고소송의 대상이 되는 것은 아니라고 판시한바 있다.

3. 검토

당초 처분을 당사자에게 유리하게 변경하는 경우에는 변경되고 남은 원처분을 소의 대상으로 하는 것이 원처분의 연속성 측면에서 타당하고, 증액경정처분의 경우에는 국민의 재판청구권을 보장하기 위해 증액처분인 변경처분을 소의 대상으로 삼는 것이 타당하다.

IV. 사안의 해결

사안의 경우 당초 부과된 과징금 보다 감액되는 변경처분을 한 경우이므로, 甲이 취소를 구하여야 할 대상은 감액되고 남은 2021. 4. 1.자 2천만원의 과징금 부과처분이다.

<끝>

[문제3] 20

I. 논점의 정리

취소소송과 국가배상청구소송의 위법성 개념을 검토하고, 취소소송의 기각판결에 따른 기판력이 국가배상청구소송에 미치는지 검토한다.

II. 기판력 개관

기판력이란 소송물에 관하여 판결이 확정되면 이후 동일한 사항이 문제되는 경우에 당사자(승계인 포함)는 그에 반하는 주장을 할 수 없고(반복금지), 법원은 그에 반하는 판단을 할 수 없는(모순금지) 구속력을 말한다. 기판력은 인용판결뿐만 아니라 기각판결에도 인정되며, 재판간 모순방지와 분쟁의 종국적인 해결에 그 취지가 인정된다. 기판력은 당사자 및 당사자와 동일시 할 수 있는자에게(주관적 범위), 사실심변론종결시까지 미치며(시간적 범위), 판결의 주문에 나타난 처분의 위법성존부에 관한 판단에 미친다(객관적 범위).

III 위법성의 개념

1. 취소소송의 위법성

취소소송의 소송물은 위법성 일반에 대한 판단으로 취소소송의 위법성은 처분등의 법규성 위반이며, 재량의 일탈남용

으로 인한 위법을 포함한다.

2. 국가배상의 위법성

1) 학설

① 국가배상법상의 위법은 공무원의 직무행위가 '법 규범'에 적합한지를 기준으로 판단하여야 한다고 보는 <협의의 행위위법설>, ② '법령 위반' 뿐만 아니라 인권존중·권력남용 금지의 원칙·신의성실의 원칙의 위반도 포함된다고 보는 <광의의 행위위법설> ③ 가해행위의 결과로 국민이 받은 손해를 국민이 수인하여여 하는가를 기준으로 판단하는 <결과불법설> 및 ④ 직무행위의 적법·위법뿐만 아니라, 피침해이익의 성격과 침해의 정도, 가해행위의 태양 등을 종합 고려하여야 한다고 보는 <상대적 위법성설>이 있다.

2) 판례

위법성 판단의 기준에 대하여 대법원의 주류적인 입장은 행위의 법규범위반을 의미한다는 행위위법설이나 행위가 객관적으로 정당성을 결여한 경우를 의미한다는 상대적 위법성설을 위하는 경우도 있다.

3) 소결

손해배상은 위법행위에 대한 전보수단으로, 적법행위로 발

	생한 손실에 대한 전보수단인 손실보상과 구별되고, 취소소송에서 위법의 본질이 법규 위반인 점을 고려할 때 국가배상도 위법의 개념을 '법질서 위반'이라는 단일한 가치판단 기준으로 보아야 하며, 국민의 권리구제 확대를 위해 <광의의 행위위법설>의 입장이 타당하다.
	IV. 국가배상청구소송에의 기판력 작용 여부
	1. 학설
	① 취소소송의 위법과 국가배상청구소송의 위법을 동일한 개념이라고 보아 취소소송의 확정판결(인용·기각판결)의 기판력이 국가배상청구소송에 미친다고 보는 <기판력 긍정설>, ② 취소소송의 위법과 국가배상청구소송의 위법을 다른 개념으로 보고, 양자의 소송물이 달라 기판력이 미치지 않는다고 보는 <기판력 부정설> 및 ③ 국가배상청구소송의 위법의 범위가 취소소송의 위법 보다 넓다고 보아 인용판결의 기판력은 국가배상청구소송에 미치나, 기각판결의 기판력은 미치지 않는다고 보는 <제한적 긍정설>이 있다.
	2. 판례
	판례는 '국가배상책임에 있어 공무원의 가해행위는 법령을 위반한 것이어야 하고, 법령을 위반하였다 함은 엄격한 의미의 법령 위반뿐 아니라 인권존중, 권력남용금지, 신의성실

과 같이 공무원으로서 마땅히 지켜야 할 준칙이나 규범을 지키지 아니하고 위반한 경우를 포함하여 널리 그 행위가 객관적인 정당성을 결여하고 있음을 뜻하는 것'이라고 하거나, '어떠한 행정처분이 후에 항고소송에서 취소되었다고 할 지라도 그 기판력에 의하여 당해 행정처분이 곧바로 공무원의 고의 또는 과실로 인한 것으로서 불법행위를 구성한다고 단정할 수는 없는 것'이라고 판시하는 바, 기판력에 관한 입장이 불분명하다.

3. 검토

취소소송과 국가배상청구소송의 위법의 개념을 어떻게 보는지에 따라 취소판결의 기판력이 미치는지 여부가 달라진다. 국가배상청구소송의 위법을 취소소송의 위법보다 더 넓게 보는 광의의 행위위법설이 통설이며 이 견해에 따라 인용판결의 기판력만이 국가배상청구소송에 미친다고 보는 <제한적 긍정설>이 타당하다.

V. 사안의 해결

사안의 경우 업무정지처분의 취소소송은 기각 되었으므로, 전소의 기판력이 국가배상청구소송에 미친다고 볼 수 없다.

<끝>

[문제4] 10

I. 쟁점의 정리

행정소송법 제4조의 제1호에서 취소소송을 '행정청의 위법한 처분등을 취소 또는 변경하는 소송'이라고 정의하고 있다. 이에 '변경'의 해석과 관련하여 법원이 일부취소판결을 할 수 있는지가 문제 된다.

II. 업무정지처분의 법적성질 (감정평가법 제39조 제1항)

업무정지는 일정기간 업무를 못하도록 하는 부작위하명으로 항고소송의 대상이되는 처분에 해당하며, 감정평가법 제39조 제1항 문언상 업무정지처분은 재량행위에 해당한다.

III. 행정소송법 제4조 제1호의 '변경'의 의미

① 학설은 행정소송법 제4조 제1호의 '변경'을 적극적 변경으로 보아 법원이 위법한 처분등을 취소하고 새로운 처분내용으로 하는 판결을 할 수 있다고 보는 <적극적 변경설>과 행정소송법에서 의무이행소송을 규정하고 있지 않으므로 행정소송법상 '변경'은 일부취소만을 의미한다고 보는 <소극적 변경설>이 대립하고, ② 판례는 위 변경을 소극적 변경(일부취소)이라고 보는 입장을 취한다. ③ 생각건대, 적극적 변경설은 법원이 행정청의 처분권한을 행사하는 것과 같은 결과를 가져오므로 권력분립의 원칙에 반하여 타당하지

않고, 현행 행정소송법이 의무이행소송을 인정하고 있지 않으므로, 행정소송법상 '변경'을 소극적 변경으로서 일부취소를 의미한다고 보는 것이 타당하다.

IV. 일부취소의 가능성 (요건 및 한계)

외형상 하나의 행정처분이라도 처분의 일부에만 위법이 있는 경우에 ① 가분성이 있거나, ② 일부취소 되는 부분이 특정(특정성)될 수 있다면 그 일부만의 취소도 가능하다. 다만, 판례는 영업정지처분과 같이 재량행위인 경우에는 처분청의 재량권을 존중하여야 하므로 법원이 직접 처분을 하는 것은 인정되지 않는다고 본다. 따라서 일부취소판결을 할 수 없고 전부를 취소하여야 한다고 판시한다.

V. 사안의 해결

감정평가법 제39조의 업무정지처분은 재량행위이므로, 처분청의 재량권 존중 차원에서 법원이 일부 취소할 수는 없으므로, 사안의 경우 법원은 해당 징계처분을 업무정지 3개월로 감경하는 판결을 할 수 없다.

<이하여백>